

30/11/2022**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. RÉU/DELATADO TEM O “*DIREITO DE FALAR POR ÚLTIMO*”. AMPLA DEFESA E APRESENTAÇÃO DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. ORDEM CONCEDIDA.

1.O acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3º da Lei 12.850/2013), e assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo colaborador. Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo colaborador.

2.O interesse processual do colaborador está direta e intimamente ligado à obtenção da condenação do delatado pelo Ministério Público. O colaborador precisa da condenação baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a colaboração não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios

HC 166373 / PR

prometidos.

3.A relação de antagonismo entre as versões da acusação, do colaborador e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o *direito de falar por último*. A relação COLABORADOR X DELATADO é de antagonismo, é de contradição, é de contraditório. Trata-se de situação diversa daquela tratada pelo Código de Processo Penal em relação aos corréus.

4.O delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator.

5.*Habeas Corpus* deferido, com a fixação da seguinte TESE: “*Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade*”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Plenário, sob a Presidência da Senhora Ministra ROSA WEBER, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, acordam em conceder a ordem de *Habeas Corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional

HC 166373 / PR

sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros EDSON FACHIN (Relator), ROBERTO BARROSO, LUIZ FUX, CÁRMEN LÚCIA e MARCO AURÉLIO. Foi fixada a seguinte tese: “Havendo pedido expresse da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.

Brasília, 30 de novembro de 2022.

Ministro Alexandre de Moraes

Redator para o acórdão

25/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 96.059/PR, Rel. Min. Felix Fischer.

A questão de fundo diz respeito à controvérsia entre o caráter **comum ou sucessivo** do prazo de alegações finais **entre defesas** de acusados que celebraram acordo de colaboração premiada e de acusados que não firmaram negócio jurídico processual dessa natureza.

O paciente foi denunciado em primeiro grau pela suposta prática dos crimes de pertinência a organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em síntese, segundo a denúncia, o paciente, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido, em conjunto com outros acusados, 37 (trinta e sete) milhões de reais a título de vantagem indevida que funcionariam como contrapartida decorrente de favorecimentos concedido a empresas em contratos firmados com a referida estatal (especialmente no toca à construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho). Aponta-se ainda

HC 166373 / PR

que parte desses valores teria sido repassada ao paciente mediante atos de lavagem, inclusive com posterior adoção de medidas tendentes à reintegração de partes desses recursos.

Sintetiza a defesa que os corréus EDISON KRUMMENAUER e LUÍS MÁRIO DA COSTA MATTONI celebraram acordo de colaboração com o Ministério Público Federal.

Adiciona que o paciente **não é mencionado** nos atos de colaboração realizados por LUÍS MÁRIO DA COSTA MATTONI e **é citado** nas declarações prestadas por EDISON KRUMMENAUER. Mais do que isso, afirma a defesa que, *“no caso concreto, há clara e direta imputação de crime pelo delator Edison ao Paciente”*.

EDISON KRUMMENAUER também é ex-gerente da Petrobras e teria sucedido o paciente na condução do empreendimento em que supostamente efetuados os pagamentos de vantagem indevida.

Acerca do mencionado colaborador, transcrevo segmento da sentença condenatória proferida em primeiro grau que atesta o seguinte:

“38. O acusado Edison Krummenauer, antes mesmo da denúncia, celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF e que foi homologado por este Juízo (processo 5060108-48.2016.4.04.7000). Cópias dos depoimentos por ele prestados no acordo instruem a denúncia (evento 1, anexo15, anexo19, anexo20). Cópia do acordo e da decisão de homologação foram juntados nos eventos 443 e 444.”

Aponta a defesa que, em sede de interrogatório, o Juízo de primeiro grau assegurou que os acusados colaboradores fossem inquiridos em momento anterior aos corréus delatados.

Encerrada a instrução processual, o Juízo conferiu prazo comum a todos os acusados para fins de apresentação de alegações finais, não fazendo distinção entre colaboradores e não colaboradores.

Diante disso, a defesa do ora paciente postulou, para fins de apresentação de alegações finais, a concessão de prazo sucessivo entre as defesas dos corréus colaboradores e não colaboradores. Nada obstante,

HC 166373 / PR

referida providência foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau.

Irresignada, a defesa impetrou *habeas corpus* endereçado ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O órgão regional, por sua vez, concluiu que “os prazos para apresentação de alegações finais são comuns a todos os atores processuais, independente de sua posição de colaborador ou não”.

A defesa interpôs recurso ordinário contra o decidido pelo TRF-4ª. Em decisão monocrática, o Min. Felix Fischer não conheceu do recurso, pronunciamento posteriormente chancelado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Pela suposta prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão. Foi absolvido da prática do delito de pertinência a organização criminosa.

A sentença examinou a temática ora em apreço, em síntese, nos seguintes termos:

“77. Não há falar sequer em cerceamento de defesa, pois os acusados colaboradores foram interrogados sob exame cruzado no momento próprio e mesmo antes as Defesas dos demais acusados já sabiam o que eles em geral tinham a dizer em seus depoimentos, já que a denúncia foi instruída com cópia de seus depoimentos prestados nos acordos de colaboração (evento 1, anexo15, anexo19, anexo20 e anexo32).

(...)

82. A Defesa de acusado colaborador não equivale à Acusação, sendo posições processuais distintas.

83. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer hierarquia entre Defesas e acusados. O prazo é comum para alegações finais de todos os defensores.

84. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base em interpretações criativas.”

Quanto à ordem das alegações finais colhidas, o tema foi esclarecido pelo Juízo de primeiro grau da seguinte forma:

HC 166373 / PR

“Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento 500) foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores os demais réus juntaram suas alegações finais. Maurício de Oliveira Guedes (evento 501), Márcio de Almeida Ferreira (evento 502), Paulo Roberto Gomes Fernandes (evento 503) e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 504). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni complementaram suas alegações finais (evento 505).

Após a apresentação das alegações finais os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida na data de 15/01/2018 (evento 509), **tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas Defesas (todas de não colaboradores) conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório, com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais.** Os réus colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 519) e Edison Krummenauer (evento 522) complementaram suas alegações finais antes mesmo do MPF (evento 526). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni, réus não colaboradores, complementaram as alegações finais no evento 529.

Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira optaram por não complementarem suas alegações finais.

(...)

Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada julgou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado.

Não há na alegações finais destes réus nenhuma

HC 166373 / PR

inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo.”

Atualmente, a ação penal de origem encontra-se no Tribunal Regional Federal da 4ª Região aguardando o julgamento de recursos de apelação.

Nesta impetração, aduz a defesa que a fixação de prazo comum para apresentação de alegações finais entre as defesas de réus colaboradores e não colaboradores configura vulneração aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, sublinha a defesa (*grifei*):

“A previsão constitucional assegura que a defesa deverá ser exercida amplamente, e para isso, por óbvio, deve conhecer o conteúdo da acusação, a qual, no caso concreto, conta com a colaboração dos delatores, que devem confirmar a tese acusatória visando obter os benefícios do acordo na sentença, e **podem trazer elementos e argumentos novos**, com o objetivo de incriminar os demais acusados, como é o caso do Paciente.”

Frisa que o conhecimento das alegações apresentadas pelo corréu colaborador seria necessário para propiciar o exercício de atividade reativa própria do contraditório.

Sustenta que, *“compreendida a colaboração como acessória da acusação oficial, ela deve falar antes da defesa dos acusados que não firmaram acordo”*.
Complementa:

“A atuação do réu colaborador objetiva confirmar as alegações feitas por ele no acordo de colaboração premiada e isto, sem sombra de dúvida, o insere no polo acusador, e não defensivo.”

Afirma ainda a defesa que inexistiam provas suficientes a lastrear a condenação, sendo que, nas palavras da defesa, o *“próprio colaborador não*

HC 166373 / PR

apresenta qualquer dado de corroboração com relação ao ora Paciente”.

Por tais razões, requer-se a concessão da “*ordem de habeas corpus para reconhecer a nulidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau, ordenando-se nova abertura de vista à defesa do Paciente após as alegações finais dos réus colaboradores.*”

Ausente pedido liminar.

Foram prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau (e.doc. 7).

A PGR, no mérito, oficiou pela denegação da ordem, sintetizando:

“Nesse contexto, tendo o paciente, desde o início da perseguição, até o seu desenrolar final, amplo acesso aos elementos de cognição, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão singular que indeferiu o pedido de concessão de prazo sucessivo ao paciente para apresentar alegações finais após os demais corréus, seja porque devidamente fundamentada em consonância com a sistemática processual vigente, seja porque não representou cerceamento de defesa, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.”

Foram prestadas informações complementares (e.doc. 13).

Indeferido pedido de habilitação de terceiro (e.doc. 32).

É o relatório.

25/09/2019**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ****ANTECIPAÇÃO AO VOTO**

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, eminentes Pares, cumprimento as sustentações orais, que aportaram reflexões relevantes sobre essa matéria.

Apresento a este Colegiado a percepção que tenho diretamente ao tema de fundo, não arrostando preliminares ou circunstâncias outras que dizem respeito a eventuais momentos preambulares do exame do mérito.

Entendo caber diretamente ao exame do tema, que traduz uma controvérsia presente e importante para este Tribunal, para o Poder Judiciário e para a própria sociedade brasileira. E, em síntese, Senhor Presidente, eminentes Pares, estamos diante de um problema jurídico e duas soluções que para enfrentá-lo se apresentam.

O problema jurídico é a controvérsia entre o caráter comum, sucessivo do prazo das alegações finais entre defesa de corréu que não tenha celebrado negócio jurídico da colaboração e defesa de corréu que tenha celebrado negócio jurídico da colaboração.

De um modo geral, quem sustenta que a posição do corréu delatado não colaborador, tendo em vista a carga acusatória da qual a colaboração revestir-se-ia, é uma posição que implica um delta diferenciado em relação à posição dos demais corréus, o que este raciocínio encontra, ao fim e ao cabo, no seu fundamento é aquilo que já restou muitas vezes denominado como Estatuto Constitucional da Ampla Defesa e da Garantia do Contraditório.

Ou seja, a solução para o problema, à luz dessa resposta, encontraria densificação para o caso concreto com a projeção direta e imediata de princípios e regras, portanto, normas constitucionais, a partir das quais se extrairiam fundamentos suficientes para essa diferenciação entre corréus, nada obstante não exista na legislação infraconstitucional regra expressa, mas essa densificação decorreria de uma projeção direta e imediata da eficácia dos princípios e regras constitucionais.

A outra resposta que procura se apresentar ao problema é a de

HC 166373 / PR

evidenciar que se está diante de um debate entre prazo comum ou sucessivo que não diz respeito a acusação e defesa, mas, sim, entre defesa e defesa. Vale dizer, entre corréus, e que, no ordenamento jurídico brasileiro, quer da ordem constitucional ou mesmo na ordem infraconstitucional, não se coloca esse caráter sucessivo entre as respectivas manifestações ou alegações finais.

Portanto, o que se tem em exame, em resumo, é se a adoção pela via negocial de postura colaborativa - e aqui já me permito utilizar a expressão postura colaborativa, porque não se está a debater se há atividade de colaboração ou negócio jurídico de colaboração, que é um outro debate que quiçá espera esse Tribunal, mas, no caso concreto, houve o negócio jurídico de colaboração de qualquer modo -, portanto, na existência de um acordo de colaboração, a partir de determinada linha de defesa, repercute ou não de forma obrigatória esta linha de defesa que implica atividade de colaboração, via negócio jurídico de colaboração, produz reflexos na ordem de apresentação das alegações finais.

Logo, em meu modo de ver, não se questiona aqui eventual inversão da ordem dos atos que veiculam pretensão acusatória, cenário que até em tese poderia comprometer o princípio da correlação e a estabilidade que deve densificar ou se concretizar nas demandas penais que veiculem pleitos de natureza condenatória.

25/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 1. Senhor Presidente, ilustres pares, de saída cumpre contextualizar a matéria trazida à colação deste colegiado maior.

1.1. A questão de fundo diz respeito à controvérsia entre o caráter **comum ou sucessivo** do prazo de alegações finais **entre defesas** de acusados que celebraram acordo de colaboração premiada e de acusados que não firmaram negócio jurídico processual dessa natureza.

O que se tem em exame, em verdade, é se a adoção, pela via negocial, de postura colaborativa, a partir de determinada linha de defesa, repercute, ou não, de forma obrigatória, na ordem das alegações finais colhidas.

Ou seja, não está se discutindo o caráter sucessivo entre as manifestações de acusação e defesa, mas sim entre defesa e defesa, a depender da estratégia e das peculiaridades do exercício do múnus defensivo concretamente considerado.

1.2. Igualmente não se questiona eventual inversão da ordem de atos que veiculam pretensão acusatória, cenário que, em tese, poderia até mesmo comprometer o princípio da correlação e a estabilidade que deve caracterizar as demandas penais que veiculam pleitos condenatórios.

Tampouco se afirma a ocorrência de vícios processuais que eventualmente tenham alcançado atos instrutórios mas, tão somente, emerge temática afeta a atos processuais posteriores ao encerramento da fase probatória.

Também não se alega a extemporânea produção de provas em fase de alegações finais.

A higidez processual de exibição de elementos probatórios

HC 166373 / PR

desacompanhada de oportunidade de impugnação por quaisquer acusados, é cenário não retratado nesta impetração.

1.3. Cabe mencionar ainda que, no caso concreto, a ação penal de origem insere-se na espacialidade da cognominada “Operação Lava Jato”. Nada obstante, não estão em pauta apenas feitos da aludida investigação.

Ao contrário, há questão jurídica subjacente, em tese, com potencial repercussão em contexto jurídico de maior amplitude.

Com efeito, a matéria trazida à deliberação do Tribunal Pleno vincula-se à própria definição, à luz da ordem normativa, do rito processual aplicável aos casos em geral que envolvam corréus que firmaram acordo de colaboração premiada.

Esse cenário, como se nota, desborda da realidade processual experimentada nos autos de origem, sinalizando possível interferência em outras apurações de crimes perpetrados no contexto de organizações criminosas e que, nos termos do estabelecido na Lei n. 12.850/13, tenham pena máxima superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional, ambiência na qual se incluem diversos crimes contra a Administração Pública, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, pornografia infantil, praticados com violência ou grave ameaça, entre outros.

1.4. Também não se discute que inexistente *regra* processual que assegure **expressamente** a postulada ordem sucessiva de manifestações defensivas. Não há lei expressa, no ordenamento normativo infraconstitucional, que sustente a tese da impetração.

O cerne da discussão, ao revés, gravita em torno da alegação de que essa sustentada cronologia configuraria decorrência implícita e necessária dos princípios constitucionais que desvelam o estatuto constitucional do direito de defesa.

1.5. Mais do que isso, e enfatizo esse ponto, cabe ponderar que se trata de julgamento de *habeas corpus*, remédio processual cuja expressa

HC 166373 / PR

destinação constitucional (art. 5º, LXVIII, CRFB) é a tutela do direito de locomoção atingido ou ameaçado **“por ilegalidade ou abuso de poder”**.

A controvérsia ora posta, portanto, não reside, ao menos num primeiro plano, na definição de qual forma de concessão de prazo para apresentação de alegações finais seria mais desejável sob a perspectiva do exercício do direito de defesa. A matéria, ao revés, em essência, diz com a eventual caracterização de **ato configurador de constrangimento ilegal**.

Vale dizer, as instâncias antecedentes, ao propiciarem a apresentação de alegações finais das defesas em prazo comum, praticaram ato jurisdicional suscetível de ser considerado ilegal ou configurador de abuso de poder?

Haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir regra legal expressa que não existe? Haveria ilegalidade ou abuso de poder ao não se cumprir interpretação constitucional até então inexistente?

2. O cerne da alegação defensiva é que as alegações finais apresentadas por colaborador premiada conteriam carga acusatória e, nessa perspectiva, deveriam submeter-se a prévia possibilidade de ciência e reação do delatado, sob pena de necessária declaração de nulidade processual.

Calha assinalar que este Tribunal Pleno já decidiu que a colaboração premiada não constitui prova em si, mas meio de obtenção de prova. Nesse sentido: Inq 4130 QO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015.

Na mesma linha, cito segmento do voto proferido pelo saudoso Min. Menezes de Direito, proferido no HC 90688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/02/2008 (*grifei*):

“A minha convicção é que, em primeiro lugar, o acordo de delação premiada não é prova. Estou absolutamente convencido de que é apenas um caminho, um instrumento para que a pessoa possa colaborar com as investigação criminal, com o processo de apuração dos delitos.”

HC 166373 / PR

Por consequência, a carga probatória das declarações prestadas pelo colaborador é reduzida, não dispensando, para fins de reconstrução histórica de determinado fato tido como ilícito, a presença de elementos de corroboração.

Nesse sentido, aliás, depreende-se a existência de decisões proferidas na ambiência desta Corte no sentido do não recebimento de denúncias ancoradas exclusivamente em declarações prestadas por colaboradores judiciais.

Na mesma linha, a Lei n. 12.850/13 é expressa ao vedar condenações com base exclusiva em declarações de colaboradores, prescrição que, aliás, a tudo se amolda ao tradicionalmente estabelecido por esta Suprema Corte na perspectiva da intitulada chamada de *corréus* (quando, fora de um contexto premial, um réu atribui determinada responsabilidade a um *corréu*). Nesse sentido, confira-se: RHC 81740, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 29/03/2005 e HC 85457, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/03/2005.

Assim, eventuais afirmações constantes das alegações finais - apresentadas pela defesa técnica de agente colaborador, e não pessoalmente pelo agente -, ainda que eventualmente dirigidas a atribuir responsabilidade penal ao acusado não colaborador, não traduzem, por si só, carga acusatória ou potencial demonstrativo probatório relevante.

Obviamente, a exibição de elementos de corroboração em sede de alegações finais ou até mesmo nova atribuição de responsabilidade poderiam, quiçá, conduzir a resultado diverso. **Mas não é disso que ora se cuida.**

Nesse particular, reafirme-se, não se questiona nestes autos a regularidade da fase probatória, até porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a colaboração premiada não constitui, por si, meio de prova, mas meio de obtenção de prova.

Suscita-se, ao revés, que a contribuição na *iniciativa* probatória por meio da implementação de meio de obtenção de prova energizada por agente colaborador interferiria, em momento posterior à fase instrutória,

HC 166373 / PR

na ordem de apresentação de alegações finais entre as defesas dos corréus.

3. Saliento que a possibilidade de implementação de colaboração premiada não constitui novidade no ordenamento jurídico nacional.

Ao contrário. Diversos diplomas normativos anteriores à Lei n. 12.850/13 já previam a possibilidade de concessão de sanção premial correspondente a determinada postura colaborativa.

Ilustrativamente, cito o art. 159, §4º, Código Penal, o art. 25, §2º, da Lei 7.492/86, o art. 16 da Lei n. 8.137/90, o art. 6º da Lei n. 9.034/95, o art. 1º, §5º, da Lei n. 9.613/98, os arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99 e o art. 41 da Lei n. 11.343/06.

Como se vê, todas essas normas são anteriores até mesmo à Lei n. 11.719/08, que alterou o procedimento da ação penal disciplinado pelo Código de Processo Penal.

Nesse contexto, com a devida vênia, não são precisas as observações que atribuem a controvérsia acerca da ordem de alegações finais entre corréus colaboradores e não colaboradores ao advento da Lei n. 12.850/13.

Embora reconheça-se que a matéria tenha recebido tratamento procedimental mais detalhado pela Lei n. 12.850/13, trata-se, em verdade, de realidade já vivenciada ao tempo em que editada a reforma normativa da instrução processual penal, desencadeada pela citada Lei n. 11.719/08.

A respeito da matéria, cumpre observar que, após a mencionada reforma processual introduzida pela Lei n. 11.719/08, as alegações finais devem ser oferecidas, em regra, de modo oral.

Acerca da ordem de apresentação, o Código de Processo Penal cingiu-se a contemplar que as alegações principiam pela acusação e, em seguida, propicia-se a oitiva da defesa.

Naturalmente, seguindo a regra geral de apresentação de alegações orais, ocorrendo litisconsórcio passivo, não se verificará concomitância na explicitações das razões defensivas. É que, obviamente, a sobreposição de manifestações orais não se coaduna com a necessária ordenação do processo. Portanto, embora se trate de prazo comum, é da natureza do

HC 166373 / PR

procedimento processual penal a impossibilidade prática de apresentação simultânea de alegações finais defensivas orais.

A legislação, contudo, não disciplinou imposição de ordem de colheita das argumentações de cada defesa, tampouco potencializou, para esse escopo, eventual adoção, ou não, de postura colaborativa. Poderia tê-lo feito e até hoje não o fez. Não deve o Judiciário legislar, em hipótese alguma.

O CPP ainda preconiza que eventual assistente de acusação manifestar-se-á após o Ministério Público e antes da defesa. Assinala-se, outrossim, que a complexidade do caso poderá legitimar a apresentação das alegações finais em forma de memoriais.

Confira-se:

“Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas **alegações finais orais** por 20 (vinte) minutos, **respectivamente, pela acusação e pela defesa**, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

§ 2º **Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse**, serão concedidos 10 (dez) minutos, **prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.**

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, **conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais.** Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.”

Observe-se que a lei processual diferencia expressamente os momentos de manifestação do Ministério Público, do assistente do Ministério Público e da defesa. **Não distingue, entretanto, o momento de participação entre as defesas em razão de eventual adoção de postura colaborativa por parte de acusados.**

HC 166373 / PR

Ao contrário, na medida em que a legislação processual penal inadmite, expressamente, que corréu possa intervir como assistente de acusação:

“Art. 270. O co-réu (sic) no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.”

Em outras palavras, a despeito da prévia consolidação normativa da possibilidade de realização de colaborações premiadas, **o Código de Processo Penal não fez qualquer distinção baseada na estratégia defensiva adotada por cada acusado.**

Isso porque, naturalmente, o corréu, ao exercitar seu direito de defesa, não veicula propriamente pretensão acusatória, cingindo-se a desencadear atividade reativa em face do titular da ação penal, considerada como oposição à imputação ou como postulação direcionada à implementação de determinada sanção premial previamente estipulada.

Também cabe pontuar que **a Lei n. 12.850/13, sabidamente familiarizada com o instituto da colaboração premiada, igualmente, não disciplina a ordem de apresentação de alegações finais defensivas de modo diferenciado entre agentes colaboradores e não colaboradores.**

Vale dizer, tanto a norma geral do CPP quanto a norma específica da Lei n. 12.850/13 não agasalham a pretensão ora veiculada.

O que se sustenta nesta impetração é que, a despeito da inocorrência de alicerce normativo expresso, a ordem sucessiva de alegações finais entre defesas de agentes colaboradores e não colaboradores configuraria consectário implícito da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionalmente asseguradas como decorrência do devido processo legal. Repita-se: não há lei infraconstitucional que assegure esse direito e ao menos até a data de hoje não há manifestação plenária deste STF sobre a matéria.

4. Aduz-se que as alegações finais apresentadas pela defesa de agentes colaboradores conteriam carga acusatória, razão pela qual, a teor do art. 5º, LV, CRFB, deveria ser assegurada prévia ciência ao agente

HC 166373 / PR

implicado, permitindo-se, inclusive, a respectiva atividade reativa.

Acerca do contraditório, Antonio Scarance Fernandes atesta que *“são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação”*, de modo que o referido princípio abarca o **dizer e o contradizer**. Complementa o autor que *“não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los”*, bem como que *“o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática”* (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65).

Afirma-se ainda que a garantia do contraditório *“vai além do conhecimento do alegado e da reação à acusação e às alegações contrárias, abarcando a perspectiva de influir no processado e no próprio decisum”*. (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica, 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 163, *grifei*).

Essas ponderações, no processo penal, guardam íntima relação com o ônus da prova que, em linhas gerais, confere ao titular da ação penal a tarefa de desconstituição do estado de inocência presumido do acusado.

Assim, sobretudo diante da perspectiva substancial do contraditório e da instrumentalidade e funcionalidade das formas processuais, o que, a meu ver, deve ser examinado, é a efetiva existência de explicitação acusatória que não tenha sido submetida a possível antítese defensiva e que, simultaneamente, tenha influído de alguma maneira no resultado processual.

5. Não se desconhece que a atuação do colaborador, de fato, guia-se comumente pelo anseio da concessão de benefícios. A implementação da sanção premial, nada obstante, segundo já se sinalizou neste Plenário, não se condiciona ao êxito da pretensão acusatória. Vale dizer, se o colaborador adimplir suas obrigações negocialmente assumidas, não é eventual improcedência da acusação que esvaziará, automaticamente, os benefícios avençados.

HC 166373 / PR

Em outras palavras, a concessão de benefícios em favor do colaborador não depende, necessariamente, da condenação de quaisquer corréus.

Na linha da ausência de necessária vinculação entre a concessão de sanções premiais e o resultado do exame do mérito de eventual acusação, colho a seguinte lição:

“Nesse contexto, pode ocorrer que o colaborador apresente sua narrativa e os documentos de corroboração dos quais disponha, mas uma instrução deficiente – seja por desídia dos investigadores, seja pela dificuldade de angariar mais elementos de provas diante de certos contextos – leve o magistrado a entender que os fatos trazidos aos autos não são suficientes para ensejar a condenação de um ou mais réus. (...) **O ônus de levar a cabo a investigação é do Estado. Sua capacidade apuratória não pode afetar os benefícios propostos, decorrentes de uma valoração positiva do material apresentado, feita por seus próprios agentes em um momento inicial.**

O colaborador não pode ficar à mercê da competência ou incompetência dos responsáveis pela investigação ou dos desdobramentos sempre imprevisíveis do processo apuratório. **Se fez sua parte, manteve sua versão e apresentou indícios e elementos reconhecidos como relevantes, fará jus ao benefício, ainda que as apurações não sigam adiante.”** (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A homologação e a sentença na colaboração premiada na ótica do STF. In Colaboração premiada (org. Pierpaolo Cruz Bottini e Maria Thereza de Assis Moura). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 198, *grifei*)

Em idêntico sentido, Pierpaolo Cruz Bottini também menciona na citada publicação segmento de voto proferido oralmente pelo eminente Min. Celso de Mello, na Pet 7074 QO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017. Aponto, nesse sentido, as sempre

HC 166373 / PR

percucientes lições do eminente decano:

“(…) há situações em que o agente colaborador procede ao adimplemento integral de suas obrigações, age, não é, de maneira muito clara, procede ativamente, colabora com os órgãos incumbidos da persecução penal e muitas vezes, por falha do aparelho de Estado, por falha da polícia judiciária, por falha do Ministério Público, os resultados pretendidos não são atingidos.”

Prossegue o professor Pierpaolo Bottini:

“Embora o Ministro ressalve ao final que tal matéria ainda merece mais reflexões, parece clara sua inclinação à admissão dos benefícios acordados quando o insucesso das investigações decorre da conduta estatal ineficiente.”

Complementando o ponto, transcrevo segmento de voto proferido na aludida assentada pelo eminente Min. Alexandre de Moraes:

“A colaboração premiada é estipulada pelas partes em consenso, há um controle jurisdicional formal pelo Relator, que pode somente analisar conveniência dentro do juízo de legalidade. Uma vez eficiente essa colaboração, na decisão judicial, no caso, aqui, no acórdão, o órgão colegiado analisará se foi eficaz, eficiente, e, como bem lembrou o Ministro Celso, **quais pontos não foram obtidos e se foi culpa do agente colaborador ou não.**” (Pet 7074 QO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2017, *grifei*)

Como se vê, a compreensão desta Corte inclina-se no sentido de que, de fato, a sanção premial não é dependente ou condicionada a um provimento condenatório.

Em idêntico sentido, doutrina defende expressamente que:

“(…) a eficácia não significa dizer que o Ministério

HC 166373 / PR

Público deva ter êxito nos processos que intentar contra os coautores expostos ou delatados. O que realmente importa é que o colaborador tenha prestado seu depoimento de forma veraz e sem reservas mentais sobre todos os fatos ilícitos de que tenha conhecimento, colaborando de maneira plena e efetiva.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. Salvador: JusPodivm. 2017, p. 715, *grifei*)

Nesse sentido, depreendo que o interesse jurídico do colaborador, no momento da celebração do respectivo acordo, até pode vincular-se mais intensamente a um ânimo de heteroinculpação.

Nada obstante, após a constituição do acordo, o agir processual do colaborador é visivelmente afeito à demonstração de que adimpliu seus deveres negocialmente estabelecidos e menos relacionado ao resultado da ação penal. Esse, aliás, é precisamente o caso dos autos, conforme se verá adiante com maior detalhamento.

Não há, por assim dizer, mormente na fase de alegações finais, comprometimento do colaborador com a tese acusatória, de modo que, sequer em tese, o colaborador funciona como assistente do Ministério Público (na linha, aliás, do expressamente vedado pelo já citado art. 270 do CPP).

A rigor, portanto, permanece sendo do titular da ação penal, e não do colaborador, o ônus processual da desconstituição do estado de inocência presumido dos corréus.

Incumbe ao colaborador a demonstração de que cumpriu com as obrigações negocialmente assumidas com o Ministério Público. Nesse sentido, ao invés de assistente da acusação, o colaborador é comumente alvo de potenciais tensões com o próprio *dominus litis*, na medida em que almeja evidenciar o adimplemento do pacto processual, cenário não imune a dissensos.

Cabe sopesar ainda que a ordem de apresentação de alegações finais entre acusação e defesa, além da distribuição do ônus da prova no direito processual penal, considera um natural desequilíbrio entre as forças persecutórias e o cidadão. Parte, portanto, da hipossuficiência processual

HC 166373 / PR

do acusado.

A prerrogativa de oitiva após a manifestação da acusação, nessa perspectiva, funciona como um modo de tentativa de se estabelecer mínimo equilíbrio de forças no processo penal.

Em outras palavras, além da questão atinente ao ônus da prova, a garantia de oitiva posterior da defesa, em razão das características e prerrogativas das forças persecutórias, traduz o implemento da necessária substancial paridade de armas **entre as partes contrapostas**.

Essa lógica não se transporta mecanicamente à espacialidade da colaboração premiada. Isso porque a colaboração, longe de refletir o poderio do agente colaborador, representa uma das possíveis formas de exercício da ampla defesa, que se exercita não apenas em oposição à pretensão acusatória mas, inclusive, sob o viés da pretensão de alcance de sanção premial.

A propósito, especificamente quanto à viabilidade de emprego do modelo colaborativo como instrumento de estratégia de defesa, afirma a doutrina:

“Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os quais se insere a colaboração premiada, ele nada mais faz do que exercer efetivamente o seu direito à ampla defesa (...).

Ora, sabe-se que **a ampla defesa não se realiza apenas com a tese de negativa de autoria**. Há casos em que é tida como estrategicamente correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma redução de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou substituição por pena restritiva de direitos, deixando, inclusive, de apelar da sentença condenatória.” (FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134, *grifei*)

E ainda:

“A opção pela colaboração premiada, sem meias

HC 166373 / PR

palavras, é um dos caminhos que o acusado pode eleger, logo, enquanto tal, é manifestação da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República) a depender das novas provas carreadas pelo Estado contra o acusado, a tornar a condenação mais do que visível no horizonte, **a delação mostra-se a estratégia capaz de minorar a punição, ou, a depender do caso, evitá-la**. Eliminar do ordenamento essa alternativa reduziria o cardápio de linhas de defesa à disposição do acusado e do seu defensor, importando involução no exercício da ampla defesa, em descompasso com um dos critérios de hermenêutica constitucional vedação do retrocesso.” (SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p. 75, *grifei*).

De tal modo, a colaboração premiada insere-se no catálogo de meios, em tese, inerentes ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido aos acusados em geral (art. 5º, LV).

Nessa perspectiva, o legítimo manejo de meio atinente à ampla defesa não autoriza, a meu ver, distinção entre as manifestações defensivas igualmente asseguradas aos colaboradores e não colaboradores, sob pena de indevida categorização cerceadora do devido processo legal.

Em outras palavras: a adoção de certa estratégia defensiva não funciona como causa determinante da ordem de manifestação processual de cada acusado.

Essa realidade, a propósito, já se verifica, em geral, na hipótese de chamada de corréus. Vale dizer, nos casos em que determinado réu, com ânimo de autoexculpação, atribui determinada conduta a corréu, não se cogita de caráter sucessivo para o prazo de alegações finais.

Cumprе enfatizar que tanto a colaboração premiada quanto a chamada de corréu possuem similar conteúdo em relação ao implicado pelas declarações. Vale dizer, em ambos os casos o corréu imputa a terceiro a prática de determinado ato narrado na peça acusatória.

Em tais casos, a esfera jurídica do implicado é atingida em idêntica dimensão. O que há de distinção, na minha compreensão, é que, na

HC 166373 / PR

hipótese de colaboração premiada, há perspectiva de concessão de sanção premial, enquanto que, na chamada de corrêu, o cerne do agir geralmente reside na pretensão de absolvição ou outro resultado processual benéfico que não se enquadre propriamente como um benefício negociado.

Ou seja, a colaboração premiada e a chamada do corrêu afetam a esfera jurídica do imputado de idêntica maneira, cabendo distinção tão somente quanto aos objetivos que motivam cada uma dessas posturas.

O acolhimento da tese defensiva, portanto, em tese, poderia autorizar prazos sucessivos inclusive na hipótese de chamada de corrêus. Mais do que isso, ainda em tese, geraria verdadeiro impasse em caso de recíproca chamada de corrêus. Nessa medida, nos casos de chamada de corrêus, como conciliar a pretendida ordem sucessiva em casos em que há imputação recíproca por parte de acusados?

Além disso, em tais casos, o acolhimento da pretensão ora veiculada pela defesa, ao que parece, poderia até mesmo exigir inversão lógica das etapas de propositura, admissão, produção e valoração da prova.

Vale dizer, incumbiria ao Estado-Juiz a prévia avaliação da estratégia defensiva, delimitando-se cada réu que eventualmente atribua determinado fato a outro corrêu, para, em seguida, definir-se a ordem de atuação dos sujeitos processuais. Atuação que, ao fim e ao cabo, direciona-se a influenciar o convencimento do julgador que, em definitivo, apenas se consolida após a plena participação das partes.

Destarte, exigir-se-ia do julgador prévio exame, ainda que superficial, das teses e estratégias defensivas, efetivas ou potenciais, e, em seguida, seria definida a ordem de manifestação das defesas. Manifestações a serem veiculadas com a perspectiva de influenciar a formação do até então não formado convencimento do julgador. Essa circunstância, a meu ver, poderia colocar em xeque a própria imparcialidade jurisdicional.

Nessa perspectiva, concluo que, após a celebração de acordo e colheita das provas por ele indicadas, a atuação processual do colaborador não desencadeia, por si só, efeito acusatório ou probatório relevante. O ânimo do colaborador, em tais cenários, reside

HC 166373 / PR

precipuamente na demonstração ao Estado-Juiz de que se verificou o adimplemento do negócio jurídico processual previamente estabelecido e judicialmente homologado, circunstância que não se condiciona ao êxito da pretensão acusatória.

O que é de relevo, portanto, não é o resultado da ação penal, mas o exame da efetiva e concreta atividade colaborativa.

Diante do exposto, incorrente veiculação de manifestação acusatória insuscetível de antítese defensiva, não se verifica, a meu ver, a nulidade arguida pela defesa.

6. Como se vê, a observância de prazo comum para colheita de alegações finais dos acusados colaboradores e não colaboradores não configura constrangimento ilegal.

A título de reforço, cabe ponderar que, mesmo que eventualmente se reconhecesse ilegalidade decorrente desse proceder, a configuração de nulidade processual, como se sabe, subordina-se à existência de prejuízo que legitime sua proclamação. Caberia, portanto, examinar a eventual repercussão da cogitada ilegalidade na validade da marcha processual.

Com efeito, a forma processual, mais do que fim em si mesmo, constitui meio de tutela de interesses jurídicos que integram o devido processo legal. Nessa perspectiva instrumental, o exame jurisdicional não deve se resumir à aferição de eventual inobservância de determinadas formalidades processuais, cabendo avaliar ainda a efetiva vulneração aos valores protegidos por essas prescrições.

Nessa linha, aponta a doutrina que:

“A partir da Constituição e dos direitos e garantias por ela assentados, o controle da forma dos atos processuais se apresenta intrinsecamente ligado ao princípio do devido processo legal, o qual tem por objetivo a proteção da ampla defesa, do contraditório e do próprio sistema acusatório.

(...) **no âmbito do estudo das nulidades do processo penal, o que deve ser analisado é a eficácia do direito fundamental que a forma tutela.**” (VASCONCELLOS, Vinicius

HC 166373 / PR

Gomes; SAAVEDRA, Giovani Agostini. Nulidades no processo penal: em busca de novas premissas. In Temas de ciências criminais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2013, p. 111/130, *grifei*).

Nesse sentido, o procedimento é concebido como meio de tutela e concretização do devido processo legal e, no caso concreto, mais especificamente, de salvaguarda do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Em outras palavras, o que deve ser verificado é a eficácia ou ineficácia do interesse jurídico subjacente que a forma processual tutela.

Também calha sopesar que a ausência de prejuízo, a rigor, não funciona como causa saneadora ou meio de convalidação de nulidades. Ao revés, a existência de prejuízo atua como circunstância essencial à própria configuração da nulidade, perspectivas que devem ser sopesadas pelo Estado-Juiz no momento do juízo de sua decretação.

Acerca da existência de prejuízo como condicionante à configuração de nulidade (*pas de nullité sans grief*), colhe-se expressa previsão do Código de Processo Penal:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A verificação da ocorrência de prejuízo figura, pois, como projeção do princípio da instrumentalidade que guia o regime jurídico das nulidades processuais.

Nessa linha, a jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a *“demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”* (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005, *grifei*).

Dessa compreensão não destoa a doutrina. Cito, a esse respeito,

HC 166373 / PR

segmento de clássica obra atinente à matéria:

“(...) seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”
(GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 31, *grifei*)

Na mesma direção, ainda prescreve o CPP (*grifei*):

“Art. 566. Não será declarada a nulidade de **ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”**

Em sentido semelhante colhe-se o verbete 523 da súmula do STF, por meio do qual se enuncia o seguinte:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

Como corolários do princípio do prejuízo em matéria de nulidades, cabe ainda examinar as facetas atinentes ao interesse e causalidade (ou consequencialidade).

Com efeito, o gravame gerado a partir da alegada nulidade não se traduz, simplesmente, a partir da existência de um provimento condenatório. É imperioso que o interessado evidencie certo nexos causal entre a suposta irregularidade e a vulneração ao devido processo penal ou o resultado da ação penal.

Especificamente nesse enfoque, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho apontam que:

HC 166373 / PR

“(...) a decretação da invalidade do ato praticado de forma irregular, com sua consequente renovação, segundo o modelo legal, **deve estar igualmente sujeita a uma apreciação sobre as vantagens que a providência possa representar para quem invoque a irregularidade.**” (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 34, *grifei*)

Na mesma linha aponto precedente de lavra do saudoso Min. Teori Zavascki, em que Sua Excelência assentou o seguinte:

“Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, **o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado.** Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, *grifei*)

Diante da controvérsia ora em exame, portanto, se se chegasse a esse ponto, caberia a demonstração da específica utilidade da postulada renovação de atos processuais.

Vale dizer, seria o caso de indicação de qual afirmação com conteúdo acusatório ou elementos probatórios não foram suscetíveis de potencial impugnação por parte da defesa do paciente. Em outras palavras, desvela-se indispensável a aferição de eventual inobservância de ciência bilateral de determinado ato processual, bem como a impossibilidade de, a tempo e modo, explicitação de manifestação contrária.

Consigno que, até mesmo em casos mais graves, nos quais houve efetiva inversão entre manifestações das partes, com precedência de atuação da defesa e subsequente agir acusatório, esta Suprema Corte não tem conferido caráter absoluto à garantia da última palavra pela defesa, tampouco tem se dispensado a demonstração de prejuízo para fins de

HC 166373 / PR

nulificação de atos processuais.

A esse respeito, a título ilustrativo, cito que, em *habeas corpus* submetidos a esta Suprema Corte, tem-se atribuído voz à defesa em sede de sustentação oral **com posterior manifestação da PGR**. Com efeito, mesmo que se considere que, em tais casos, o Ministério Público oficia na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tenho que esse cenário infirma a tese do cogitado absoluto direito subjetivo da defesa à manifestação após a colheita de todos os argumentos potencialmente contrários a seus interesses.

Registro ainda que, em diversos precedentes, a Corte não reconheceu constrangimento ilegal em casos que contaram com manifestação defensiva seguida de atuação da acusação.

Ou seja, mesmo nas hipóteses em que há inversão entre as atuações de acusação efetiva e defesa, ou seja, em que há real contraposição de partes (cenário que ora não se coloca, eis que, como dito, o colaborador não integra o polo acusatório da relação processual), o STF tem implementado análise à luz da concreta verificação de prejuízo a legitimar a proclamação da nulidade. Confira-se:

“*HABEAS CORPUS*. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE SUSCITADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (*pas de nullité sans grief*). Precedentes. 2. **A manifestação do Ministério Público, apesar de posterior às alegações finais da defesa, abarcou exclusivamente questões de Direito, as quais já haviam sido articuladas pela defesa e sobre as quais o magistrado poderia ter-se manifestado de ofício. Inexistência de prejuízo.** 3. *Habeas corpus* denegado.” (HC 130433, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, *grifei*)

HC 166373 / PR

“(…) quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa.” (RHC 104261, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, *grifei*)

“AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 137772 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, *grifei*)

Em linha semelhante, mas equacionando questão atinente à inversão na seara probatória, a Corte também condicionou o reconhecimento da nulidade à demonstração de prejuízo:

“*HABEAS CORPUS*. PROCESSO PENAL. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. NULIDADES. A nulidade parcial do processo, por inversão da ordem processual, só deve ser reconhecida se causar prejuízo à parte. No caso, a aludida inversão não ocorreu, e mesmo que se entendesse ter havido, seria em decorrência de questões preliminares suscitadas pela defesa. Houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. *Habeas* conhecido e indeferido.” (HC 78245,

HC 166373 / PR

Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, *grifei*)

Em hipótese diversa, qual seja, na ambiência de atos contraditórios da defesa, a Corte também não chancelou a nulidade postulada:

*“Habeas corpus. 2. Nulidade. **Inversão da ordem de apresentação das alegações finais**. Não ocorrência. 3. Defesa que convergiu para ocorrência da suposta nulidade, porquanto se antecipou à intimação legal, a fim de apresentar suas alegações finais. 4. **Ordem denegada.**”* (HC 108476, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, *grifei*)

Embora, como dito, a matéria subjacente ao indicado precedente realmente seja diversa, cabe assinalar que o Tribunal, no caso concreto mencionado, ao verificar que a defesa teria concorrido para a irregularidade, não reputou presente constrangimento ilegal, a corroborar, na minha óptica, que eventual inobservância da cogitada ordem de manifestação processual não gera, como consequência necessária, a invalidação processual.

A seguir, passo a examinar essa questão especificamente no caso concreto.

7. No caso concreto, verifico que a ilustre defesa sequer alega que a ordem entre as alegações finais apresentadas pelas respectivas defesas de agentes colaboradores e não colaboradores teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo ao exercício do contraditório, cingindo-se a argumentação, no campo da generalidade, ao apontamento de que a concessão de prazo comum para apresentação de alegações finais de acusados colaboradores e não colaboradores configuraria constrangimento ilegal.

Anoto que **não se trata de impor à defesa a demonstração, por exemplo, de que seria absolvida em caso de observância da ordem**

HC 166373 / PR

processual sucessiva que entende adequada. O que se pontua é que caberia a indicação de que, no caso concreto, apenas essa cronologia concretizaria o devido processo legal.

Em outras palavras, **caberia ao impetrante o apontamento de qual tese, argumento ou elemento probatório não teria, em razão da ordem processual adotada, sido possível de oposição oportuna.**

Nada obstante, enfatizo que não se indica que se deixou de franquear à defesa a narrativa acusatória, possíveis teses ou argumentos, as provas amealhadas ou eventuais elementos de corroboração das atividades colaborativas desencadeadas no transcurso da ação penal.

Tampouco se articula que as alegações oferecidas pela defesa de colaborador conteve argumentos inovadores em relação às etapas processuais anteriores ou não passíveis de oportuno enfrentamento.

O ponto central da questão, portanto, é a efetiva observância substancial, ou não, do contraditório, aspecto cuja vulneração a defesa não logrou demonstrar para fins de se reputar presente causa de constrangimento ilegal. **O que se evidenciou, ao revés, é a plena preservação do exercício do contraditório.**

A ausência de inovação a partir das alegações finais do colaborador já havia sido enaltecida na sentença:

“77. Não há falar sequer em cerceamento de defesa, pois os acusados colaboradores foram interrogados sob exame cruzado no momento próprio e mesmo antes as Defesas dos demais acusados já sabiam o que eles em geral tinham a dizer em seus depoimentos, já que a denúncia foi instruída com cópia de seus depoimentos prestados nos acordos de colaboração (evento 1, anexo15, anexo19, anexo20 e anexo32).

(...)

82. A Defesa de acusado colaborador não equivale à Acusação, sendo posições processuais distintas.

83. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer hierarquia entre Defesas e acusados. O prazo é comum para alegações finais de todos os defensores.

84. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base

HC 166373 / PR

em interpretações criativas.”

Esse cenário foi reafirmado nestes autos nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:

“Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada julgou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado.

Não há na alegações finais destes réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo.”

Cumprе frisar que sequer há indicação, por exemplo, de que segmentos veiculados nas alegações finais do colaborador tenham sido sopesados como fonte de convencimento do Juízo ou que tenham concorrido para a formulação do édito condenatório.

A propósito, verifico que as alegações finais apresentadas pelo colaborador EDISON KRUMMENAUER centram-se em alegações de cunho genérico e no esforço de demonstração específica de adimplemento do acordo firmado com o Ministério Público. Em argumentação sintética em consideração às peças das demais defesas, apontou-se que (*grifei*):

“Em diversas passagens de suas alegações finais, o Ministério Público Federal reconheceu a relevância da contribuição dada por Edison na revelação dos fatos descritos na denúncia e, sobretudo, afirmou a corroboração dos elementos probatórios indicados pelo defendente quando levou tais episódios ao conhecimento da acusação pública.

HC 166373 / PR

(...)

Como retrato da extensão da abrangência e da relevância do seu discurso, merece ser mencionada a quantidade de vezes em que o teor do interrogatório judicial de Edison foi reproduzido na argumentação final do Ministério Público Federal, a demonstrar a procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia.”

Ao final, a defesa do colaborador cingiu-se a postular a concessão de sanção premial ao acusado, **não formulando qualquer pleito condenatório em relação a corréus**, inclusive o ora paciente.

Assim, a defesa teve acesso integral à imputação e eventuais elementos probatórios, descabendo proclamar nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual.

Registro ainda que, no caso concreto, defesas de **não** colaboradores teriam apresentando novos documentos em sede de alegações finais. Embora o Juízo tenha reputado inoportuna a produção probatória nessa fase, propiciou manifestação, ainda que restrita a esse ponto, às defesas de todos os acusados. Nada obstante, nos termos das informações prestadas pelo Juiz da causa, as defesas dos *“réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira optaram por não complementarem suas alegações finais.”* Como se vê, nem houve manifestação adicional, como facultado.

Esse cenário, a meu ver, bem depõem em favor da condução processual pautada pelo respeito substancial ao exercício do contraditório assegurado aos acusados.

Por fim, saliento que a observância de ordem sucessiva no momento dos interrogatórios judiciais (na fase probatória, portanto), ao invés de fortalecer a tese defensiva, robustece a demonstração de plena observância do direito de defesa do paciente. Com efeito, a autodefesa, nessa espacialidade, foi plenamente assegurada, na medida em que possibilitada prévia ciência e oportuna reação em face das declarações (logo, com conteúdo depoimento) prestadas pelos colaboradores na etapa instrutória.

HC 166373 / PR

8. Diante do exposto, considerando a ausência de constrangimento, bem como a inocorrência de prejuízo decorrente da alegada irregularidade, **voto pela denegação da ordem.**

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Procurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:

Trata-se de *Habeas Corpus*, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RHC 96.059/PR, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.

Retratam os autos, em síntese, que, **em 8/6/2017**, o paciente foi denunciado pela prática das condutas previstas no art. 2º, c/c, § 4º, II, III, IV e V, da Lei 12.850/2013; no art. 317, § 1º, c/c art. 29 e art. 327 do Código Penal; e no art. 1º, *caput*, c/c § 4º da Lei 9.613/98 (Doc. 2 – fls. 56). A denúncia foi recebida em **13/6/2017** (doc. 2 – fls. 62-66) e, em **5/2/2018**, sobreveio sentença de parcial provimento da pretensão acusatória (Ação Penal 5024266-70.2017.4.04.7000), resultando na absolvição pelo crime de organização criminosa e condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro (Doc. 2 – fls. 132-250). Por ocasião da prolação da sentença, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR dispôs (Doc. 2 – fl. 149):

II.6

79. As Defesas de Maurício de Oliveira Guedes, Paulo Roberto Gomes Fernandes, **Márcio de Almeida Ferreira** e de Marivaldo do Rozário Escalfoni alegam vício procedimental porque, segundo eles, o prazo para a apresentação de suas alegações finais só deveria ter sido aberto após a apresentação das alegações finais das Defesas dos acusados colaboradores.

80. De fato, houve requerimentos nesse sentido pelas Defesas e que foi indeferido nos despachos de 24 e 28/11/2017 (eventos 476 e 481).

81. Na linha do exposto no tópico anterior, trata-se de outro requerimento que não tem amparo legal.

82. A Defesa de acusado colaborador não equivale à Acusação, sendo posições processuais distintas.

83. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer

HC 166373 / PR

hierarquia entre Defesas e acusados. O prazo é comum para alegações finais de todos os defensores.

84. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base em interpretações criativas.

85. Registre-se, por oportuno que tal matéria foi submetida ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo HC 5069625-91.2017.4.04.0000 e que foi indeferido liminarmente.

86. Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental no ponto.

Segundo informações prestadas, em 5/2/2019, pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, a temática “foi suscitada como preliminar na apelação interposta pela Defesa de Marcio de Almeida Ferreira contra a aludida sentença condenatória, pendente de análise pela 8ª Turma do E. TRF4” (Doc. 7 – fl. 3).

No tocante ao objeto desta impetração, consta que, ao final da instrução, em 14/11/2017, foi designado prazo comum para todos os réus apresentarem alegações finais (Doc. 2 – fls. 68-69). Inconformada, postulou a defesa, nos autos da Ação Penal 5024266-70.2017.4.04.7000/PR, que o prazo para a apresentação das alegações finais do paciente fosse posterior ao concedido às defesas dos colaboradores (Doc. 2 – fl. 72).

Em 24/11/2017, o pleito foi indeferido pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, por ausência de previsão legal (Doc. 2 – fl. 74):

A Defesa de Márcio de Almeida Ferreira requer seja postergada a apresentação de suas alegações finais para data posterior à apresentação das alegações finais pelos acusados que celebraram acordo de colaboração premiada com o MPF (evento 474).

A pretensão da Defesa não está albergada pelo ordenamento jurídico.

Nem o CPP nem a Lei 12850/2013 preveem benefício da espécie.

A ampla defesa e o contraditório foram já plenamente

HC 166373 / PR

assegurados com a oitiva dos colaboradores em audiência, sujeitos aos questionamentos das partes.

Indefiro, assim, o pedido formulado pela Defesa de Márcio de Almeida Ferreira, mantendo o prazo comum para a apresentação das alegações finais pelas Defesas (evento 463).

Ciência à referida Defesa.

Curitiba, 24 de novembro de 2017.

Contra essa decisão, foi impetrado *Habeas Corpus* junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC 5069625-91.2017.4.04.0000/PR), liminarmente indeferido pelo Desembargador relator em **12/12/2017** (Doc. 2 – fls. 77-80). Em **7/2/2018**, essa decisão foi confirmada pelo colegiado, conforme se depreende da seguinte ementa (Doc. 2 – fl. 106):

'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRAZO DIFERENCIADO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. RÉU NÃO COLABORADOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. A impetração de *habeas corpus* destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.

2. O *habeas corpus* não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade (Súmula 124 do TRF4).

3. Os prazos para apresentação de alegações finais são comuns a todos os atores processuais, independente de sua posição de colaborador ou não.

4. Agravo regimental desprovido.

Ainda irresignada, a defesa interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, do qual o relator não conheceu, em

HC 166373 / PR

16/5/2018, porque interposto por advogado sem procuração nos autos, de modo a incidir “o óbice previsto na Súmula n. 115/STJ: *‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’*” (Doc. 2 – fls. 280-285 – destaques no original). Em 7/6/2018, esse entendimento foi mantido pela Quinta Turma no julgamento do Agravo Regimental, conforme registrado na ementa do julgado (Doc. 2 – fl. 301):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCURAÇÃO. ADVOGADO. JUNTADA. NECESSIDADE. RECORRENTE. PACIENTE. SÚMULA 115/STJ. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" - enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal

II - Não obstante se considere que na impetração de habeas corpus não se exija a produção de instrumento de mandato, uma vez que qualquer um do povo pode impetrar o remédio heróico, tal faculdade não se estende à interposição do respectivo recurso ordinário.

III - A comprovação da capacidade postulatória em recurso dessa natureza somente é dispensada na hipótese em que pessoa leiga impetre o habeas corpus, e contra a decisão do *writ*, ele próprio interpõe o recurso.

Agravo regimental desprovido.

Os subsequentes Embargos de Declaração também não obtiveram sucesso. Eis a ementa do julgado (Doc. 2 – fls. 332):

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MATÉRIA ANALISADA. EMBARGOS

HC 166373 / PR

REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do **decisum** embargado.

II - As alegações de que o Impetrante não figura como mandatário do Paciente, eis que ocupa o polo passivo do writ, bem assim a inaplicabilidade da Súmula 115/STJ ao recurso ordinário e a possibilidade de intimação para regularização da representação processual não configuram o vício da omissão, sobretudo porque a fundamentação do voto condutor foi clara e suficiente a esclarecer acerca da imprescindibilidade da juntada da procuração. Trata-se de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso ordinário, sem o qual não se permite avançar no conhecimento do mérito.

III - A pretensão do embargante de alterar a manifestação desta Corte, de modo a adequá-la ao seu entendimento, não justifica a oposição de embargos declaratórios.

Embargos rejeitados.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido “de apresentação das alegações finais após a apresentação das alegações finais dos réus colaboradores, violando-se gravemente a ampla defesa” (Doc. 1 – fl. 1). Sustenta que: **(a)** “o Sr. Edison Krummenauer e o Sr. Luís Mário da Costa Mattoni celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. O Sr. *Luís Mário da Costa Mattoni* não menciona o ora Paciente em sua delação. Porém, o colaborador Edison Krummenauer, ainda que injustamente, atribui ao Paciente a prática de crime de corrupção”; **(b)** “a previsão para apresentação das alegações finais defensivas após as alegações finais de réus colaboradores decorre do próprio princípio da ampla defesa e do princípio do contraditório” (Doc. 1 – fl. 8); **(c)** “[a]

HC 166373 / PR

previsão constitucional assegura que a defesa deverá ser exercida amplamente, e para isso, por óbvio, deve conhecer o conteúdo da acusação, a qual, no caso concreto, conta com a colaboração dos delatores, que devem confirmar a tese acusatória visando obter os benefícios do acordo na sentença, e podem trazer elementos e argumentos novos, com o objetivo de incriminar os demais acusados, como é o caso do Paciente” (Doc. 1 – fl. 8); **(d)** “[e]mbora o colaborador seja incluído na condição de réu, ele também acusa os demais acusados, e assim a defesa daqueles que não firmaram acordo de colaboração devem conhecer a argumentação dos réus colaboradores, especialmente em alegações finais, para que possam apresentar sua defesa de forma ampla, podendo reagir aos argumentos de quem o acusa” (Doc. 1 – fl. 9); **(e)** “não há como se afirmar, como faz o Juízo de 1º grau, que não existe norma estabelecendo a possibilidade de apresentação de alegações finais por último, já que a lei garante que a defesa apresentará após a acusação. Compreendida a colaboração como acessória da acusação oficial, ela deve falar antes da defesa dos acusados que não firmaram acordo” (Doc. 1 – fl. 10); **(f)** “[o]s colaboradores foram interrogados antes dos demais réus, porém o Juízo, inexplicável e lamentavelmente, não permitiu esta prática na ocasião da apresentação das alegações finais, que talvez fosse mais importante do que a ordem do interrogatório” (Doc. 1 – fl. 11); e **(g)** é “evidente que o recurso, ordinário, manejado no âmbito da ação constitucional de *habeas corpus* pelo autor da referida ação, **não pode ser obstaculizado sob este pífio argumento de deficiência da representação; sem, ainda (superando o equívoco e a incoerência do entendimento), oportunizar à defesa a juntada da procuração**” (Doc. 1 – fl. 18 – destaques no original).

Ao final, requer a concessão da ordem, “para reconhecer a nulidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau, ordenando-se nova abertura de vista à defesa do Paciente após as alegações finais dos réus colaboradores” (Doc. 1 – fl. 20).

O Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR apresenta informações de teor seguinte (Doc. 7 – fls. 2-3):

Relativamente ao habeas corpus acima identificado,

HC 166373 / PR

paciente Marcio de Almeida Ferreira, venho informar o que segue.

Insurgem-se os impetrantes contra a longínqua decisão, proferida pelo então Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, na ação penal 5024266-70.2017.4.04.7000, em 24/11/2017, na qual o aludido magistrado indeferiu pedido formulado pela Defesa de Marcio de Almeida Ferreira para apresentação de alegações finais somente após a apresentação das alegações finais dos coacusados que celebraram acordo de colaboração premiada. Transcrevo, por oportuno:

"A Defesa de Márcio de Almeida Ferreira requer seja postergada a apresentação de suas alegações finais para data posterior à apresentação das alegações finais pelos acusados que celebraram acordo de colaboração premiada com o MPF (evento 474).

A pretensão da Defesa não está albergada pelo ordenamento jurídico.

Nem o CPP nem a Lei 12850/2013 prevêm benefício da espécie.

A ampla defesa e o contraditório foram já plenamente assegurados com a oitiva dos colaboradores em audiência, sujeitos aos questionamentos das partes.

Indefiro, assim, o pedido formulado pela Defesa de Márcio de Almeida Ferreira, mantendo o prazo comum para a apresentação das alegações finais pelas Defesas (evento 463).

Ciência à referida Defesa.

Curitiba, 24 de novembro de 2017".

A alegação também foi suscitada pela Defesa dos coacusados Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni e indeferida, com os mesmos fundamentos, em 28/11/2017.

Posteriormente, a questão foi examinada como preliminar de mérito na sentença condenatória, proferida em 05/02/2018, com o que a decisão impugnada na base dos sucessivos habeas

HC 166373 / PR

corpus substituiu-se pela decisão de mérito, definitiva.
Transcrevo:

"II.6

79. As Defesas de Maurício de Oliveira Guedes, Paulo Roberto Gomes Fernandes, Márcio de Almeida Ferreira e de Marivaldo do Rozário Escalfoni alegam vício procedimental porque, segundo eles, o prazo para a apresentação de suas alegações finais só deveria ter sido aberto após a apresentação das alegações finais das Defesas dos acusados colaboradores.

80. De fato, houve requerimentos nesse sentido pelas Defesas e que foi indeferido nos despachos de 24 e 28/11/2017 (eventos 476 e 481).

81. Na linha do exposto no tópico anterior, trata-se de outro requerimento que não tem amparo legal.

82. A Defesa de acusado colaborador não equivale à Acusação, sendo posições processuais distintas.

83. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer hierarquia entre Defesas e acusados. O prazo é comum para alegações finais de todos os defensores.

84. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base em interpretações criativas.

85. Registre-se, por oportuno que tal matéria foi submetida ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo HC 5069625-91.2017.4.04.0000 e que foi indeferido liminarmente.

86. Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental no ponto".

A questão, também, foi suscitada como preliminar na apelação interposta pela Defesa de Marcio de Almeida Ferreira contra a aludida sentença condenatória, pendente de análise pela 8ª Turma do E. TRF4.

Operada a substituição da decisão provisória pela definitiva, não tem mais sentido a impetração sucessiva de habeas corpus com a finalidade de atacar a decisão substituída

HC 166373 / PR

e de antecipar posterior análise do E. TRF4.

Assim, reputa este Juízo, respeitosamente, que, ante a prolação de sentença na ação penal 5024266-70.2017.4.04.7000, esgotou-se o objeto da presente impetração.

Aproveito para encaminhar cópia da aludida sentença.

Era o que tinha a informar.

A Procuradoria-Geral da República, em parecer subscrito pela Procuradora-Geral RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, manifesta-se pela denegação da ordem, mediante razões assim sumariadas (Doc. 8):

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA JATO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 403 DO CPP. PRAZO COMUM. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE RÉUS COLABORADORES E NÃO COLABORADORES. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A jurisprudência desse E. Supremo Tribunal Federal, quando trata da necessidade de procuração para interposição de recurso ordinário em *Habeas Corpus*, é enfática ao não exigir a apresentação do instrumento de mandato pelo subscritor do recurso.

2. Inexiste ilegalidade na decisão que, na fase de alegações finais, concede prazo comum aos corréus colaboradores da Justiça e não colaboradores. As normas de regência da questão em debate, sejam do CPP (art. 403), sejam da Lei nº 12.850/13, não fazem qualquer diferenciação entre corréus colaboradores da Justiça e aqueles não colaboradores. Ambos integram, em igualdades de condições, o polo passivo da relação processual, submetendo-se, portanto, aos mesmos prazos processuais.

HC 166373 / PR

3. A alegação genérica de nulidade, sem a comprovação do efetivo prejuízo ao paciente, não autoriza a anulação de ato processual, nos termos da Súmula 523/STF.

– Parecer pela denegação da ordem.

Em 28/8/2019, o eminente relator, Ministro EDSON FACHIN, com suporte nos arts. 6º, II, “c”; 21, I e XI, e 22, “b”, todos do RISTF, e com base no decidido no julgamento do HC 143.333/PR, afetou este *writ* à deliberação do Plenário (Doc. 9).

Instado a apresentar informações complementares, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR noticia (Doc. 13):

Venho a Vossa presença com o fim de prestar informações complementares requisitadas no *habeas corpus* n.º 166373, impetrado em favor de Márcio de Almeida Ferreira, onde é solicitado o "*encaminhamento de cópia das alegações finais apresentadas pelas partes na ação penal de origem, bem como fornecimento de senha que propicie acesso aos autos respectivos*".

Inicialmente reporto-me às informações já prestadas no ofício nº 70000624989, destacando que não houve neste juízo alteração fática acerca do anteriormente informado.

Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento 500) foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores os demais réus juntaram suas alegações finais. Maurício de Oliveira Guedes (evento 501), Márcio de Almeida Ferreira (evento 502), Paulo Roberto Gomes Fernandes (evento 503) e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 504). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni complementaram suas alegações finais (evento 505).

Após a apresentação das alegações finais os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida na data de 15/01/2018 (evento 509), tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas Defesas (todas de não

HC 166373 / PR

colaboradores) conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório, com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais.

Os réus colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 519) e Edison Krummenauer (evento 522) complementaram suas alegações finais antes mesmo do MPF (evento 526). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni, réus não colaboradores, complementaram as alegações finais no evento 529.

Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira optaram por não complementarem suas alegações finais.

Encaminho em anexo cópia das alegações finais prestadas pelas partes, bem como das decisões que trataram da reabertura do prazo para complementação em decorrência dos documentos apresentados pelas defesas dos réus não colaboradores e das complementações das alegações finais.

Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada julgou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado.

Não há na alegações finais destes réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo.

[...]

Fico à disposição de Vossa Excelência para prestar outras informações ou remeter cópia de peças eventualmente julgadas necessárias.

Por oportuno, manifesto meus respeitosos cumprimentos.

Anexe-se ao presente ofício cópia as alegações finais do

HC 166373 / PR

MPF (evento 487); da assistente de acusação Petrobras (evento 489); das alegações dos réus colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento 500); das alegações finais dos demais réus não colaboradores Maurício de Oliveira Guedes (evento 501), Márcio de Almeida Ferreira (evento 502), Paulo Roberto Gomes Fernandes (evento 503) e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 504); da complementação das alegações finais dos réus não colaboradores Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 505); da decisão que intimou as partes sobre os documentos juntados pelas defesas dos réus não colaboradores (evento 509); da complementação das alegações finais pelos colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 519) e Edison Krummenauer (evento 522), pelo MPF (526) e pelos réus não colaboradores Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 529); do pedido incidental feito pelos réus Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 520) e a decisão que o indeferiu (evento 523); e ainda o pedido incidental feito pelo réu Márcio de Almeida Ferreira (evento 533) e a decisão que o indeferiu (evento 536). (destaques nossos)

Por meio de Petição, PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES alegou ser corréu do ora paciente e pugnou por sua habilitação neste *writ*, a título de “interessado juridicamente em seu desfecho” (Doc. 25). Entendeu Sua Excelência que o peticionante “não se insere nas hipóteses de admissão retratadas pela jurisprudência desta Corte” e, portanto, indeferiu o pedido, resguardando-lhe, “sendo o caso, eventual impetração em nome próprio e, desde logo, nos exatos termos do art. 580, CPP, formulação de eventual e oportuno pedido de extensão” (Doc. 32).

Feita essa breve retrospectiva dos fatos, **passo a votar**.

1. NATUREZA DA DELAÇÃO – MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA – AMPLA POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO.

HC 166373 / PR

A delação premiada é um *negócio jurídico personalíssimo, no campo do Direito Público*, em que o Ministério Público ou a Polícia celebram o acordo com o delator.

Sendo o acordo de “colaboração premiada” um “meio de obtenção de prova” (art. 3º da Lei 12.850/2013), assim como a busca e apreensão, a interceptação telefônica, o afastamento de sigilo bancário e fiscal, como foi bem salientado no magistral voto do Ministro DIAS TOFFOLI (HC 127.483/PR).

Assim como ocorre em outros meios de obtenção de prova, como a interceptação telefônica, o contraditório é diferido e deverá ser realizado durante a ação penal, com amplas possibilidades de demonstrar eventual falsidade, erros ou exageros das declarações prestadas pelo delator/colaborador.

Haverá, portanto, total possibilidade de impugnação das afirmações e informações apresentadas pelo relator.

No momento da decisão final de mérito, o Judiciário deverá analisar a colaboração premiada e as provas dela derivadas, assim como o fará em relação a todos os meios de prova (interceptação, quebra de sigilo bancário, mandado de busca e apreensão, etc), no intuito de formar sua convicção e julgar.

O juízo natural decidirá o mérito da ação penal, a partir da análise das provas produzidas em juízo, inclusive daquelas obtidas a partir das informações prestadas pelo delator, mediante contraditório e ampla defesa. Analisará, inclusive, a licitude de todas as provas e da regularidade dos métodos de sua obtenção, sob pena de cerceamento da atividade e independência jurisdicional e ferimento ao devido processo legal.

O juiz natural analisará cada uma das provas obtidas, bem como a licitude ou não dos meios pelas quais as provas foram obtidas (CF, art. 5º, LVI).

Da mesma maneira que o órgão poderá chegar à conclusão que determinadas gravações obtidas por meio de interceptação telefônica devidamente autorizada, durante a investigação, apresentaram

HC 166373 / PR

irregularidades – apontadas pela defesa no contraditório diferido existente – e declarar a ilicitude das provas obtidas; poderá entender que as provas obtidas a partir da colaboração premiada são ilícitas, se houver algum vício na “regularidade, voluntariedade ou legalidade do acordo”, também a partir do contraditório diferido.

No momento da sentença final, o juízo natural da causa, para formar sua convicção, analisará a licitude de todos os meios de prova e provas obtidas, devidamente impugnadas e contraditadas mediante o devido processo legal, inclusive a colaboração premiada e as provas dela decorrentes.

Da mesma maneira, no momento da decisão de mérito deverá ser analisada a eficácia real da cooperação prestada pelo agente colaborador/delator, pois a implementação das denominadas “sanções premiais”, como destacado pelo nosso Decano, Ministro CELSO DE MELLO, está necessariamente condicionada ao efetivo adimplemento das obrigações que tenham sido assumidas por referido colaborador e de que advenha um ou mais dos resultados indicados no art. 4, incisos I a V, da Lei 12.850/2013” (HC 144.652/DF).

2. CONDIÇÕES PARA EFETIVIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – SITUAÇÃO PECULIAR DO DELATOR NA RELAÇÃO PROCESSUAL.

Importante analisar do que depende a efetividade da delação e a obtenção dos benefícios acordados pelo delator, durante a ação penal.

Quando o delator terá direito a diminuição de pena ou ao próprio perdão prometido?

Somente se sua delação auxiliar efetivamente na obtenção da condenação, ou seja, se o Ministério Público obtiver a condenação e, desde que, para essa obtenção tenha concorrido as informações prestadas pelo delator. Deve haver nexo de causalidade entre a colaboração e a condenação.

Dessa forma, não me parece existir qualquer dúvida de que o

HC 166373 / PR

interesse processual do delator é absolutamente oposto ao interesse do delatado.

Impossível, portanto, falarmos materialmente na existência de litisconsórcio passivo entre delator e delatado, uma vez que o sucesso da delação, e, conseqüentemente a obtenção das vantagens premiais oferecidas pelo Ministério Público ao delator, depende da condenação do delatado.

Em outras palavras, a absolvição do delatado afasta a eficácia da delação e, com isso, torna sem efeito os benefícios prometidos ao delator pelo Ministério Público.

Em sentido material, portanto, poderíamos concluir que o delator é litisconsorte da defesa do delatado ou da própria acusação?

Qual o resultado da ação penal que lhe interessa?

Condenação ou absolvição do delatado?

Qual o resultado da ação penal que lhe garante futura diminuição de pena, outros benefícios ou até mesmo o perdão total acordado com o Ministério Público? A absolvição ou a condenação do delatado?

O interesse processual do delator está direta e intimamente ligado à obtenção da condenação do delatado pelo Ministério Público. Porém, pretende mais do que a obtenção da condenação.

O delator precisa da condenação baseada em informações eficazes que tenha fornecido na delação e que, concretamente, tenham possibilitado a obtenção de provas para sustentar a sentença condenatória; pois se a delação não for eficaz, o delator não fará jus aos benefícios prometidos. Assim se dá o funcionamento da justiça premial.

A delação inútil, as informações vazias ou insuficientes, a participação irrelevante do delator geram a inefetividade da delação e não permitem que se obtenha as vantagens prometidas e acordadas com o Ministério Público nesse sistema de justiça premial.

Ora, todo o empenho processual do delator será a favor do Ministério Público, buscando a obtenção de uma sentença condenatória do delatado, condição absolutamente necessária para a plena eficácia do acordo de delação realizado. Condição necessária, porém não suficiente;

HC 166373 / PR

pois, a sentença condenatória precisará reconhecer a efetividade das informações do delator para a conclusão do processo.

Dessa forma, a relação DELATOR X DELATADO é de antagonismo, é de contradição, é de contraditório.

Trata-se de situação diversa daquela tratada pelo Código de Processo Penal em relação aos corréus.

O interesse do corréu é obter sua absolvição, independentemente das argumentações, inclusive imputando os fatos ao outro réu. Seu antagonismo ao Ministério Público é evidente. Os interesses são conflitantes entre acusação – que pretende sua condenação – e defesa.

A situação do delator é diversa.

O delator não precisa, efetivamente, se defender, pois sua intenção, seu móvel é dar efetividade ao acordo, ou seja, ele precisa obter a condenação do delatado. Se não obtiver, não haverá efetividade da delação e ele não será beneficiado com a delação. SEUS INTERESSES SÃO ABSOLUTAMENTE OPOSTOS AO DO DELATADO.

Se é uma relação contraditória, não se pode fugir da aplicação integral dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

3. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (art. 5º, LIV, LV) – ORDEM DAS MANIFESTAÇÕES NO PROCESSO - “DIREITO DE FALAR POR ÚLTIMO”.

A Constituição Federal de 1988 incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à *Magna Charta Libertatum* de 1215, de vital importância no direito anglo-saxão. Igualmente, o art. XI, nº 1, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, garante que

“todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”.

HC 166373 / PR

Inovando em relação às antigas Cartas, a Constituição atual referiu-se expressamente ao *devido processo legal*.

O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, direito de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).

O devido processo legal tem como corolários a *ampla defesa* e o *contraditório*, que deverão ser assegurados aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional expresso (art. 5º, LV), aplicando-se inclusive ao “processo administrativo, para a apuração de ato infracional cometido por criança ou adolescente (art. 103 e ss., ECA), na medida em que seu objetivo é a aplicação de medida socioeducativa pela conduta infracional, a qual se assemelha à imposição de sanção administrativa.

Por *ampla defesa* entende-se o salvaguarda que é dada ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou de calar-se, se entender necessário, enquanto o *contraditório* é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (*par conditio*), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.

A relação de antagonismo entre as versões da acusação e da defesa não deixa dúvidas sobre quem tem o “*direito de falar por último*”.

O direito de falar por último está contido no exercício pleno da ampla defesa englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator.

HC 166373 / PR

Repita-se que, o delator precisa que o Ministério Público obtenha a condenação para ter sucesso em seu acordo, conseqüentemente, suas alegações finais, fornecendo ao processo e ao juiz todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória.

Logo, o delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação.

E isso ocorre em todos os ordenamentos jurídicos democráticos.

Na Alemanha, em relação às hipóteses de Justiça premial, até 2009, não havia regulação legislativa específica. Porém, as decisões foram paradigmáticas, ao julgarem casos específicos em que a barganha havia ocorrido. A Corte Suprema Alemã, no âmbito da jurisdição ordinária, se posicionou implicitamente a respeito da mesma de maneira a garantir a incidência do contraditório e da ampla defesa nesse instituto (*BGH 4 StR 240/97 - Urteil vom 28. August 1997 – LG Dortmund; BGH GSSt 1/04 - Beschluss vom 3. März 2005 – LG Lüneburg/LG Duisburg*).

O próprio Judiciário solicitou a atuação urgente do legislativo para melhor regulamentação. Em vista disso, em maio de 2009, surgiu a Lei de Regulamentação dos Acordos no Processo Penal, a qual fundamentalmente adicionou um parágrafo (§ 257c) ao Código de Processo Penal alemão (StPO), regulando a realização de barganhas e estabelecendo a incidência da Seção 258, à Seção imediatamente anterior incluída para regulamentar as barganhas.

A inclusão da Seção 257c faz com que a Seção 258 a ela se aplique, ou seja, O RÉU TERÁ SEMPRE A ÚLTIMA PALAVRA (Seção 258 – (2) O promotor público tem o direito de responder; o réu terá a última palavra).

Da mesma maneira, o ordenamento jurídico italiano ao estabelecer o desenvolvimento da discussão processual, no Capítulo V, do artigo 523 do Código Processual, estabelece no item 5, que “5. *De qualquer forma, o acusado e o defensor devem ter, sob pena de nulidade, a última palavra, se o solicitarem*”.

O ordenamento jurídico espanhol, igualmente, consagrou que sempre haverá vulneração à ampla defesa e um prejuízo real e efetivo aos

HC 166373 / PR

interesses do réu se não puder impugnar todos os argumentos apresentados, ou seja, se lhe for negado o direito à última palavra, com o conhecimento prévio e pleno de toda a atividade probatória realizada e de todos os argumentos apresentados e que possam ter influência em sua eventual condenação.

Nas Sentenças 181/1994, 29/1995, 91/2000, 13/2006 e 258/2007, o Tribunal Constitucional da Espanha estabeleceu que o “direito à última palavra” no processo penal deve ser do acusado, que deve ter a oportunidade final de apresentar suas argumentações como garantia efetiva do princípio da ampla defesa.

Na América do Sul, a Delação premiada no direito colombiano vai mais além, pois admite a ampla defesa na própria formação do acordo, e, nos termos do artigo 442 da lei processual, o direito a falar por último é sempre daquele cuja imputações são contrárias. Definiu a Corte Constitucional, que compete a esse acusado o “último turno de intervenção argumentativa” (Corte Constitucional mediante *Sentencia C-651* de 2011; Corte Constitucional mediante *Sentencia C-616* de 2014).

O devido processo legal, ampla defesa e contraditório exigem que o delatado se manifeste após ter o pleno conhecimento de toda a atividade probatória realizada durante o processo, podendo contraditar todos os argumentos trazidos nos autos, inclusive aqueles trazidos pelo delator.

Não foi outro o entendimento da Suprema Corte Americana, no caso *Crawford vs. Washington* (2003), em que a Corte decidiu que se toda e qualquer declaração de natureza testemunhal utilizada para comprovar a veracidade de fatos somente poderá ser admitida em juízo se o destinatário da imputação tiver a oportunidade de examinar o teor da declaração.

Esse é o mesmo entendimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em diversas decisões: *Asch vs. Áustria* (1991); *Isgrò vs. Itália* (1991); *Kostovski vs. Países Baixos* (1989), *Camilleri vs. Malta* (2013), considerando que todo aquele que imputa um fato criminoso ao acusado deve ser considerado como “testemunha”, pouco importando o meio pelo qual o relato chegou ao conhecimento do julgador, somente podendo ser

HC 166373 / PR

fundamento para a sentença condenatória se o acusado tiver oportunidade posterior, adequada e suficiente para contestar seu inteiro teor.

Dessa maneira, havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado para ter o *“último turno de intervenção argumentativa”*, que foi negado inconstitucionalmente pelo juízo de origem, há ferimento flagrante ao devido processo penal, à ampla defesa e ao contraditório.

Diante do exposto, CONCEDO a ordem de *HABEAS CORPUS*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, e proponho a fixação da seguinte TESE:

“Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.

É o voto.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**VOTO**

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Senhoras Ministras, caros Colegas, ouvi com atenção o voto de ontem do Ministro Luiz Edson Fachin e, hoje, com igual aplicação, ouvi o voto do Ministro Alexandre de Moraes.

I. OS FATOS RELEVANTES

Como sempre gosto de fazer, situo aqui a hipótese com que estamos lidando. Trata-se de um *habeas corpus*. Segundo a denúncia, o paciente do *habeas corpus*, na qualidade de gerente da Petrobras, teria recebido, em conjunto com outros acusados, R\$ 37 milhões a título de vantagens indevidas que funcionariam como contrapartida de favorecimentos concedidos a empresas em contratos firmados com a Petrobras, especialmente no tocante à construção do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho. Este é o fato subjacente: o desvio de R\$ 37 milhões. Nada é pequeno no quadro da corrupção brasileira.

O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 10 anos e 3 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva (levar vantagem indevida) e lavagem de dinheiro. O *habeas corpus* é impetrado contra essa decisão condenatória.

A questão jurídica em discussão é saber se havendo réus que são colaboradores da Justiça e réus que não colaboraram com a Justiça, se os réus que não colaboraram têm o direito de se manifestar em alegações finais, após a manifestação dos réus que colaboraram. Com a observação, que considero importante, de que as alegações finais não constituem um momento de inovação no processo penal.

As alegações finais consistem em uma manifestação das partes acerca do material probatório produzido ao longo do processo. Não há inovação nas alegações finais porque, se houver, o juiz tem que abrir

HC 166373 / PR

prazo para que os outros se manifestem, como de resto – e vou demonstrar logo adiante – foi o que aconteceu nesse processo. Repito, ninguém é surpreendido por nada que se traga em alegações finais. As alegações finais se limitam a interpretar, analisar, comentar as provas já produzidas. Acho que esta é a primeira observação que considero importante a propósito dessa discussão.

A segunda é que este não é um caso isolado – como observou o eminente Ministro Luiz Edson Fachin. O que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Essa inovação importante do Direito brasileiro já vinha na legislação, desde lá atrás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Então, essa discussão não é um caso isolado de *habeas corpus*. Será produzido um efeito sistêmico na interpretação de uma legislação que funcionou e que ajudou o Brasil a começar a romper o paradigma de impunidade, que vigorava em relação à corrupção e à criminalidade do colarinho branco.

II. O CONTEXTO DA CORRUPÇÃO NO BRASIL

Pois, qual é o contexto em que se insere este julgamento? É o contexto de um esforço imenso da sociedade brasileira para enfrentar o quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o País e que não começou com uma pessoa, com um governo, com um partido. Vem de longe, vem de muito longe, só que acumulativamente, até que um dia transbordou.

Assim, o cenário deste julgamento é o cenário de um País que procura se libertar do domínio oligárquico da corrupção estrutural e institucionalizada. Não é difícil demonstrar o meu argumento. O contexto em que vivemos, do qual ainda não saímos, inclui o seguinte:

(i) entre o fim da década de 80 e início dos anos 90, vivemos o escândalo dos Anões do Orçamento, com desvios de aproximadamente 800 milhões. E chamo a atenção dos eminentes Colegas para a escalada

HC 166373 / PR

dos valores;

(ii) entre 92 e 98, foi desvendado o caso da construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, em que foram desviados R\$ 2 bilhões;

(iii) em meados dos anos 90, veio à tona o escândalo do Banestado, em que mais de R\$ 30 bilhões foram enviados ao exterior – boa parte, produto de corrupção e envolvendo lavagem;

(iv) entre 1990 e 2004, o esquema dos "Sanguessugas" desviou mais de 4 bilhões por meio de superfaturamento na compra de remédios e homoderivados. Nem a saúde escapa da sanha da corrupção;

(v) e, nos anos 2000, o escândalo do Mensalão, em que mais do que os valores envolvidos (R\$ 160 milhões, segundo se divulgava), colocou em xeque o próprio funcionamento da democracia brasileira por meio da compra regular de votos no parlamento.

O Mensalão é um ponto de inflexão muito importante de se ressaltar no Brasil. Porque, a partir daí, houve uma reação da sociedade brasileira, que progressivamente foi deixando de aceitar o inaceitável. As instituições começaram a corresponder a essas demandas da sociedade: Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal não faltou a esse compromisso com a história. No julgamento do Mensalão, mais de duas dezenas de pessoas, entre políticos e empresários –possivelmente, pela primeira vez na história do Brasil –, foram efetivamente condenadas por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

O julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal começou a mudar a história do Brasil, e, naquele julgamento, se produziram páginas antológicas das quais destaco algumas passagens de Ministros que ainda integram esta Corte e participaram do julgamento, começando pelo Ministro Celso de Mello, nosso Decano, um orgulho para o Brasil e para todos nós. Disse Sua Excelência, na Ação Penal 470, julgamento do Mensalão:

"A ordem jurídica **não pode permanecer indiferente** a condutas de **quaisquer** autoridades da República que hajam eventualmente incidido

HC 166373 / PR

em censuráveis desvios éticos e em graves transgressões penais" (...).

(...)

"O ato de corrupção **constitui um gesto de perversão da ética do poder e da ordem jurídica, cabendo ressaltar que o dever de probidade traduz obrigação cuja observância se impõe a todos** os cidadãos desta República **que não toleram o poder que corrompe nem admitem o poder que se deixa corromper.**"

Páginas memoráveis daquele julgamento.

Disse ainda o Ministro Celso de Mello:

"**Quem transgredie** tais mandamentos, **não** importando a sua posição estamental, **se patricios ou plebeus, governantes ou governados,**" - aqui o depoimento sobre a dificuldade de se criar um Direito Penal verdadeiramente igualitário no Brasil - **expõe-se à severidade** das leis penais **e, por tais atos,** o corruptor e o corrupto **devem ser punidos, exemplarmente,** na forma da lei."

Prossegue Sua Excelência:

(...) "**nem** o cinismo, **nem** o pragmatismo, **nem** a ausência de senso ético, **nem** o oportunismo podem justificar, **quer** juridicamente, **quer** moralmente, **quer** institucionalmente, **práticas criminosas, como a corrupção parlamentar ou as ações corruptoras** de altos dirigentes do Poder Executivo **ou** de agremiações partidárias."

Prossegue o Ministro Celso de Mello:

"**A corrupção deforma** o sentido republicano de prática política, **afeta** a integridade dos valores **que informam e dão significado** à própria ideia de República, **frustra** a consolidação das instituições, **compromete** a execução de políticas públicas *em áreas sensíveis* **como** as da saúde, educação, segurança pública e do próprio desenvolvimento do País, **além de vulnerar** o princípio democrático."

E conclui Sua Excelência:

"**Eis aí,** Senhor Presidente, **as gravíssimas** consequências **que derivam dessa aliança profana, do gesto infiel e indigno** de agentes corruptores, *públicos e privados,* **e** de parlamentares corruptos, **em comportamentos criminosos, devidamente comprovados, que só fazem**

HC 166373 / PR

desqualificar **e** desautorizar, **perante** as leis criminais do País, a atuação desses marginais do Poder."

Nesse mesmo julgamento, votou o Ministro Gilmar Mendes:

"A prova dos autos revela a utilização do aparelho do Estado com desvirtuamento de suas finalidades e sobreposição de interesses privados."

(...)

"Não se pode cogitar de *normal ordem jurídico-social* quando se tem um partido político corrompendo parlamentares, distribuindo cargos públicos por meio de cooptação política; quando a máquina do Estado é utilizada para fins privados; quando se fraudam licitações; quando se desviam recursos públicos; quando uma instituição financeira coloca interesses outros à frente do seu papel constitucional de promover o desenvolvimento e de servir aos interesses da coletividade; quando a empresa não se orienta por sua função social, ao revés, empenha-se na atividade criminosa."

Ainda, em outro julgamento de 2013, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes assim se pronunciou:

"A investigação revela que o patrimônio público estaria sendo saqueado por forças políticas. Os recursos serviriam para manter a boa vida dos mandatários, mas não apenas isso. O esquema se afigura verdadeiro método de governar: de um lado, recursos do estado fluiriam para as forças políticas; de outro, financiariam a atividade político-partidária e de campanhas eleitorais, a corrupção de agentes públicos, a manutenção de base partidária fisiológica, a compra de apoio da imprensa e de movimentos sociais e, claro, o luxo dos atores envolvidos.

Ou seja, cuidava-se de método criminoso de governança, que visava à perpetuação de um partido no poder, por meio do asfixiamento da oposição."

Ainda, do voto do Ministro Gilmar Mendes, de 2013, colho:

"Não se fazia contrato na Petrobras sem pagar propina. Não se fazia contrato na Petrobras sem dever dinheiro para partido. É evidente a

HC 166373 / PR

confusão entre Estado e partido. Mas, como ninguém é de ferro, nem tudo pode ir para o partido, tem que ir para os iates, para as casas, para as pessoas. Bendita Lava-Jato porque deitou sobre esse caso!

Eu não sabia - prossegue o Ministro Gilmar Mendes - que havia essa diferença entre a corrupção para o partido e a corrupção para o interesse próprio, como se houvesse um tipo penal diferente, uma ética peculiar. Estamos num mundo realmente surreal. O desenvolvimento da Lava-Jato conta uma história triste, vergonhosa, mas que mostra as entranhas do sistema político-administrativo que se desenvolveu no Brasil. A Lava Jato estragou tudo, a Lava Jato revelou o quê? Pelas contas do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa”.

Esses pronunciamentos foram decisivos na mudança da percepção da sociedade brasileira quanto ao significado da corrupção, e não se considerar como normal o que foi naturalizado no Brasil, que é o desvio regular de dinheiro público. Agentes públicos que se consideram sócios do País e levam um percentual em todas as obras públicas relevantes. E como é difícil mudar essa cultura! E como é abrangente o arco de alianças que se forma para a preservação desse modo de fazer política e de se fazerem negócios!

Depois do Mensalão e de 2015, tragicamente, a corrupção continuou. Mudaram os governos, mas as práticas não mudaram. E aí vieram:

- (i) a operação Zelotes, em que se apuram desvios de R\$ 20 bilhões;
- (ii) a operação Greenfield, que revelou um esquema de investimentos fraudulentos que gerou mais de 8 bilhões de prejuízo aos fundos de pensão das empresas estatais – dinheiro do trabalhador, direito de gente que trabalha – Funcef, Petros, Previ, Postalís.
- (iii) depois veio a operação Cui Bono, que identificou fraudes na liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal que somam mais de 3 bilhões, além de desvios em aportes do Fundo de Garantia.
- (iv) vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase R\$ 100 bilhões

HC 166373 / PR

só para a Petrobras. Relembre-se que a empresa teve que fazer acordo com acionistas, perante o Poder Judiciário dos Estados Unidos, no valor de bilhões de dólares para compensar os prejuízos causados pela corrupção; que teve que fazer acordo com o Departamento de Justiça americano de mais de US\$ 800 milhões. Essas instituições não podem ser acusadas de integrar qualquer tipo de conspiração contra quem quer que seja;

(v) na operação Radioatividade, apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da Usina de Angra dos Reis, Angra 3, em cerca de R\$ 3 bilhões, pagos a um partido político e a dirigentes da Eletronuclear;

(vi) na Operação Tesouro Perdido foi encontrado, em um apartamento de ex-secretário da Presidência da República, R\$ 51 milhões;

(vii) um ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo recebimento de mais de US\$ 1,5 milhão de propina, e o mesmo presidente foi condenado em processo derivado da Operação Sépsis, relacionada ao FI-FGTS, por corrupção, violação de sigilo e lavagem de dinheiro, por receber propina de R\$ 52 milhões relacionada ao Porto Maravilha;

(viii) um ex-candidato a Presidente da República foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, por recebimento de propinas, e obstrução de justiça;

(ix) um ex-Presidente da República foi denunciado por receber 5,9 milhões em propina relacionada à Medida Provisória dos Portos. O mesmo ex-Presidente foi denunciado pelo recebimento por interposta pessoa de R\$ 500 mil, entregues em uma mala de dinheiro, filmada, ao vivo e a cores, para quem tivesse olhos de ver. Por lavar dinheiro, por meio da reforma de apartamento de um parente, e por participar com o seu partido de desvios de R\$ 1,8 bilhão também da Usina Nuclear de Angra dos Reis.

Esses fatos ocorreram e se revelaram a partir de meados de 2016.

Novos governos, mesmos fatos, mesmas práticas, que o Supremo, veementemente, condenou no Mensalão e em julgamentos subsequentes, em boa hora.

HC 166373 / PR

Porém, a partir de 2016, as sinalizações, nessa matéria de enfrentamento da corrupção, vindas do Supremo Tribunal Federal, foram diferentes. Confira-se:

(i) diversas ações foram retiradas da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, que havia quebrado o paradigma de ineficiência e impunidade em relação à criminalidade do colarinho branco;

(ii) transferiu-se a competência para o julgamento de crimes comuns, sobretudo de colarinho branco, conexos com os eleitorais, para a Justiça Eleitoral, no momento em que a Justiça Federal vinha funcionando com crescente eficiência.

(iii) considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há quase oitenta anos, com a finalidade de impedir a destruição de provas e a combinação de versões;

(iv) entendeu-se que o parlamentar que utilize o mandato para prática de crimes, documentadamente comprovados – gravado e filmado –, não podiam ser afastados do mandato por decisão do Supremo, ficando a matéria submetida à Casa Legislativa, de onde praticados os crimes;

(v) mais de cinquenta *habeas corpus* foram concedidos apenas no Rio de Janeiro, um Estado-membro devastado pela corrupção, praticada com inimaginável desfaçatez.

E agora chega este caso, com o risco de se anular o esforço que se vem fazendo até aqui para enfrentar essa corrupção que, como disse, não é fruto de pequenas fraquezas humanas, de pequenos desvios individuais. São mecanismos profissionais de arrecadação, de desvio e de distribuição de dinheiros.

Não há como o Brasil se tornar desenvolvido e furar o cerco da renda média com os padrões de ética pública e de ética privada praticados aqui. Nós precisamos romper com esse paradigma e as instituições precisam corresponder às demandas da sociedade dentro da Constituição e dentro da lei, por evidente!

Na medida em que a jurisprudência se flexibilizava, alguém poderia imaginar que estivéssemos melhorando. Tragicamente, não foi o que

HC 166373 / PR

aconteceu. Pelo índice de percepção da corrupção, medido pela Transparência Internacional, temos piorado. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição; em 2016, pioramos para a 79ª; em 2017, caímos para 96ª; e, em 2018, o Brasil ocupa a 105ª posição, na percepção da corrupção por parte da população. Estamos para lá da metade dos países mais corruptos do mundo. Esse é o cenário brasileiro. Esse é o contexto, Presidente; nada do que eu falei é opinião. Tudo o que eu falei até agora é factual. Estou narrando fatos, penosos como sejam.

III. EXAME DO CASO CONCRETO

E, aí, chegamos ao *habeas corpus* aqui trazido pelo Ministro Luiz Edson Fachin e pautado pelo eminente Presidente.

Presidente, vou superar a questão de cabimento, porque creio que essa questão é suficientemente importante para que se objetive a discussão e se firme uma tese. Seja lá qual for, é uma tese que vai valer, porque, do contrário, ficaríamos com decisões de casos pontuais, o que não é bom para a segurança jurídica e nem para a percepção da Justiça. Supero a discussão sobre o cabimento, porque entendo imprescindível o Supremo tratar dessa matéria objetivamente. Porém, há um caso concreto subjacente; e eu passo a me pronunciar sobre ele.

III.1. ARGUMENTOS ESPECÍFICOS**1. O paciente efetivamente juntou suas alegações finais após os colaboradores premiados**

No caso concreto em julgamento, o paciente efetivamente juntou suas alegações finais após os colaboradores premiados. Após! Está dito isso no relatório do Ministro Luiz Edson Fachin, onde transcreve informações prestadas pelo juiz de primeiro grau:

"Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento

HC 166373 / PR

500) foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores os demais réus juntaram suas alegações finais" (...) - inclusive, Márcio de Almeida Ferreira, o impetrante neste caso específico.

Aqui, concretamente, houve a juntada das alegações finais pelos réus não colaboradores após os colaboradores. O Advogado de defesa Doutor Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma, que fez uma magnífica sustentação da tribuna, defendendo com enorme proficiência e empenho os interesses do seu cliente, observou que, mesmo tendo sido depois, não teria havido tempo suficiente para a reflexão e para a preparação de alegações finais que pudessem ter levado em conta o material trazido pelos colaboradores premiados.

2. O paciente teve o prazo aberto para a complementação de suas alegações finais, após os colaboradores terem apresentado as suas, mas não se manifestaram

Mas aqui – e com todas as vênias – houve um fato superveniente: é que o juiz, considerando que alguns dos réus juntaram novos documentos, abriu prazo para a apresentação de alegações finais complementares; ou seja, depois da juntada das alegações finais dos colaboradores premiados, abriu-se novo prazo integral – "Zero Km" –, para que os réus se manifestassem! O que aconteceu no tocante ao paciente desse *habeas corpus*? Permaneceu silente, achou que não tinha mais nada a dizer, não tinha mais nada a complementar, apesar de devidamente intimado para apresentar complemento das alegações finais. E, bem defendido como era; não era um réu indefeso, vimos a qualidade da defesa aqui.

Portanto, não falou, porque não quis; não falou, porque não precisava; não falou, porque não tinha nada a acrescentar. Esse fato, documentado nos autos, colhe-se das informações.

"Após a apresentação das alegações finais os autos foram baixados

HC 166373 / PR

em diligência por meio de decisão proferida na data de 15/01/2018 (evento 509), **tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas Defesas (todas de não colaboradores)**" - os documentos novos não foram trazidos pelos colaboradores premiados, eles não apresentaram mais nada - **"conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório, com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais."**

(...)

"Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira" - paciente deste *habeas corpus* - **"optaram por não complementarem suas alegações finais."**

Logo, foi estratégia da defesa; foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. *Data venia*, não para de pé a tese. Não há nas alegações finais desses réus nenhuma "inovação argumentativa, fática ou probatória" que pudesse importar em prejuízo à defesa.

E diz o juiz, relatando os autos – e estão à disposição para quem quiser ler:

"Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores" - (...) - **"houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado."**

É isso que o colaborador quer, que se cumpra o acordo celebrado com ele.

"Não há nas alegações finais destes réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas," (...).

Até porque, se houvesse aberto o prazo para a complementação das alegações finais, eles teriam se manifestado, mas optaram por não fazê-lo. De modo que, nesse caso concreto, é impossível conceder a ordem.

HC 166373 / PR

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Com muito prazer.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Na verdade, é uma indagação. Pelas minhas anotações do estudo que fiz dos autos, o paciente impetrou *habeas corpus* contra essa decisão denegatória. Ou seja, manifestou o seu inconformismo em razão do quê? Ele não se conformou, porque não lhe foi permitido falar em último lugar. Ele sofreu um prejuízo. Quer dizer, ele vem percorrendo toda a cadeia recursal porque se sentiu prejudicado. Não importa o que o juiz de primeiro grau falou, *data venia*, mas que ele não teve, de fato, a possibilidade de contestar as acusações feitas pelo corréu delator.

Desculpe-me, faço uma indagação, porque não posso imaginar que um advogado ilustre, como esse que defende o paciente, tenha lançado mão de recursos em toda a estrutura recursal do País por nada, por mero espírito de emulação. É isso que me impressiona, *data venia*.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO - Depois da condenação, como é do papel do advogado, busca-se reformar a decisão, colhendo os argumentos que possa. Mas estou afirmando, e está documentado, que, antes da sentença, contra a qual se insurgiu o advogado, foi aberto o prazo para complementação das alegações finais, e à parte e ao seu advogado pareceu bem não as complementar.

Veja, estou falando do momento anterior à sentença. É claro, uma vez condenado, os advogados, ainda mais nesse incrível sistema recursal brasileiro, vão se valer de todos os recursos e possibilidades. Mas, antes da sentença desfavorável, abriu-se o prazo, e ele não exerceu a faculdade de se manifestar.

HC 166373 / PR

III.2. ARGUMENTOS GERAIS

1. Inexiste previsão legal de que réus que não são colaboradores apresentem alegações finais após os réus colaboradores

Passando aos argumentos gerais, aplicáveis a este caso.

Inexiste previsão legal de que réus que não são colaboradores apresentem alegações finais após os réus colaboradores. Isso não está dito em lugar nenhum. Vou ao Código de Processo Penal, que foi revisto, reformado e revirado muitas vezes, inclusive depois do surgimento da legislação sobre colaboração premiada, e o seu art. 403 diz assim:

"Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença."

"Respectivamente"... Sendo assim, primeiro fala a acusação, e, depois, fala a defesa: alegações finais orais. Essa é a previsão do Código de Processo Penal. Dessa forma, colaborador premiado e réu não colaborador falam em sequência, oralmente. Não pode nem ir para casa fazer dever de casa, tem que ser ali, de chofre. Neste caso, o juiz deferiu memoriais escritos – e já vou chegar lá.

E o § 1º do art. 403 fala que:

"Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual."

Não tem uma linha, aqui, dizendo que colaborador premiado fala antes e o réu não colaborador fala depois. Não há nenhuma distinção feita pela lei.

Depois, o § 3º do mesmo art. 403 diz que:

"O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença."

HC 166373 / PR

Ou seja, a opção para alegações finais escritas e não orais, como desejavelmente seria a regra que, na prática, sabemos, não o é. Assim, o juiz concederá às partes do prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. As partes são o Ministério Público e os réus. Também não faz nenhuma distinção entre colaborador premiado e não colaborador premiado.

Mas aí tem um dispositivo, que, a meu ver, repercute diretamente neste caso, porque alguns equiparam o colaborador premiado ao assistente de acusação. Diz o § 2º:

"Art. 403. [...]"

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa."

Só que, pela legislação, pelo art. 270 do Código de Processo Penal, nenhum réu pode ser assistente de acusação, é proibido por lei. Diz o art. 270 do Código de Processo Penal que "o corréu no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público". O réu é parte da defesa – colaborador ou não colaborador.

Simplesmente não há previsão legal.

E mais do que isso, quem quer que tenha tido alguma experiência em advocacia criminal, não é incomum, mas rotineiro, que os corréus se acusem mutuamente, ou que um corréu coloque a culpa no outro, e nunca ninguém disse que o corréu que recebeu a culpa colocada pelo outro tenha que falar subsequentemente. Acontece todos os dias.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me permite?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO –
Certamente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Há um precedente do

HC 166373 / PR

Ministro Celso de Mello, um célebre caso - Boris Berezovsky - em que essa questão foi colocada, e o Tribunal assentou exatamente neste sentido. Foi objeto de discussão na Turma. Precisamente porque havia acusação de corrêus; é que se tinha que fazer uma distinção. Isso compõe exatamente o clássico modelo de contraditório e ampla defesa no Direito Penal. É isso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Obrigado! Porém, como é a regra geral, um corrêu coloca a culpa no outro corrêu. E aí nós vamos ficar rodando, porque essa é a regra geral: um corrêu coloca a culpa no outro; e o outro, no um. Dessa forma, vamos ficar em um círculo vicioso aqui: fala um, fala o outro; e o processo não acaba. Assim sendo, esse é o comum. Quem quer que tenha tido atuação em processo penal saberá que, presas diversas pessoas, as culpas são alocadas mutuamente.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Barroso, permite-me só uma observação?

Não é tão comum assim. Eu atuei por dez anos na Justiça Criminal na função de promotor. De cada cem casos, um ou dois corrêus jogam a responsabilidade no outro. Mas me parece aqui que o mais importante é que os corrêus ambos têm interesses antagônicos ao Ministério Público; e o delator tem o mesmo interesse do Ministério Público.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu acho que colocar a culpa um no outro não é antagônico, porque, na medida em que você coloca a culpa no outro, é você que quer se exonerar. Você quer que o Ministério Público se convença de que é o outro, e não você.

Mas, continuando, o Código de Processo Penal não tem uma linha, ou uma letra sequer, dizendo que o colaborador premiado fala antes, e o outro fala depois. Aí veio a Lei de Organização Criminosa, a Lei nº 12.850/2013, que disciplinou minuciosamente a colaboração premiada. Também não há uma linha sobre isso. A lei específica também não previu.

HC 166373 / PR

Se, em outros países há lei prevendo, acho que se deve cumprir a lei; mas aqui entre nós não existe essa previsão legal.

O Direito Penal é um ramo do Direito em que vigora uma legalidade estrita, porque traria imensa insegurança jurídica descobrirem-se nulidades que não têm previsão legal, e ainda por cima, dando-se efeito retroativo.

Dessa forma, em primeiro lugar, não é assim, porque a lei não prevê que seja assim.

2. Não houve comprovação de prejuízo

Em segundo lugar, não houve comprovação de prejuízo. A norma central do regime de nulidades no Direito brasileiro – provavelmente, no Direito mundial – é que não há nulidade onde não há prejuízo.

Lembrava ontem o Ministro Luiz Edson Fachin a expressão francesa clássica: *Pas de nullité sans grief*. Isso está consignado expressamente no art. 563 do Código de Processo Penal:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é torrencial e pacífica. O impetrante não traz um argumento objetivo sequer para demonstrar o prejuízo que teria sofrido. O que o colaborador premiado disse, em alegações finais, que ele já não sabia e de que, conseqüentemente, não pôde se defender?

Aliás, em rigor técnico, sequer em tese pode haver prejuízo decorrente da ausência de concessão de prazo sucessivo. É que, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei de Organização Criminosa, que cuida da colaboração premiada:

"Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador."

O que o agente colaborador diz não vale nada se não for corroborado por provas, as quais, no momento em que chegam as alegações finais, ou já estão nos autos, ou não existem. Se, por acaso,

HC 166373 / PR

aparecerem na fase de alegações finais, tem-se que abrir novo prazo, como aconteceu aqui, sendo que as novas provas não foram trazidas pelos colaboradores premiados.

Portanto, não há nem em tese prejuízo, porque não é possível fundamentar uma condenação com base na colaboração premiada, como ficou documentado por este Tribunal, em acórdão que foi o *leading case* da matéria, da relatoria do Presidente, Ministro Dias Toffoli, em que se assentou que os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório.

Então, o que o colaborador premiado fala sozinho não vale nada. O juiz não pode ter condenado com base na palavra do colaborador premiado, e sim com base nas provas que ele tenha aportado e que estarão nos autos. Incide aqui também a jurisprudência antiga, pacífica e tradicional do Supremo de que não se proclama nulidade sem demonstração cabal da existência de prejuízo.

3. A introdução de uma regra nova, mesmo que por via jurisprudencial, somente pode produzir efeitos prospectivos

Em terceiro lugar, ainda que em *obiter dictum* se quisesse dizer que este deveria ser o procedimento – mas não é porque a lei não o prevê –, ainda que, por criação jurisprudencial, se quisesse prever essa nova ordem, o que preciso dizer é que, se for favorável ao réu, é perfeitamente compatível com meu modo de pensar o Direito. É legítima uma interpretação criativa para contemplar uma situação nova. Porém, evidentemente, uma interpretação que dá um sentido novo ao Direito vigente, sem previsão normativa expressa – e, de certa forma, superando a literalidade do art. 2º do CPP –, só poderia valer para frente.

Se a maioria do Tribunal se inclinasse por dizer: "Daqui para frente, consideramos que realiza mais adequadamente o mandamento constitucional da ampla defesa que o réu não colaborador premiado fale depois do colaborador premiado", não tenho dificuldades com isso. O

HC 166373 / PR

legislador deveria ter feito, não o fez porque não o quis. Se o Judiciário quisesse criar essa previsão nova, a qual não existia, acho que é uma interpretação construtiva, criativa e defensável e, se a maioria dos Ministros assim entender, não me oponho, mas penso que não se pode fazer isso retroativamente, isto é, anular processos pretéritos com base em uma norma processual nova.

E diz o art. 2º do Código de Processo Penal, na sua textualidade: "a lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Jurisprudência criativa que prevê algo que não estava na lei equivale a lei processual nova e que não invalida o que foi realizado anteriormente. E há precedentes bem específicos deste Tribunal dizendo exatamente o que eu acabo de afirmar.

No julgamento do HC 127.900, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, de 3 de março de 2016, discutia-se a incidência do art. 400 do Código de Processo Penal, que havia transferido o interrogatório do início para o fim do procedimento, nos feitos militares, e ali se decidiu:

"6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado."

Nessa mesma discussão, diversos Ministros se manifestaram no mesmo sentido: O de que não era possível retroagir.

E aqui transcrevo novamente passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes (estamos antes de agosto de 2016):

"A mim me parece que nesse sentido, veja-se, o risco não está só no processo militar. Mesmo os processos antigos, já julgados, serão passíveis de revisão, porque estaríamos a dizer que esse procedimento... E, claro, os autores, como o Presidente acaba de sinalizar, fizeram nessa perspectiva, de que atenderia, de forma mais adequada, ao princípio do contraditório e da ampla defesa - o ministro Celso também já ressaltou esse aspecto -,

HC 166373 / PR

que a oitiva se desse, ao final, quando já conhecidos todos os fatos, portanto, parece ser mais condizente. Mas, até pouco tempo, era reconhecido legítimo.

(...)

Portanto, isso teria enorme repercussão sobre todo o sistema e nós, ao invés de estarmos assegurando um quadro de segurança jurídica, estaríamos produzindo um quadro de instabilidade."

É isso mesmo. É só aplicar este precedente. Temos uma norma nova que o Tribunal quer assentar e, portanto, deve-se seguir o padrão que sempre se seguiu: a inovação produz efeitos prospectivos.

IV. CONCLUSÃO

Aqui concluo, Presidente, o meu voto em que procurei demonstrar o quadro em que se situava essa decisão e a repercussão sistêmica que produz, bem como o papel importante que o Supremo desempenha no imaginário da sociedade brasileira para iluminar o caminho do enfrentamento da corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que devastou o País.

Há uma novidade no Brasil, que é uma sociedade civil, que, conforme afirmei, deixou de aceitar o inaceitável e tem uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo, por patriotismo. E essa é a energia que muda paradigmas e empurra a História. A sociedade civil brasileira já mudou. A iniciativa privada brasileira já mudou substancialmente. Há um novo *business* no País que se chama *compliance*. Todas as grandes empresas hoje têm um departamento de *compliance*. A coisa era tão ruim no Brasil que não tinha nem um termo em português para identificar integridade, cumprimento da lei e respeito às regras do jogo. Sendo assim, a iniciativa privada hoje tem no "*compliance*" um departamento importante da sua atuação.

Logo, mudou a sociedade civil, mudou a iniciativa privada e as instituições precisam mudar e corresponder, dentro da Constituição e dentro das leis, a essas demandas importantes da sociedade brasileira. As

HC 166373 / PR

instituições não podem ficar para trás na História. Elas têm que ser capazes de promover o avanço social que estamos tentando promover.

Não é normal que a quarta maior democracia de massas do mundo, que a décima maior economia do mundo, esteja no lote de países mais corruptos do mundo, ostentando um constrangedor 105º lugar no Índice de Corrupção da Transparência Internacional. Eu preciso dizer que acordo envergonhado todos os dias ao pensar nisso. Logo, não podemos ser parceiros da manutenção desse *status quo*. Não é natural desviar dinheiro, não é natural! Nós precisamos romper esse paradigma! Garantismo significa direito de saber do que se é acusado, direito de apresentar defesa, direito de produzir provas, direito de ser julgado por um juiz imparcial e direito a um recurso. Garantismo não significa direito a um processo que não funcione, que não acabe, que sempre produza prescrição. E se, por fatalidade e excepcionalmente, acabar sem produzir prescrição, aí anula-se tudo.

Presidente, voto com o eminente Relator, com a seguinte tese de julgamento, apenas porque gosto de terminar os meus julgados, os meus votos, com uma tese:

“A falta de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais entre corréus, colaboradores e não colaboradores, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”.

Essa é a minha inequívoca convicção. Porém, Presidente, se para construir uma solução intermediária, se optar por dizer, em *obiter dictum*, que o Supremo Tribunal Federal entende que doravante se deve interpretar a legislação no sentido de que o réu não colaborador fale depois do réu colaborador, também aderiria a essa posição intermediária, porque penso que a lei poderia ter feito e que não é uma interpretação absurda, apenas acho que ela não está na legislação. Se a maioria entender que é mais desejável que seja assim, eu me reajustaria para acompanhar a maioria neste sentido, porque, aí, retardar cinco dias o processo, não é grave, mas anular tudo o que já foi feito, é gravíssimo.

HC 166373 / PR

É como voto.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, egrégia Corte, ilustre Representante do Ministério Público, Senhores Advogados presentes e Estudantes.

Eu até conversava aqui com o Ministro Lewandowski que fui surpreendido com essa capacidade de síntese da Ministra Rosa, que lá fora nos avisou que daria esse auxílio à Corte, para que pudéssemos concluir o julgamento. Então, gostaria de, em nome da Corte, agradecer a Vossa Excelência, Ministra Rosa Weber, esse seu poder de síntese.

Senhor Presidente, quero acompanhar, nesse poder de síntese, a Ministra Rosa Weber, mas a acompanho só no poder de síntese. Tenho divergência em relação à tese de fundo.

Basicamente, aqui já se narrou qual é o caso *sub judice*. Então, a verdade é que, limitando-me à questão jurídica, o que se discute é se o delatado tem o direito de falar após o delator na medida em que é colocado como um *sui generis* assistente de acusação, retirando-o da posição do polo passivo, como é, inclusive, autuado nos autos.

Cada um traz aqui o seu enfoque, e para evitar até uma repetição - muito embora, serei breve -, nós estamos no campo do Direito Público, estamos no campo do Direito Penal e do Processo Penal, estamos no campo de normas jurídicas imperativas e indisponíveis pela vontade das partes. Nós estamos no campo da legalidade estrita, em que não cabe ao Judiciário criar um artigo de lei não previsto no ordenamento próprio.

E à luz desse princípio da legalidade, eu questiono: há algum dispositivo legal no Código de Processo Penal, ou na alteração do Código de Processo Penal, ou na Lei de Delação Premiada, que seria a sede própria, *habitat* próprio, dessa regra, que permite ao delatado falar depois do delator? Absolutamente, não.

É claro que o delator e o delatado, ambos, são réus, e o art. 270 é claro ao afirmar que o corréu não pode assumir a assistência de acusação,

HC 166373 / PR

porque isso é um verdadeiro paradoxo. Além de não poder assumir a posição de assistente de acusação, o delator e o delatado se defendem em face do Ministério Público.

E essa figura de ambos os réus se atacarem ao mesmo tempo, se deferem do Ministério Público, como aqui foi destacado, é comuníssima, inclusive no Processo Civil. Quando há uma denúncia da lide por evicção, em que se promove uma ação contra o adquirente que denuncia à lide o alienante, adquirente e alienante, sem prejuízo de litigarem entre si, são considerados litisconsortes passivos. Isso acontece no Processo Civil e acontece também no Processo Penal.

O art. 270 do Código de Processo Penal, aqui já lido, mas é preciso reiterar, porque nós não estamos declarando a inconstitucionalidade desse, diz:

"Art. 270. O corréu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público."

Então, a lei é extremamente clara.

Em segundo lugar, sob um plano, digamos assim, jusfilosófico da assistência, o assistente, quando intervém no processo, não pode atuar em contraste contra a parte assistida, mas o assistente aqui, o delatado, vai atuar em contraste com o Ministério Público. Então, essa assistência não foi prevista em nenhuma lei esparsa, em nenhum Código, porque ela é uma *contradictio in terminis*. Como é que o delatado é assistente do Ministério Público se ele luta contra a acusação? O delatado também tem interesse em ser absolvido evidentemente.

Então, na verdade, o delator e o delatado são corréus e figuram no polo passivo da relação processual e, jamais, poderia ser assistente de acusação. Ele apenas formula sua delação que sequer serve, no meu modo de ver, para o recebimento da denúncia unicamente; e a delação não serve também para a condenação.

Por outro lado, o que se discute aqui? "Não, o delatado tem direito de oferecer alegações finais depois do delator". Por quê? As alegações finais não representam meio de prova nenhum. E é preciso ter em mente

HC 166373 / PR

que, quando o processo chega à fase de alegações finais, delator e delatado já têm conhecimento de tudo o quanto se passou, já analisaram as razões de todas as partes do processo. Depois do interrogatório, vem a defesa prévia, depois, a produção de provas com amplo contraditório. Alegações finais é fato novo? É prova? Não é prova. Alegações finais é um meio de exercer a sua defesa.

E o delatado participa de todas as audiências, de todas as razões expostas durante o curso do processo. Aqui, foi destacado - e é a realidade - que o delatado falou depois do delator, mas, muito embora isso tenha ocorrido no caso concreto, no meu modo de ver, com a devida vênia, a tese que exclui o delatado do polo passivo não encontra respaldo nem na lei, nem na Constituição.

Porque, se é para falar de princípio do devido processo legal e de ampla defesa, como fica a ampla defesa e o devido processo legal do delator que fala primeiro do que o delatado, se, eventualmente, o delatado trazer fato em relação ao delator? Como se responde à indagação de que se ambos se delatarem quem é que fala por último? É claro que eles são réus, estão no polo passivo, que foi a solução alvitada pelo legislador.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Fux, permite um aparte de vinte segundos. Nesse caso, Vossa Excelência, eu sei que retoricamente perguntou como se responde, mas só uma reflexão: na verdade, o delator não precisa se defender de mais nada porque já fez um acordo, ele não está sendo acusado mais, já assumiu a culpa, já aceitou aquilo.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu concordo. Exatamente por isso que ele é réu no processo.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Ministro Fux, só uma pequena observação. Pela minha fundamentação, eles, delator e delatado, em caso de delações recíprocas, passarão a estar na mesma condição. Estarão em igual condição enquanto delatores e delatados recíprocos. Aí, pode ser o prazo comum, sem problema algum.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Sim, mas Vossa Excelência

HC 166373 / PR

acolheu a tese de que o delatado fala depois? Ou eu entendi errado.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Sim, acolhi a tese. E por que acolhi a tese? Porque entendi de aplicar a isonomia: estando em situação desigual, o delatado deve falar por último, e o delator em primeiro lugar. Vossa Excelência trouxe agora o argumento: mas se o delatado também fizer alguma delação?

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Se eles se delatarem reciprocamente.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Aí estarão nas mesmas condições. O fato de o prazo, na delação recíproca, ser comum não trará prejuízo, não os desigualará. Estarão na mesma situação, pela minha fundamentação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu entendi. Contudo, continuo no sentido de que não há nenhuma razão lógica de o delatado, que acompanhou todo o processo, desde a sua fase preambular, ter o direito de falar depois do delator. Eu não consigo entender, pois o Código de Processo Penal estabelece que corréu não pode ser assistente de acusação. Evidentemente, que corréu não é assistente de acusação.

Essa é uma criatividade jurisprudencial e até da advocacia, que eu reverencio, porque é uma habilidade retórica muito grande, mas, na verdade, nada, absolutamente nada, justifica essa benesse, no meu modo de ver, processual para o delatado.

Senhor Presidente - vou juntar voto -, também assento principalmente essa questão de que o juiz é um gestor do processo. Estamos no campo do Direito Público, e, neste campo, só se pode fazer aquilo que está previsto em lei. Não está previsto em lugar nenhum que o delatado fala depois do delator. Essa é uma interpretação...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - O contraditório e a ampla defesa...

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas o contraditório - sinceramente, não consigo compreender -, o contraditório e a ampla defesa se referem a dados que não possam surpreender a parte contrária.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu estava pesquisando

HC 166373 / PR

aqui e vi esse precedente do Ministro Celso. Depois, aparece-me agora um caso muito conhecido de José Dirceu, a cassação de José Dirceu, em razão de acusações que foram dadas *a posteriore*, e o Supremo Tribunal Federal, pela voz do Peluso, Relator, com a experiência dele de juiz, disse: "Isso é uma violação"; presume-se, inclusive, a nulidade. Isso, no procedimento administrativo. Portanto, nenhuma novidade aqui, nenhuma novidade aqui.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É um caso completamente diferente. No caso do Zé Dirceu, eles ouviram, primeiro, as testemunhas de defesa e, depois, as de acusação. Isso evidentemente é uma grosseira violação ao devido processo legal. Não é disso que se trata aqui.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Não é diferente. Vossa Excelência está relatando factualmente de forma diversa. Não é disso que se trata.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Bom, deixa eu só concluir. Eu respeito as opiniões que estão aqui sendo esposadas - senão o julgamento não acaba -, não estamos disputando posição.

Então, basicamente, o juiz é um gestor processual no campo do Direito Público; uma relação jurídica de Direito Público.

Qual é a regra? No campo do Direito Público, o homem público só pode fazer aquilo que está autorizado na lei. Há alguma regra jurídica que autoriza o juiz, procedimentalmente, a conferir ao delatado o direito de falar depois do delator? Juiz do processo não pode criar direitos e deveres, ônus e faculdades se não estiverem previstos na lei. Essa é a minha opinião.

Então, levando-se em conta o princípio da legalidade, a que o juiz deve obedecer, há inexistência de qualquer dispositivo que autorize - muito ao contrário, há uma interdição legal de que o corréu assuma uma posição, ainda que no plano ideal, de assistente de acusação.

Considerando, digamos assim, a essência doutrinária do instituto da assistência, em que o assistente não pode atuar em contraste com a parte assistida, que é o Ministério Público; ele se defende do Ministério Público;

HC 166373 / PR

ou então, o delator delata e não pode mais de defender no processo? Absolutamente, não é assim.

E considerando também que o delatado participou de toda a marcha processual, que não tem surpresa nenhuma, que não haverá nenhuma novidade, as alegações finais não representam meio de prova, então, o delatado já tem o conhecimento de tudo. Na verdade, no meu modo de ver, digamos assim, é até... - com uma certa admiração pela criatividade dos advogados que trouxeram essa filigrana processual para infirmar um processo de tamanha relevância, como sói ser este processo que envolve Operação Lava Jato.

Peço vênica, Senhor Presidente, a todos que entendem contrariamente, e, se efetivamente for a manifestação do Colegiado, eu sou um Colega que me submeto imediatamente à vontade da maioria. Só entendo que devemos ter aquela preocupação descrita na nova Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, qual seja, que os juízes, ao decidirem, devem ter em mente as consequências daquele resultado judicial, seus efeitos sistêmicos etc. E nesse sentido, tenho absoluta certeza de que nós vamos debater aqui uma modulação dessa decisão para que ela não seja capaz de pôr por terra toda uma Operação que visou colocar o País no padrão ético e moral que ele merece, já tendo sido considerado a 8ª economia do mundo.

Por essas razões, Senhor Presidente, acompanho integralmente o minucioso voto do Relator, Ministro Luiz Edson Fachin, sem deixar de manifestar também a minha admiração pela divergência, lavrada pelo Ministro Alexandre de Moraes, pelo voto do Ministro Barroso e pelo voto da Ministra Rosa Weber.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhor Presidente, Senhores Ministros, já tive oportunidade, junto com o Ministro-Relator, Ministro Edson Fachin, com seu brilhantismo, e na companhia dos integrantes da Segunda Turma, pela primeira vez, enfrentar a questão.

Naquela ocasião, disse se tratar de uma matéria inédita, pelo menos nesse campo específico que estamos tratando. Acompanhei a divergência inaugurada pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de se tratar de nulidade relativa, e, naquele caso, considerei que havia sido comprovada.

Por essa razão e a despeito do que disse ali, gostaria de fazer apenas a leitura de algumas passagens para concatenar as minhas ideias e a conclusão.

Neste *habeas*, o qual já se mostrou aqui de maneira muito clara, desde o voto muito percuciente do eminente Ministro-Relator, há uma impetração em benefício de Márcio de Almeida Ferreira, apontando-se com autoridade coatora a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do Ministro Félix Fischer, o qual não conhecera do Recurso Ordinário em *Habeas Corpus*.

O paciente, em conjunto com outros réus, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Neste caso, a defesa alega constrangimento ilegal do paciente pelo ato judicial proferido pelo Juiz da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, consistente na negativa de pleito de concessão de prazos sucessivos: alegações finais pelos corréus colaboradores e corréus delatados.

Faço algumas observações sobre a questão de a defesa alegar a nulidade processual exatamente quanto à ordem de apresentação das alegações finais, distinguindo a situação do corréu colaborador e do

HC 166373 / PR

corréu delatado. Por isso, a situação jurídica que aqui se põe inicialmente, já enfatizado por todos, é a do réu colaborador e as consequências dessa condição processual em que se põe.

A atribuição de consequências favoráveis ao sentenciado, no momento da aplicação da sanção penal pelo Estado-juiz, pelo seu comportamento pós-delitivo, consistente na confissão do crime, é uma medida amplamente adotada no Direito Penal. Porém, introduziu-se a confissão como medida de colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro e em algumas legislações, a qual foi se alterando, até que sobreveio a questão da colaboração premiada, inserida no Direito brasileiro de uma forma muito específica, objeto de todos os votos que me antecederam.

Na sistemática da Lei nº 12.850/2013 - faço referência, porque me parece ser esse o ponto central -, a confissão colaborativa tem como objeto acordo de colaboração premiada, o que distingue de outras situações previstas anteriormente na legislação brasileira, porque não tinham exatamente esta configuração normativa, portanto, uma figura muito diferenciada.

Conforme decidido por este Plenário, o acordo de colaboração premiada é uma espécie de negócio jurídico processual celebrado por termo entre o colaborador e o Ministério público ou autoridade policial.

Estou fazendo transcrição dos textos legais e afirmando: Por essa nova sistemática introduzida em 2013, o réu, quando colaborador, tem interesse na efetividade da comprovação de suas imputações, porque a conquista dos benefícios acordados pode depender exatamente disso.

Nesse sentido, o § 1º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013 estabelece que, em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância e a eficácia da colaboração. Essa eficácia, claro, faz com que o acusado colaborador tenha um interesse específico, no qual se obtém exatamente a comprovação e, portanto, a atuação do réu delatado. O colaborador tem situação jurídica distinta - aqui já enfatizado várias vezes - de outro acusado que não ostente igual condição.

(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA:

1. *Habeas corpus*, com requerimento de liminar, impetrado em benefício de Márcio de Almeida Ferreira, apontando-se como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.9.2018, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, Relator, que não conheceu o recurso ordinário em *habeas corpus* nº 96.059.

Consta dos autos ter sido denunciado o paciente, em conjunto com outros réus, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Alega a defesa constrangimento ilegal do paciente, pelo ato judicial proferido pelo juízo da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba/PR, consistente na negativa do pleito de concessão de prazos sucessivos à apresentação de alegações finais pelos corréus colaboradores e corréus delatados.

2. A então Procuradora-Geral da República, em 9.4.2019, manifestou-se “*pela denegação da ordem*”.

3. Em 28.8.2019, o Relator, Ministro Edson Fachin:

“Com vistas a angariar segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial, nos termos da previsão regimental (artigos 6º, II, “c”, 21, I e XI e 22, “b”, todos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e com base no decidido pelo Tribunal Pleno no HC 143.333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.4.2018, afeto a presente impetração à deliberação do Plenário, cujo objeto traduz controvérsia a merecer exame do colegiado maior sobre prazo sucessivo

HC 166373 / PR

ou simultâneo para apresentação das razões finais por corréus colaboradores e não colaboradores. Desde logo, nos termos do art. 129, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indico preferência para julgamento. Comunique-se à Presidência desta Suprema Corte”.

4. A defesa alega nulidade processual pela não concessão de prazos sucessivos para a apresentação de alegações finais quanto aos corréus colaboradores e os demais corréus.

5. Para o correto deslinde da questão, há de se analisar, inicialmente, a situação jurídica do réu colaborador.

A atribuição de consequências favoráveis ao sentenciado, no momento da aplicação da sanção penal pelo Estado-Juiz, pelo seu comportamento pós-delitivo consistente na confissão do crime, é medida hoje adotada legitimamente pelo Direito Penal.

Confessar significa “*declarar (o acusado) sua responsabilidade em crime que lhe é atribuído*” (GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário Técnico Jurídico. São Paulo: Rideel, 2007, 9ª. Ed., p. 195).

Nesse sentido, após a Reforma de 1984 (Lei n. 7.209/1984), o Código Penal brasileiro, com a norma agora vigente, prescreve, em seu art. 65, inc. III, al. *d*, que a confissão espontânea da autoria do crime, perante autoridade, é circunstância que sempre atua a pena:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

(...)

d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.

6. Introduziu-se a confissão como medida de colaboração premiada no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n. 8.072/1990 (Lei dos crimes hediondos), cujo art. 8º dispõe:

HC 166373 / PR

“Art. 8º. Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços”.

Novas normas sobre a colaboração premiada foram inseridas no direito pátrio, como, por exemplo, a Lei n. 9.034/1995, antiga Lei do crime organizado, a Lei n. 9.613/1998 e a Lei n. 9.807/1999.

Em 2013, na mesma linha, sobreveio o Lei n. 12.850/2013 (atual Lei das organizações criminosas), com a seguinte norma:

“Art. 4º O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados:

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas;

II - a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa;

III - a prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa;

IV - a recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa;

V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada.

§ 1º Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração.

§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos

HC 166373 / PR

autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).

§ 3º O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo, relativos ao colaborador, poderá ser suspenso por até 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional.

§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador:

I - não for o líder da organização criminosa;

II - for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.

§ 5º Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos.

§ 6º O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor.

§ 7º Realizado o acordo na forma do § 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador e de cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação, o qual deverá verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presença de seu defensor.

§ 8º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto.

§ 9º Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.

§ 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as

HC 166373 / PR

provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor.

§ 11. *A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.*

§ 12. *Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial.*

§ 13. *Sempre que possível, o registro dos atos de colaboração será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações.*

§ 14. *Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.*

§ 15. *Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor.*

§ 16. *Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.*

Na sistemática da Lei n. 12.850/2013, a confissão colaborativa deve ser objeto de “*acordo de colaboração premiada*”, espécie de negócio jurídico processual celebrado mediante termo entre o colaborador e o Ministério Público ou a autoridade policial.

Dispõe o art. 6º da Lei n. 12.850/2013:

“Art. 6º O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter:

I - o relato da colaboração e seus possíveis resultados;

II - as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia;

III - a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor;

IV - as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor;

V - a especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário”.

HC 166373 / PR

7. Por essa nova sistemática introduzida pela Lei n. 12.850/2013, o réu, quando colaborador, tem interesse na efetividade da comprovação das suas imputações, pois a conquista dos benefícios acordados pode depender disso.

Nesse sentido, dispõe o § 1º do art. 4º da Lei n. 12.850/2013:

“Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração”.

Portanto, o réu colaborador tem situação jurídica distinta de outro acusado que não ostente igual condição. Ele assume postura pro ativa no processo, porque, além de assumir a autoria do crime, tenta, também, demonstrar a veracidade do teor de suas imputações quanto aos demais corréus.

Diferente do réu que confessa o seu crime, cujo direito será o benefício da atenuante da pena por assumir a prática do delito, o colaborador tem acesso a benefícios maiores, que podem chegar até mesmo ao perdão judicial, desde que eficiente a sua colaboração. Eficiente seria a colaboração que apresente dados que comprove a conduta do corréu. Assim, não basta assumir que praticou o delito, é necessário entregar seus comparsas e suas informações devem ser eficazes para o processo, daí seu interesse na condenação do demais réus.

Trata-se, portanto, de posição processual distinta.

Não parece sem base jurídica a impossibilidade de equiparar a situação processual do réu colaborador, cujas declarações têm carga acusatória quanto aos corréus, assumindo, assim, o colaborador, em parte, papel dotado de carga acusatória, quanto aos demais réus no processo, sob pena de se poder causar prejuízo à defesa.

HC 166373 / PR

8. Saliento que também acolho – como outros já o fizeram – que o réu colaborador tampouco se equipara ao assistente de acusação, pois a esse não é imputada uma conduta criminosa, pelo contrário, ele figura no processo para resguardar os interesses da vítima e, portanto, não detêm os predicados inerentes à defesa, ficando ao ser cargo somente a função acusatória, em auxílio ao titular da ação penal.

De acordo com a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho *“pela posição processual que essas partes assumem, podemos distingui-las em parte acusatória e parte acusada. Em suma: acusador e acusado”* (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 290).

Ocorre que, com o advento da nova legislação, que regulamentou a figura da colaboração premiada, o réu colaborador passou a assumir posição específica e distinta do corréu, por ser acusado da prática de infrações penais, mas também imputar ilícitos aos demais corréus em busca de benefícios legais, o que confere à sua atuação certa carga de acusação.

Assim, diferente do assistente de acusação que ocupa o polo inerente à parte acusadora, o réu colaborador transita com traços de similitude e distinção entres as duas figuras processuais - parte acusatória e parte acusada -, o que lhe distingue de qualquer uma delas.

Aliás, como explicitado por Eugênio Pacelli de Oliveira *“por óbvio, não se haverá de admitir a assistência de co-réu no mesmo processo, nos termos do art. 270 do CPP. Ora, a ressalva parece-nos inteiramente dispensável, uma vez que o co-réu vem a ser parte no processo, e não terceiro interessado”* (de Oliveira, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 420).

Destaque-se, também, que o assistente de acusação é uma figura

HC 166373 / PR

processual facultativa, já o réu colaborador, quando formalmente acusado, deve necessariamente figurar no polo passivo da relação jurídica processual penal.

Ainda nas palavras de Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Por outro lado, quanto à sua importância processual, as partes se distinguem em necessárias e contingentes (Miguel Fenech, Derecho processual penal, Barcelona, Labor, 1952, v. 1, p. 182).

Necesária são aquelas partes ‘cuya constitución está permitida por la ley, pero que no son necesarias para que el proceso exista’. Entre nós, podemos dizer que a única parte contingente é o assistente de acusação. A lei permite sua ingerência no processo (art. 268), mas, com assistente ou sem assistente, o processo existe.

Contingente, portanto” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 292).

Portanto, não há que confundir o réu colaborador com o assistente de acusação, por serem atores processuais distintos, embora ambos carreguem, cada um de acordo com sua específica posição no processo, interesse na condenação dos demais corréus, sendo que esse importante ponto de similitude repercute no direito da defesa dos demais corréus de se manifestar por último.

9. Nessa linha, o Código de Processo Penal, no § 3º do art. 403, é expresso ao dispor que, quando as alegações finais forem escritas (memoriais), o prazo de cinco dias será sucessivo, primeiro para a acusação e depois para a defesa:

“§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença”.

Some-se a isso que o assistente de acusação falará nos autos sempre depois do Ministério Público e antes da defesa:

HC 166373 / PR

“Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

(...)

Art. 403 (...)

§2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa”.

O legislador esclarece ordem escalonada para as manifestações finais no processo penal e coloca por último a defesa, a fim de que ela tenha a oportunidade de conhecer as imputações que lhe são feitas, podendo se contrapor a elas, em nítida aplicação legislativa de adequação da norma ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

Assim, considerando a afirmação anterior de que o réu colaborador tem interesse na efetividade da comprovação das suas imputações, pois a conquista dos benefícios acordados pode depender disso, compõe-se o sistema em que, devido à carga acusatória de sua delação, ele deve se manifestar antes dos demais réus, para que os últimos possam se defender como se mostre necessário.

10. Trata-se de aplicação da analogia, consagrada no art. 3º do Código de Processo Penal:

“A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

A analogia é método de integração do direito, pois o ordenamento jurídico apresenta lacunas a serem preenchidas, consoante ocorre na espécie vertente.

Tem-se das lições de Fernando da Costa Tourinho Filho:

HC 166373 / PR

“Analogia é um princípio jurídico segundo o qual a lei estabelecida para determinado fato a outro se aplica, embora por ela não regulado, dada a semelhança em relação ao primeiro” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 49).

Em sentido semelhante é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, citando Carlos Maximiliano:

“Analogia, por sua vez, é um processo de integração do direito, utilizado para suprimir lacunas. Aplica-se uma norma existente para uma determinada situação a um caso concreto semelhante, para o qual não há qualquer previsão legal. Ensina Carlos Maximiliano que a analogia ‘no sentido primitivo, tradicional, oriundo da Matemática, é uma semelhança de relações. (...) Passar, por inferência, de um assunto a outro de espécie diversa é raciocinar por analogia. Esta se baseia na presunção de que duas coisas que tem entre si um certo número de pontos de semelhança, possam conseqüentemente assemelhar-se quanto a um outro mais. Se entre a hipótese conhecida e a nova a semelhança se encontra em circunstância que se deve reconhecer como essencial, isto é, como aquela da qual dependem todas as conseqüências merecedoras de apreço na questão discutida; ou, por outra, se a circunstância comum aos dois casos, com as conseqüências que da mesma decorrem, é a causa principal de todos os efeitos; o argumento adquire a força de uma indução rigorosa’ (Hermenêutica e aplicação do direito, p. 253)” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 69).

Onde há a mesma razão deve ser aplicado o mesmo direito. E a finalidade da norma que determina que a defesa se manifeste depois da acusação é possibilitar seu conhecimento prévio das imputações que lhe são dirigidas para que possa melhor se defender.

Nessa mesma ordem, considerando que o réu colaborador tem interesse na demonstração das acusações que faz contra os demais

HC 166373 / PR

corrêus, é imperativo que se aplique a mesma razão em benefício da defesa dos corrêus não delatores, assegurando-lhes o direito de se manifestar por último.

11. Ademais, outro importante método integrativo que pode ser utilizado para a correta aplicação do direito ao caso concreto é a interpretação lógico-sistemática.

A interpretação é o processo utilizado para se entender o sentido e a vontade da lei. Ao valer-se de regras gerais para extrair o sentido da lei o Poder Judiciário aplica a interpretação lógica, pois tem o objetivo de alcançar os fins buscados com a sua inclusão no sistema.

A interpretação sistemática conduz a que o intérprete há de reverenciar o direito a ser aplicado em sua relação como as outras as normas que compõem o sistema.

Nas palavras de Rogério Greco, citando Norberto Bobbio:

“Com a interpretação sistêmica, o exegeta analisa o dispositivo legal no sistema no qual ele está contido, e não de forma isolada. Interpreta-o como os olhos voltados para o todo, e não somente para as partes. Bobbio define a interpretação sistêmica como

‘aquela forma de interpretação que tira os argumentos do pressuposto de que as normas de um ordenamento, ou, mais exatamente, de uma parte do ordenamento (como o Direito Privado, o Direito Penal) constituam uma totalidade ordenada (mesmo que depois se deixe um pouco no vazio o que se deve entender com essa expressão), e, portanto, seja lícito esclarecer uma norma deficiente recorrendo ao chamado ‘espírito do sistema’, mesmo indo contra aquilo que resultaria de uma interpretação meramente literal’” (Greco, Rogério. Curso de direito penal. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2013. p. 38).

No caso em análise, o espírito da lei, extraído da razão do sistema processual penal, é determinar que os atores processuais, cujas

HC 166373 / PR

declarações tragam carga acusatória, manifestem-se antes da defesa.

Pelo exposto, a melhor forma de se interpretar o direito a ser aplicado no caso concreto, considerando o sistema em que ele está inserido e a vontade genuína da norma, é que, havendo nos autos réu colaborador, por ter ele interesse na efetividade da comprovação das suas imputações, que atinge práticas delitivas imputadas a outras pessoas, deve ser fixado o prazo sucessivo para que se manifeste antes dos demais réus, a fim de que esses últimos possam se defender em toda a amplitude necessária, assim como ocorre com a acusação e o assistente de acusação, que se manifestam antes da defesa.

12. Chama atenção no caso examinado ter observado o juiz de primeiro grau a correta interpretação e integração das normas no interrogatório dos réus. Adotou, então, como conduta processual ouvir primeiro os corréus colaboradores e depois os demais corréus, mas não utilizou esse mesmo raciocínio quando abriu o prazo para alegações finais.

Importante lembrar que a lógica era a mesma e, portanto, o prazo sucessivo deveria ter sido observado pelo magistrado, mesmo porque não haveria prejuízo para a marcha processual ou atraso no trâmite da ação penal, pois o tempo de tramitação do processo seria dilargado em apenas cinco dias.

13. De se saber se eventual ofensa a essa ordem de oitiva das partes implicaria em mera irregularidade, em nulidade relativa, em nulidade absoluta ou em inexistência do ato, sendo as consequências diferentes para cada uma dessas modalidades:

“Em uma perspectiva de direito privado, pode-se afirmar que, a partir da irregularidade na prática do ato processual, os atos seriam nulos, anuláveis e inexistentes, segundo o grau ou intensidade do vício. Essa é uma distinção clássica no terreno da classificação dos vícios dos atos jurídicos.

HC 166373 / PR

Fiquemos, pois, com a classificação de atos inexistentes e atos nulos, podendo em relação aos últimos, trata-se de nulidade absoluta e de nulidade relativa.

A distinção entre os atos nulos e os atos inexistentes, quanto ao grau de irregularidade (distinção que do ponto de vista conceitual não é muito difícil), apresenta algumas indagações no âmbito dos pressupostos processuais, em razão dos critérios normalmente utilizados para a caracterização de um e outro vício” (de Oliveira, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 694).

“Observe-se que a atipicidade do ato pode gerar-lhe a nulidade (absoluta ou relativa) ou a simples irregularidade.

Pode-se falar, também, em inexistência” (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Manual de processo penal. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 403).

14. Na espécie vertente, a lei não prevê expressamente a obrigação de o juiz ouvir primeiro o réu colaborador para somente depois abrir prazo para os demais réus, ficando a questão sujeita à atividade interpretativa do magistrado.

Por trata-se de interpretação, o julgador deve levar em conta a lógica do sistema processual penal e a aplicação da analogia.

Assim, o vício não provém de violação direta do texto constitucional - o que acarretaria a nulidade absoluta ou a inexistência do ato – ou sequer de violação ao texto infraconstitucional, mas de inobservância de regra processual não escrita, advinda da interpretação incorreta do sistema processual penal.

15. Tem-se que a nulidade relativa *“viola exigência estabelecida pelo ordenamento legal (infraconstitucional), estabelecida no interesse predominante das partes. A formalidade é essencial ao ato, pois visa resguardar interesse de um dos integrantes da relação processual, não tendo um fim em si mesma. Por essa razão, seu desatendimento é capaz de gerar prejuízo, dependendo do caso*

HC 166373 / PR

concreto. O interesse, no entanto, é muito mais da parte do que de ordem pública, e, por isso, a invalidação do ato fica condicionada à demonstração do efetivo prejuízo e à arguição do vício no momento processual oportuno” (Capez, Fernando. Curso de processo penal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 683).

Este Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre temas parecidos com o ora apreciado, tendo concluído exatamente pela configuração da nulidade relativa:

“EMENTA: 1.Defesa: ausência de oportunidade para a Defesa se manifestar sobre o interrogatório de co-réu, no qual fora delatado o paciente: nulidade que, se ocorresse, seria relativa, sanada à falta de arguição oportuna. 2.Trata-se de vício da instrução que, por força do art. 571, II, do C.Pr.Penal, deve ser suscitado no prazo das alegações finais, o que não ocorreu. 3.Habeas corpus indeferido” (HC 91.292, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 24.8.2007, Primeira Turma, decisão unânime – grifos nossos).

“EMENTA: I. Vício na inquirição de testemunhas e deficiência da Defesa: nulidades relativas: preclusão. 1. O vício na inquirição de testemunhas constitui nulidade relativa, que fica preclusa por falta de protesto oportuno, ou seja, quando das alegações finais (C.Pr.Penal, arts. 406; 571, I; e 572; v.g., HHCC 70.615, 1ª T., 21.09.93, Pertence, DJ 15.10.93; 70.415, 2ª T., 10.5.94, Marco Aurélio, DJ 24.06.94; 70.248, 2ª T., 10.05.94, Brossard, DJ 17.06.94). 2. A deficiência da Defesa também constitui nulidade relativa (v.g., HC 66.465, 1ª T., 06.09.88, Moreira, DJ 02.12.88) e, por isso, deveria ser argüida tão logo o novo Defensor tivesse oportunidade para falar nos autos - quando da sustentação oral realizada no julgamento do recurso em sentido estrito -, o que não ocorreu. II. Habeas corpus: reexame de fatos e provas: inviabilidade. No caso, ainda que afastado o óbice da preclusão, somente o profundo revolvimento de fatos e provas permitiria concluir pela suposta deficiência radical da Defesa, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 90.103, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 27.4.2007, Primeira Turma, decisão unânime – grifos nossos).

HC 166373 / PR

“EMENTA: Crime falimentar: inquérito judicial falimentar: necessidade de contraditório prévio à instauração do processo (DL 7.661/45, arts. 105,106 e 107): a ausência de oportunidade para a Defesa se manifestar, pela supressão da fase do art. 106 da antiga Lei de Falências, constitui nulidade relativa, que, no caso, ficou sanada, à falta de alegação quando da Defesa Prévia (C.Pr.Penal, art. 572, caput; 564, III, e, parte final, e IV). Habeas corpus indeferido” (HC 86.586, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10.11.2006, Primeira Turma, decisão unânime – grifos nossos).

16. Portanto, nos casos em que o magistrado não concede prazo sucessivo para o réu colaborador e os demais corréus apresentarem alegações finais, configura-se, na minha compreensão, nulidade relativa. Tanto significa a imprescindibilidade de ser arguida pela parte prejudicada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesse sentido é a doutrina:

“Como se vê, as nulidades relativas devem ser arguidas no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade de falar nos autos. Se não houver arguição tempestiva, a regra é a de se operar a preclusão sobre o ato viciado, que será considerado sanado” (Távora, Nestor e Alecar, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 1.100).

“É por isso que as nulidades relativas, por dependerem de valoração das partes quanto à existência e à consequência do eventual prejuízo, estão sujeitas a prazo preclusivo, quando não alegadas a tempo e modo. Parte-se do pressuposto de que, não havendo alegação do interessado, a não-observância da forma prescrita em lei não teria resultado em qualquer prejuízo para as partes. Assim, é de se prosseguir normalmente com o processo, sem o recuo à fase já ultrapassada” (de Oliveira, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 696).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao

HC 166373 / PR

julgar situação que também tratava de prazo para alegações da defesa:

“HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRAÇÃO NO SUPREMO – PREJUÍZO. O prejuízo da impetração formalizada no Supremo pressupõe o deferimento da ordem na origem. DEFESA PRÉVIA – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade decorrente da falta de abertura para defesa prévia prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal é relativa, precluindo caso não articulada na primeira oportunidade que a parte tenha para falar no processo. PRECATÓRIA – AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO. Uma vez revelando o pronunciamento revisor da sentença proferida a ocorrência de intimação para audiência verificada no Juízo deprecado, descabe versar nulidade” (HC 109.573, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6.2.2018, Primeira Turma, decisão unânime – grifos nossos).

Portanto, tratando-se de nulidade relativa, é imprescindível que a defesa, caso se sinta prejudicada, suscite a questão imediatamente, na primeira oportunidade que se manifestar nos autos, sob pena de convalidação do ato nulo, pela preclusão.

17. Outra importante consequência da nulidade relativa é que deverá ser obrigatoriamente demonstrado o efetivo prejuízo ocorrido, não sendo esse presumido.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“nulidades relativas, aquelas que somente serão reconhecidas caso arguidas pela parte interessada, demonstrando o prejuízo sofrido pela inobservância da formalidade legal prevista para o ato realizado” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 889).

Frise-se que, em certas circunstâncias, o prejuízo pode simplesmente não ocorrer. Tem-se como exemplo um caso em que o juiz concede prazo comum para todos os réus – colaboradores ou não – mas os réus colaboradores não apresentam nenhuma nova tese ou imputação em

HC 166373 / PR

desfavor dos demais réus. Nessa hipótese não haveria prejuízo, pois, apesar do prazo comum, não existia algo no processo que a defesa dos demais réus já não tivesse conhecimento e sobre isso não pudesse ter se manifestado.

Nas palavras de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do antigo pas de nullité sans grief, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)” (de Oliveira, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. p. 693).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não só as nulidades relativas estão sujeitas à demonstração do prejuízo, mas também as nulidades absolutas, porque o *“princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção”* (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).

18. Pelo exposto, o juiz deixar de conferir prazos sucessivos para alegações finais às defesas dos réus colaboradores, que tenham apresentado o pleito, e às dos demais réus poderá acarretar nulidade relativa. Tanto exige demonstração do prejuízo no caso concreto e a alegação na primeira oportunidade que a defesa tiver para falar nos autos, sob pena de preclusão.

19. Na espécie vertente, a defesa alegou a nulidade desde o primeiro momento em que não lhe foi concedido o prazo diferenciado.

HC 166373 / PR

Tem-se da decisão do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR:

“79. As Defesas de Maurício de Oliveira Guedes, Paulo Roberto Gomes Fernandes, Márcio de Almeida Ferreira e de Marivaldo do Rozário Escalfoni alegam vício procedimental porque, segundo eles, o prazo para a apresentação de suas alegações finais só deveria ter sido aberto após a apresentação das alegações finais das Defesas dos acusados colaboradores.

80. De fato, houve requerimentos nesse sentido pelas Defesas e que foi indeferido nos despachos de 24 e 28/11/2017 (eventos 476 e 481).

81. Na linha do exposto no tópico anterior, trata-se de outro requerimento que não tem amparo legal” (Evento 2 – fl. 149).

Entretanto, não foi demonstrado o prejuízo, consoante se pode constatar com clareza das informações prestadas pelo juízo de primeiro:

“Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento 500) foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores os demais réus juntaram suas alegações finais. Maurício de Oliveira Guedes (evento 501), Márcio de Almeida Ferreira (evento 502), Paulo Roberto Gomes Fernandes (evento 503) e Marivaldo do Rozário Escalfoni (evento 504). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozário Escalfoni complementaram suas alegações finais (evento 505).

Após a apresentação das alegações finais os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida na data de 15/01/2018 (evento 509), tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas Defesas (todas de não colaboradores) conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório, com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais.

Os réus colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 519) e Edison Krummenauer (evento 522) complementaram suas alegações finais antes mesmo do MPF (evento 526). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozário Escalfoni, réus não

HC 166373 / PR

colaboradores, complementaram as alegações finais no evento 529. Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira optaram por não complementarem suas alegações finais.

Encaminho em anexo cópia das alegações finais prestadas pelas partes, bem como das decisões que trataram da reabertura do prazo para complementação em decorrência dos documentos apresentados pelas defesas dos réus não colaboradores e das complementações das alegações finais.

Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada julgou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado.

Não há nas alegações finais destes réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo” (Evento 13 – fls. 2/3 – grifos nossos).

Assim, desconfigurada está nulidade processual na espécie vertente, pela ausência de demonstração do prejuízo demonstrada pela atuação processual da parte, que, tendo tido oportunidade de se manifestar após os réus colaboradores, conheceu do que poderia alegar nesta fase processual. Mais ainda, tendo tido uma segunda oportunidade de apresentação de alegações finais, deixou de fazê-lo, o que seria uma escolha processual que a liberdade das partes adota.

20. Anote-se, ainda, como consignei expressamente no julgamento do HC 157.627 AgR, na Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por tratar-se de um caso até então inédito, de matéria ainda não examinada por este Tribunal, me reservava o direito de continuar pensando sobre a matéria.

A pesquisa detalhada da jurisprudência deste Tribunal conduziu-me

HC 166373 / PR

a concluir que, cuidando-se caso líder e de matéria julgada de forma diversa à interpretação literal da lei, tem sido dado efeito prospectivo à decisão, em nome do princípio da segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI, da CR/88), porque as instâncias antecedentes, ao aplicar o direito então vigente, não poderiam antever a interpretação diversa que seria conferida por este Supremo Tribunal Federal.

Quer-se dizer, na data da prática do ato, o juízo competente aplicou a norma da forma como ela vinha sendo considerada válida, sendo que somente agora foi apresentada interpretação diversa por esta última instância.

21. Sobre o efeito prospectivo, tem-se como exemplo o julgamento pelo plenário das ADPFs 395 e 444, Relator Ministro Gilmar Mendes, que tratavam da condução coercitiva. Naquela oportunidade constou expressamente do acórdão:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgar procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Destacam, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato” (DJe 14.6.2018).

O mesmo ocorreu, por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio, no julgamento, também pelo plenário, do HC 127.900, Relator o Ministro Dias Toffoli:

HC 166373 / PR

“Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).

2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa.

3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302).

4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático,

HC 166373 / PR

integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV).

5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal.

6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14.

7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado” (DJe 3.3.2016).

22. Os efeitos da nulidade relativa eventualmente reconhecida devem ser aplicados apenas aos casos que venham a ocorrer após a publicação do acórdão proferido neste *Habeas Corpus*, não sendo o caso de se desconstituir as alegações finais apresentadas até a referida data, mesmo que reconhecida a nulidade relativa.

23. Pelo exposto, **voto no sentido de conhecer o *habeas corpus*, acolher a tese da nulidade mas, no mérito, denegar a ordem.**

(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)

26/09/2019**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ****INCIDÊNCIAS AO VOTO**

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Ministro Luiz Fux, eu diria que todos os dados e fatos já são conhecidos a essa altura, no momento das alegações finais. Entretanto, o legislador preferiu garantir que a acusação fale antes da defesa.

E também não vai haver novidade quanto à acusação, porque não se vai inovar, a não ser reiniciando-se. A legislação cuidou, exatamente, de se permitir que primeiro fale a acusação, com suas alegações, e depois a defesa.

Então, a interpretação que estou compreendendo ser a mais adequada atende à mesma finalidade buscada pela lei, exposta, de maneira expressa, quanto a esta situação.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Na verdade, essa ordem sucessiva é estabelecida, porque o réu é sujeito "do" e "ao" processo. Então, quem tem o ônus primário é o Ministério Público; depois, em nome da ampla defesa, o réu se defende. Neste caso específico, no meu modo de ver, ambos são réus e contra ambos pesa uma acusação.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - A nossa diferença de compreensão é essa.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Mas Vossa Excelência me permite, inclusive, relembrar? Pelo poder de síntese, para auxiliar o trabalho da Corte, a gente acaba se esquecendo de alguns detalhes.

Agora, vejamos nós, o Código de Processo Penal é claro. Aí vem uma lei que regula a delação premiada e fala de todos os direitos, deveres, faculdades e ônus dos delatores e delatados, e não cria essa hipótese que está agora sendo submetida à nossa apreciação de o delatado ter o direito de falar depois do delator.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É por isso que estamos a discutir qual é a interpretação sistêmica. Porque o Direito é um sistema, e, por isso mesmo, precisa de atender sempre - conforme a

HC 166373 / PR

compreensão de cada um, claro - a melhor finalidade buscada pela norma.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Permite-me, Ministra Cármen? Por isso eu lembrei o caso que examinamos no Eleitoral, há poucos dias, em que a legislação infra não contempla as ofensas irrogadas por carro de som, mas contempla-se as mesmas ofensas, desde que irrogadas por outras formas. E se entendeu, em uma interpretação sistêmica, a partir da extração constitucional do direito de resposta, que era cabível sim. Mas são visões diferentes.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Aqui criou-se um privilégio para o delatado, no meu modo de ver.

(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

APARTE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministra Cármen, Vossa Excelência me permite uma rápida observação?

A meu ver, esse caso é exatamente idêntico àquele que julgamos na Segunda Turma.

A defesa apresentou a todos nós, com toda certeza, um alentadíssimo memorial, em que faz a cronologia dos fatos tal como aconteceram. E até demonstra, com o devido respeito, que a meritíssima juíza que prestou informações não as prestou de forma completa. Inclusive há aqui uma transcrição literal do despacho, do dia 15/1/2018, em que o juiz de piso baixou os autos em diligência, em função ou em razão de novos documentos juntados por alguns réus. E ela, de fato, abriu o prazo para que todos se manifestassem, mas aqui exclusivamente no que diz respeito aos novos documentos juntados. Contra essa decisão houve o inconformismo, tempestivo, e esse inconformismo subiu - e, como, de fato, subiu e nós estamos examinando - até o Supremo Tribunal Federal.

O prejuízo, onde é que está? O prejuízo está na condenação sem que se tenha ouvido a parte prejudicada, no caso, os delatados.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Aí, é a interpretação que cada um faz. Eu considereei que aquele caso era diferente deste, por isso mantenho a tese e a fundamentação.

Passo à leitura da parte final, Presidente.

(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor Presidente, o meu voto é brevíssimo, todos conhecem a minha posição. Eu lancei um voto escrito, na Segunda Turma, e mantenho esse entendimento.

Quero dizer, rapidamente, que o contraditório é um dos valores mais caros à civilização ocidental. A própria Bíblia, no Gênesis, já aponta para este direito quando Deus pergunta a Caim, que matou o irmão, onde é que se encontra Abel, que ele havia assassinado. A própria Santa Inquisição, na Idade Média, oferecia as suas vítimas a possibilidade de se arrependerem das supostas heresias antes de mandá-las à fogueira.

O próprio Ministro Alexandre de Moraes, agora de forma muito substancial e vertical, fez um estudo histórico do direito ao contraditório, à ampla defesa, mostrando que ele já se encontra veiculado desde a Magna Carta de 1215, como também da própria Declaração Universal de 1948.

Esse direito encontra-se, com todas as letras, agasalhado no Pacto de São José, no art. 8º, II, **b**, desse documento importante. A Constituição Federal também expressamente garante o direito à ampla defesa e ao contraditório no art. 5º, LIV e LV, e, por isso, quer me parecer, Senhor Presidente, que não importa que a legislação processual ordinária não tenha previsto esta garantia, que é exatamente do réu, não colaborador, falar depois dos réus colaboradores para oferecer a sua defesa e a contradita.

E isso também foi dito aqui por vários Ministros que me antecederam, que a legislação processual é anterior à criação desse novo

HC 166373 / PR

instituto da delação premiada, eufemisticamente, hoje, chamado de colaboração premiada.

Quero dizer ainda, que não me impressiona a gravidade da delação apresentada contra o delatado, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado inúmeras denúncias e trancado vários inquéritos por absoluta falta de comprovação das acusações feitas por delatores.

E não me impressiona também o argumento *ad terrorem* de que vários processos poderão voltar à estaca zero, pois o que está em jogo, a meu ver, é um dos valores mais caros, um dos valores fundantes do Estado Democrático de Direito, que é exatamente o direito ao contraditório e à ampla defesa. Eu ousaria dizer que, sem esses valores, não existe Estado Democrático de Direito.

Penso ter demonstrado, Senhor Presidente, com a rápida leitura que fiz de trechos do memorial ofertado pela defesa - e isto é absolutamente irrefutável - que houve, sim, gravíssimo prejuízo para os pacientes, neste caso, porque o juiz de primeiro grau negou-lhes o direito de falar depois dos delatores. Foi, sim, aberto prazo, mas exclusivamente para que estes, os pacientes, se manifestassem relativamente aos novos documentos juntados. Então, não houve, de forma nenhuma, qualquer tipo de preclusão com relação a essa decisão, a esse inconformismo.

Então, Presidente, singelamente, voto por conceder a ordem para anular o julgamento proferido na Ação Penal 5024266-70.2017.4.04.7000, do Paraná, bem como todos os atos subsequentes ao encerramento da instrução processual, assegurando ao paciente, por consequência, o direito de oferecer novamente os seus memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido aos réus colaboradores.

É como voto.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Também

eu, Presidente, vou pedir todas as vênias ao Ministro Fachin e àqueles que o acompanharam, para sufragar às inteiras o voto do Ministro Alexandre.

Gostaria apenas de dizer - eu gostaria de ter tempo, mas já não tenho e não gostaria de frustrar o voto do Ministro Celso ainda nesta assentada -, que o combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas que não se pode combater a corrupção cometendo crimes.

Eu passaria, se tivesse tempo, mas não o vou fazer, pelas mensagens do *The intercept*, Presidente, para lembrar o que é as entranhas também desse chamado "combate à corrupção", como ele se dá, inclusive, com fenômenos mesmo de corrupção, com corrupção rasteira, baixa. Por exemplo, pedido de passagens, venda de palestras e coisas do tipo.

Não vou repassar isso, mas, em outra oportunidade, poderei fazê-lo.

HC 166373 / PR

Mas é um caso importante. Aqui, estamos falando de uma quantia importante, digna da Lava Jato, decidida pelo Ministro Alexandre de Moraes, é a famosa Fundação Dallagnol, Doutor Alcides: 2,2 bilhões; 1,2 bilhão iria para os clientes do Doutor Carvalhosa. Isso estava no acordo que o Ministro Alexandre suspendeu. Deixa, portanto, cheiro de corrupção, jeito de corrupção, forma de corrupção, matéria de corrupção. Portanto, combate à corrupção tem que se fazer dentro de casa inclusive. Isso é muito sério!

Entretanto, vamos ao ponto.

A questão a ser enfrentada neste *habeas corpus*, já se disse: O paciente foi denunciado, bateu-se pelo reconhecimento do direito de falar por último e não o obteve, tal como no precedente que discutimos na Turma.

Prejuízo? Alguma dúvida de prejuízo? A não ser por um cinismo de pedra, podemos dizer que não há prejuízo aqui, calcário, porque o sujeito foi condenado, e o pediu em todas as instâncias.

De modo que, pedindo todas as vênias, tenho voto escrito sobre a matéria, concedo a ordem nos termos do voto do Ministro Alexandre.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES: Trata-se de *habeas corpus* impetrado em favor de Marcio de Almeida Ferreira, requerendo “a nulidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau, ordenando-se nova abertura de vista à defesa do Paciente após as alegações finais dos réus colaboradores”.

1. Combate à corrupção e os desvios da Operação Lava Jato: uma tragédia anunciada

Antes de iniciar a análise do *Habeas Corpus*, gostaria de tecer alguns comentários acerca do papel exercido por este Supremo Tribunal Federal no contexto dos desdobramentos da Operação Lava Jato nos últimos anos.

Mesmo que neste momento seja fácil adotar a postura de profeta do acontecido, a minha biografia de Juiz Constitucional felizmente revela, de longa data, o enfrentamento dos abusos praticados pela força-tarefa de Curitiba.

A Operação Lava Jato consolidou um importante modelo de combate à macrocriminalidade econômica no Brasil.

Seria impróprio deixar de valorizar as suas conquistas no avanço do paradigma de impunidade sobre a corrupção brasileira. Não me furto de reconhecer esses méritos. É necessário, porém, contextualizar a avaliação que tenho feito sobre os excessos diagnosticados desde as fases iniciais da Operação.

Ainda em março de 2015, poucos meses após os processos da Lava Jato chegarem ao STF, em julgamento pela Segunda Turma, manifestava preocupações com as decretações de prisões preventivas pela 13ª Vara Federal de Curitiba baseadas em fundamentação genérica.

HC 166373 / PR

Em julgamento em que se discutia a possibilidade de extensão de *habeas corpus* concedido ao ex-diretor da Petrobras Renato Duque, por ausência de fundamentação na decretação da preventiva, verbalizei a inquietação com a matéria ao afirmar, já à época, que: *“a mim me parece que estávamos nos aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação de execução, a não ser que haja outras justificativas”*. (HC 125.555-Extn-terceira-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 10.2.2015, DJe 21.5.2015).

A preocupação com a ampliação do uso de prisões cautelares também foi por mim ressaltada no julgamento do AgR na Rcl. 25.362, quando observei que *“temos um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinam em Curitiba e temos de nos posicionar sobre esse tema que, em grande estilo, discorda e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos”*. (Rcl 25.362 AgR, Relator: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.2.2017, DJe 2.8.2017).

Ainda em setembro de 2015, o Tribunal enfrentou o debate acerca da extensão da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar e julgar ações relacionadas à Operação Lava Jato.

Na ocasião, esta Corte decidiu que a competência de Curitiba não tem contornos de universalidade sobre toda e qualquer investigação que envolva utilização de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas, mas, na verdade, restringe-se aos fatos especificamente relacionados a fraudes no Sistema Petrobras.

O Tribunal deixou claro que *“o fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações sobre crimes diversos não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência”* e que *“nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários”* (Inq. 4.130 QO, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 23.9.2015, DJe 3.2.2016).

Este parece ter sido um primeiro e raro momento de lucidez desta Corte quanto às intenções espúrias da força-tarefa no sentido de se

HC 166373 / PR

hastear sobre toda e qualquer investigação relacionada à criminalidade econômica no país.

Ainda no ano de 2016, continuei a insistir em chamar atenção para os excessos na manutenção das prisões provisórias decretadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba.

No julgamento do HC 132.267/PR, que tinha como paciente Marcelo Odebrecht, o próprio relator reconheceu que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantia da ordem pública, mas a segregação cautelar foi mantida pela Segunda Turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal.

Na ocasião, destaquei que: *“mesmo em casos rumorosos, venho ressaltando a jurisprudência do Tribunal a propósito da excepcionalidade da prisão provisória”*. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente.

Nessa quadra, já me era claro que o expediente expansivo da Operação se desdobrava, inclusive, para o campo político. Em debate realizado no Senado Federal, em 4 de dezembro de 2016, manifestei-me sobre os desacertos das indigitadas “10 Medidas Contra a Corrupção”, que, dentre outras hipóteses, proibia a concessão de liminar em *habeas corpus* sem prévia requisição de informações ao promotor ou procurador. Na oportunidade, assentei:

“Tenho impressão de que estamos vivendo momento singular [...] Depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios, a vida continua. O resumo da ópera é: você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó do borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia, calcem as sandálias da humildade”.

Mesmo sujeito às contingências do convencimento do Colegiado nas ações julgadas pela Segunda Turma e pelo Plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de justiça

HC 166373 / PR

criminal negocial que se alastrava pelo país com os acordos de colaboração premiada da Lei 12.850/2013. No emaranhado de acordos negociados pela força-tarefa de Curitiba, podemos afirmar que vimos de tudo.

Ao apreciar a Questão de Ordem na PET 7.074, em que esta Corte discutia os poderes do relator para homologação dos acordos de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo J&F, meu voto trouxe sérias advertências sobre os abusos cometidos pelo *Parquet* na celebração de tais acordos. Na oportunidade, afirmei que estava convicto de que tínhamos que “*evoluir em soluções jurisprudenciais e legislativas reforçando a presunção de inocência, sem impedir as investigações*” (Pet 7.074 QO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2017, DJe 3.5.2018).

Na oportunidade, colhi um inventário de acordos que estipulavam sanções premiaias que ultrapassavam o rol previsto na Lei 12.850/2013 (art. 4º, *caput*, § 2º, e 4º). Ressaltei que, de forma progressiva, novos expedientes foram introduzidos tanto em benefício do colaborador quanto da acusação, conforme as tratativas das partes.

Alguns exemplos paradigmáticos merecem ser rememorados. Dois dos primeiros acordos de colaboração celebrados pela Operação Lava Jato, os de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, previam as seguintes condições, acordadas sem respaldo na legislação: (i) redução da pena de multa; (ii) início do cumprimento da pena privativa de liberdade com a celebração do acordo, independentemente de condenação; (iv) fixação de requisitos menos gravosos para a progressão de regime da pena privativa de liberdade; (v) suspensão de investigações e de procedimentos, após atingido o teto de pena privativa de liberdade em outras sentenças.

Nesses acordos, já se previa o teto da pena privativa de liberdade a ser fixado pelo juiz sentenciante. Em acordos como o de Paulo Roberto Costa, convencionou-se desconsiderar o tempo de prisão processual anterior ao acordo no cálculo dos benefícios para se gerar um incentivo para a rápida adesão à colaboração. O cumprimento antecipado da pena, uma espécie da prisão preventiva voluntária, também passou a ser uma

HC 166373 / PR

previsão padrão. No caso de Sérgio Machado, por exemplo, o colaborador optou por cumprir antecipadamente a pena, depois desistiu – Pet 6.138.

O acordo de Sérgio Machado, a propósito, notabilizou-se por ser talvez o mais engenhoso e inventivo que a Lava Jato pôde ter produzido. O acordo colocava a salvo da recuperação de ativos bens em nome de familiares, especialmente dos filhos do colaborador.

De forma flagrantemente *contra legem*, o acordo previa que o Ministério Público se comprometia a postular que as sentenças em ações de improbidade administrativa ajuizadas contra o colaborador teriam natureza meramente declaratória. A mesma avença previa ainda a suspensão do prazo prescricional por 10 (dez) anos, apesar de a Lei 12.850/2013 limitar a, no máximo, 6 (seis) meses.

Complemento esse inventário com outras pérolas. O ciclo de engenhosidades parece ter atingido o seu ápice na previsão de novos regimes de execução de pena privativa de liberdade não imaginados pelo legislador.

O mesmo acordo de Sérgio Machado previa a “obrigação” de o delator cumprir a sentença de prisão em sua própria residência particular durante o período negociado, sendo-lhe permitido sair da residência, em oito dias por ano, por um período de seis horas contínuas.

O acordo continha como anexo um rol de 27 amigos e familiares que poderiam visitar a residência. Já o acordo de João Cerqueira de Santana Filho estipulava que o réu deveria ficar apenas das 20h às 6h em sua casa, sendo autorizadas viagens para o exterior para tratamentos de saúde.

Havia tanta naturalidade na criação dos novos regimes de detenção que a “Orientação conjunta 1/2018: acordos de colaboração premiada do Ministério Público Federal”, ao prever as penas aplicáveis ao colaborador, ressaltava que, “em caso da previsão de regimes diferenciados, suas regras devem ser detalhadas no acordo”. (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Orientação conjunta n. 1/2018: acordos de colaboração premiada**. 2018, p. 10).

Diante de todas essas constatações, no julgamento da referida PET

HC 166373 / PR

7.074-QO, em meu voto, mesmo sem deixar de reconhecer os avanços que a Operação trouxera para o combate à corrupção no país, externalizei com veemência as minhas recalcitrâncias quanto às verdadeiras finalidades dos membros da força-tarefa. Nesse sentido, destaquei à época que:

A preocupação [da Operação Lava-Jato] em produzir volume de investigações, com ou sem futuro, parece ter-se tornado, com as vênias de estilo, ou sem vênias, um dos objetivos do Grupo de Trabalho da Procuradoria-Geral da República.

(...) Os objetivos da Lava Jato não são imediatamente políticos. A disputa é por poder entre Poderes do Estado, inclusive subjugando o Judiciário, e não se está percebendo isso! Está-se submetendo o Judiciário agora ao crivo da Procuradoria, inclusive essas ações que são enjambradas para amedrontar magistrados.

(...) **Para além de vaidades pessoais, está em formação um quadro que permite que o Processo Penal domine o jogo político.** Complementados pelo tapetão eleitoral costurado pela lei da ficha limpa, as investigações de macrocriminalidade das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do País; basta abrir um inquérito sem controle.

Faço uma observação de que essas finalidades políticas e eleitorais tornaram-se evidentes com as revelações do *The Intercept*. Isso fica claro quando Dallagnol diz que ajudaria se “o MPF lançar um candidato por estado”. (disponível em: <https://theintercept.com/2019/09/03/deltan-senado-candidato/>). É um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho. Vejam: **esse seria o Partido dos Procuradores, um projeto político.**

No último ano, as censuras feitas por mim parecem ter se exacerbado diante do escancaramento dos desvios cometidos. Já alertava aqui, com alguma frequência, sobre o comportamento ardiloso com que os procuradores conduziam as investigações, em clara afronta aos limites

HC 166373 / PR

da legalidade.

Na apreciação do HC 143.333/SP, impetrado por Antônio Palocci, dediquei parte do meu voto a denunciar que a corrupção já havia chegado à Procuradoria. Destacando os detalhes dos episódios de Marcelo Miller, afirmei:

Não queria falar sobre isso mais uma vez, Doutora Raquel, mas a corrupção já entrou na Lava Jato pela Procuradoria, ou alguém tem dúvida do episódio – hoje está nos jornais – da atuação de Fernanda Tórtima e Marcelo Miller? É um clássico de corrupção. Isso tem que ser investigado e tem que ser dito. Veja, na medida em que vamos fechando o sistema e empoderando esses nichos, nós estamos dando azo. E eu estou dizendo que sou mau profeta. Eu falei aqui daquele acordo, na semana seguinte eclodiu aquela fita, agora os jornais de hoje noticiam que a JBS entrou nos Estados Unidos contra Trench Rossi Watanabe, pedindo indenização. É um caso seríssimo. As consequências políticas da opção que estamos fazendo são extremamente graves, porque nós perdemos o controle do sistema, o que decidirem será.

Ainda ontem eu relatava na Turma, Presidente – estou mandando a Vossa Excelência amanhã –, o episódio do auxílio-moradia dos juízes no Rio, em que um dos requerentes é o Doutor Bretas. E o que aconteceu nesse processo? Não estamos falando só de desvios, Presidente, que vão se acumulando, dessa gente empoderada que está aí. Um processo movido pelo Paulo Espírito Santo, Bretas e outros juízes, no Rio de Janeiro, perante um colega seu, para ganhar benefício de auxílio-moradia, embora vedado pelo CNJ, houve a liminar concedida e, depois, o mérito. A AGU não recorreu, também não houve recurso de ofício, e deram o processo como trânsito em julgado. Vejam o empoderamento que está acontecendo, Presidente, isso o pouco que a gente sabe, na conversa com os advogados, que certamente têm todos os seus cuidados em relação a isso.

(...) Não preciso adivinhar, isto já está prenhe de corrupção, no verdadeiro sentido da palavra. Quando vi esses

HC 166373 / PR

dias que o Doutor Marcelo Miller recebeu um montante de indenização por conta daquele grampo do escritório, pensei: A Procuradoria é tão ágil para pedir indisponibilidade de bens de todo mundo, por que ainda não fez em relação ao Doutor Marcelo Miller? A sua prisão preventiva foi indeferida pelo Ministro Fachin, não houve recurso, mas é um caso sério, é um caso sério de corrupção! Não tem outra palavra! E isto está sendo alimentado por esse empoderamento, porque não se faz revisão. Isto é muito sério, Presidente. (HC 143.333, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 12.4.2018, DJe 26-03-2019).

Em 16 de março de 2019, ainda antes de serem reveladas as mensagens do *The Intercept*, o Tribunal julgou o Inq. 4.435-Quarto-Agr, no qual se discutia a extensão da competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais, prevista no inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal e no inciso II do artigo 35 do Código Eleitoral. (Inq. 4.435 AgR-quarto, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, DJe 21.8.2019).

Na oportunidade, busquei deixar claro que a tentativa do Ministério Público de mudar a competência da Justiça Eleitoral – a qual permanecia incólume em todas as Constituições brasileiras – representava um verdadeiro projeto de poder. Ressaltei:

É preciso o combate à corrupção dentro do Estado de Direito. **Não se pode combater a corrupção cometendo crimes, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações.** Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias brasileiras. Esquadrão da morte é fruto disto. É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito” (Inq 4.435 AgR-quarto, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14.3.2019, DJe 21.8.2019).

HC 166373 / PR

Mais recentemente, os desvios de finalidades da Operação foram diagnosticados em acordo que procuradores firmaram com representantes do governo dos EUA, para a criação da chamada “Fundação Dallagnol” a partir de R\$ 2,5 bilhões recuperados da Petrobras. Uma das cláusulas do acordo previa que metade do dinheiro que seria destinado ao Brasil teria como finalidade a *"satisfação de eventuais condenações ou acordos com acionistas que investiram no mercado acionário brasileiro (B3) e ajuizaram ação de reparação, inclusive arbitragens, até a data de 8 de outubro de 2017"*.

Curiosamente, à época já tramitava na Câmara de Arbitragem do Mercado, da B3, a bolsa de valores de São Paulo, um procedimento arbitral de interesse dos sócios minoritários que tinham como advogado o Dr. Modesto Carvalhosa.

Na decisão do Min. Alexandre de Moraes de 17.09.2019 que homologou acordo que destina R\$ 2,6 bilhões do Fundo da Lava Jato para a Amazônia e para a educação, o relator destacou a ilicitude da cláusula que destinava parte da verba à indenização dos acionistas minoritários. Cita-se trecho da decisão:

“Importante, ainda, ressaltar a ilegal previsão de reserva de metade do valor depositado pela Petrobras para eventuais pagamentos a acionistas minoritários da própria empresa.

Mais uma vez, reitere-se, por se tratar de receita pública, não poderia ter destinação diversa do Tesouro, sendo apropriada por particulares a título de satisfazer pretensão que se deduz em face da Petrobras, e não da União, que tem direito a esse montante em razão da sua personalidade de direito público.

Além disso, caso se autorizasse a realização desses pagamentos, teríamos uma situação em que a multa paga pela Petrobras estaria sendo utilizada para a satisfação de passivo da mesma Petrobras, o que foi expressamente vedado no acordo firmado pela empresa com as autoridades norte-americanas.

À luz do ordenamento brasileiro, tais pagamentos seriam ilegais. **Os acionistas minoritários fazem parte do quadro social da Petrobras e se consorciaram a essa na fruição dos ônus**

HC 166373 / PR

e bônus da atividade empresarial. Nesse momento, a empresa se vê na contingência de internalizar severas perdas financeiras em razão da responsabilidade perante terceiros por esquemas criminosos dos quais foi vítima, como no caso da multa arbitrada em acordos firmados nos EUA. Se sócios minoritários, assumindo a roupagem de terceiros, puderem minorar suas perdas pela constrição dos valores aqui tratados, a Petrobras será desproporcionalmente prejudicada, pois: (a) esse trânsito de valores para acionistas pode caracterizar confusão patrimonial; (b) ela também foi vítima de ilícitos investigados no Brasil e no exterior”.

Esse breve levantamento jurisprudencial forma a minha consciência de que, desde as fases iniciais da Operação, exerci, de forma responsável, o controle jurisdicional dos atos praticados pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário relacionados à apuração de fraudes no Sistema Petrobras.

2. A necessidade de reconstrução do sistema de justiça criminal brasileiro: a rejeição à indulgência

Ao contrário do que se poderia imaginar, **nenhum projeto de combate à corrupção estrutural está imune a abusos de poder por parte dos imbuídos da tarefa persecutória.** O tratamento indulgente para com os desvios de legalidade cometidos pelos agentes do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário não se mostra compatível com um sistema de Estado de Direito. Precisamos aprender e progredir com os nossos equívocos do passado.

As mensagens divulgadas pelo Portal *The Intercept* e pelos portais parceiros revelam com bastante clareza os estratagemas e os atalhos adotados pelos membros do MP e do Judiciário para superar a divisão funcional entre defesa e acusação.

A mim não restam dúvidas de que o Juiz Sérgio Moro atuou como

HC 166373 / PR

verdadeiro Chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. **Quem acha que isso é normal, certamente não está lendo a Constituição e nem o nosso Código de Processo Penal.**

No curso de um dos processos contra o ex-presidente Lula, o então Juiz Sérgio Moro espontaneamente informou a Deltan Dallagnol a existência de uma suposta fonte que poderia ter informações sobre a transferência de imóveis de um dos filhos do réu. O magistrado diz ao procurador:

“Entao. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodado por ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de escrituras para transferências de propriedade de um dos filhos do ex Presidente. Aparentemente a pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou entao repassando. A fonte é seria”
(<https://theintercept.com/2019/06/16/vaza-jato-corrupcao-sergio-moro-politica-dallagnol/>)

Outra reportagem publicada pela Veja demonstra que, seguindo a orientação do juiz, Dallagnol procurou as pessoas citadas, mas elas teriam se recusado a colaborar. Em resposta a Moro, o procurador chegou a sugerir que se forjasse uma denúncia anônima para justificar a expedição de uma intimação que obrigasse as testemunhas a depor no Ministério Público.

Ainda na mesma toada de auxílio à acusação, ao apreciar denúncia formulada contra o suposto operador Zwi Skornicki, Moro deu por falta da prova de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro “*Coaching*” da acusação, o juiz avisou a Deltan Dallagnon, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que “*tem um depósito em favor do [Eduardo] Musa e se for por lapso que não foi incluído, ele [Moro] vai*

HC 166373 / PR

receber amanhã e dá tempo” (<https://oglobo.globo.com/brasil/moro-alertou-dallagnol-para-inclusao-de-prova-em-processo-da-lava-jato-diz-revista-23785689>).

O magistrado ainda tinha a função estratégica de sugerir aos procuradores a ordenação das fases da Operação, considerando, é claro, o seu interesse midiático. O quadro de esquizofrenia nas funções do Juiz não chega a passar despercebido pelos próprios membros da força-tarefa. Em mensagem atribuída à Dra. Monique Cheker, a procuradora demonstra ter clareza de que *“Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados”* (Conteúdo disponível em: <https://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jatohttps://theintercept.com/2019/06/09/chat-moro-deltan-telegram-lava-jato>).

Esse núbio entre julgador e polícia pode ter até algum fetiche, até de índole sexual, mas aqui devemos ter moderação! **Julgador é órgão de controle, não é órgão de investigação.**

Como já pontuava anteriormente, com os desdobramentos da Lava Jato, as prisões cautelares foram se ampliando ao completo arrepio da jurisprudência desta Corte que consagra a sua mais absoluta excepcionalidade.

As revelações do *The Intercept* vieram a demonstrar que usavam-se as prisões provisórias como nítido **elemento de tortura**. Custa-me dizer isso no Plenário, mas quem defende tortura não pode ter assento nesta Corte. Essas prisões eram feitas por gente como Dallagnol e como Moro. É preciso que se saiba disso: **o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal.**

Considero oportuno destacar alguns acontecimentos nesse sentido. Em uma das passagens reveladas pelo *The Intercept*, a Força-Tarefa tentava articular com autoridades portuguesas a captura de um foragido. Diante de dificuldades para obter sua localização, o procurador Dr. Diogo Castos de Mattos suscita a ideia de fazer uma operação *“na filha do Raul Schmidt”*. O ousado plano consistiria em imputar a filha como beneficiárias de contas do pai no exterior e, a partir disso, apreender-lhe o

HC 166373 / PR

celular, interceptá-la e pedir as quebras de sigilo fiscal e telemático. (disponível em: <https://theintercept.com/2019/09/10/moro-devassa-filha-investigado/>)

Em outro episódio, fica clara a tentativa dos procuradores de coagirem investigados a delatar. Em mensagem de meados de junho de 2015, Deltan esboça plano para forçar a colaboração do investigado Bernardo Freiburghaus, apontado como operador de propinas da Odebrecht e que, à época, estava na Suíça. Numa conversa, Dallagnol revela a intenção: *"Acho que temos que aditar para bloquear os bens dele na Suíça. Conta, Imóvel e outros ativos. Ir lá e dizer que ele perderá tudo. Colocar ele de joelhos e oferecer redenção. Não tem como ele não pegar"* (<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/08/29/dallagnol-vazou-informacoes-de-investigacoes-para-imprensa-aponta-dialogo.htm?cmpid=copiaecola&cmpid>).

Era notório ainda o intuito espúrio de constranger a atuação desta Corte Constitucional. Em 31 de janeiro de 2017, logo após a triste tragédia que vitimou o saudoso Ministro Teori Zavascki, os procuradores tentaram se associar a grupos políticos para "pressionar" o Tribunal na redistribuição da relatoria dos processos da Lava Jato.

Na época, Deltan orientou os demais membros do MP a informarem "em off" para os jornalistas que a Lava Jato temia *"que Toff, Gilm ou Lew assumam"*. Sabendo que a emissão de uma manifestação oficial da Força Tarefa não seria compatível com os valores do MP, o procurador Dr. Paulo Roberto Galvão suscita a estratégia de utilizar um movimento social com a finalidade de pressionar o STF: *"se houver um movimento social, sem vinculação conosco, contra o sorteio, aí pode ter algum resultado..."* (<https://theintercept.com/2019/08/11/deltan-lava-jato-vemprarua-lobby-stf/>).

Em um dos lamentáveis episódios revelados, após a Polícia Federal ter anexado aos autos de um processo da Lava Jato indícios probatórios envolvendo autoridades com foro no STF, Moro e Deltan Dallagnol, com o apoio da Procuradoria Geral da República, articularam a escolha de qual inquérito o juiz deveria encaminhar para o STF:

HC 166373 / PR

“Falei com Pelella. Ele disse que se resolve com a remessa dos autos (ajustei mandar Odebrecht e disse que manteríamos Zwi e Santana, com o que ele concordou e disse que cindirão e devolverão) e confidenciou que na próxima semana a pressão se transferirá para lá e esquecerão isso. Quanto à decisão de ontem, ele disse que certamente as coisas se acalmarão” (<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/leia-integra-da-troca-de-mensagens-entre-moro-e-deltan-ante-tensao-com-stf.shtml><https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/leia-integra-da-troca-de-mensagens-entre-moro-e-deltan-ante-tensao-com-stf.shtml>).

Para além desses episódios, não há como deixar de reconhecer que a própria dignidade dos membros do Supremo Tribunal Federal foi vilipendiada em diversos episódios desta triste tragédia. Cito aqui as investidas dos membros da força-tarefa para investigar Ministros do STF. Em outro célebre diálogo, Dallagnol, sem o menor pudor, pede ao ex-Chefe de gabinete da PGR o endereço do Presidente Dias Toffoli, a fim de trabalhar em “*dados de inteligência*”:

“Pelella, queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar Vcs. Sei que o competente é o PGR rs, mas talvez possa contribuir com Vcs com alguma informação, acessando umas fontes. Vc conseguiria por favor descobrir o endereço do apto do Toffoli que foi reformado?” (<https://theintercept.com/2019/08/01/deltan-incentivou-cerco-lava-jato-toffoli/>).

Essas insinuações parecem ter atingido o seu grau máximo quando, insatisfeitos com a concessão de ordem em sede de *habeas corpus*, os membros da força-tarefa, em um evidente delírio, elucubram que eu seria beneficiário de contas e cartões de créditos mantidos na Suíça. Na ocasião, a possibilidade de membros do MP apurarem dados a respeito de um Ministro do Supremo é tratada com ironia e desdém: “*vai que tem*

HC 166373 / PR

um para o Gilmar...hehehe”, diz o procurador Roberson Pozzobon. (conteúdo disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/05/politica/1565040839_880977.htm https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/05/politica/1565040839_880977.htm).

As investidas contra mim articulavam-se inclusive a partir de um consórcio entre procuradores e advogados privados. Mensagens vazadas revelam que a procuradora Dra. Thaméa Danelon teria redigido o pedido de impeachment de minha pessoa que viria a ser apresentado ao Senado Federal pelo advogado Modesto Carvalhosa.

Trata-se do mesmo advogado que, como dito anteriormente, patrocinava os interesses de sócios minoritários da Petrobrás que seriam beneficiados pelo acordo do “Fundão da Lava Jato”. Dizia a procuradora: “O Professor Carvalhosa [Modesto Carvalhosa, advogado] vai arguir o impeachment de Gilmar. Ele pediu para eu minutar para ele”. Em resposta, Deltan afirma: “Se quiser olhamos depois de Vc redigir” (<https://reinaldoazevedo.blogosfera.uol.com.br/2019/09/16/ilegal-e-imoral-1-cotada-por-aras-tramou-com-advogado-contramembro-do-stf/>)

Aparentemente, nem os relacionamentos entre os membros desta Suprema Corte escapavam ao conhecimento dos membros da Força-tarefa, que previamente já contavam com os votos e posicionamentos de cada um de nós.

Em uma das anedotas assaz curiosa, Dallagnol conta para os procuradores que “Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou”. Dallagnol teria revelado ainda que os procuradores da Lava Jato podiam contar com ele com o que fosse preciso. Ao saber do diálogo, Moro sagra: “In Fux we trust” (Disponível em: <https://veja.abril.com.br/politica/in-fux-we-trust-disse-moro-a-deltan-em-mensagem-vazadahttps://veja.abril.com.br/politica/in-fux-we-trust-disse-moro-a-deltan-em-mensagem-vazada>).

Até o próprio relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, que sempre se destacou pela sua mais absoluta integridade e isenção nos seus posicionamentos, era tachado como um juiz conivente com a organização criminosa de Curitiba. Em outra conversa, Deltan aponta:

HC 166373 / PR

“Caros, conversei 45 m com o Fachin. Aha uhu o Fachin é nosso”. (disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/aha-uhu-o-fachin-e-nosso-disse-deltan-apos-encontro-com-o-ministro-do-stf><https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/aha-uhu-o-fachin-e-nosso-disse-deltan-apos-encontro-com-o-ministro-do-stf>).

Sequer a Ministra Cármen Lúcia foi poupada. Após tomarem ciência de que uma ADPF ajuizada pela Rede Sustentabilidade houvera sido distribuída à eminente ministra, os procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de *“frouxa”* (disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2019-08-07/procurador-da-lava-jato-chamou-carmen-lucia-de-frouxa-em-mensagens-vazadas.html>).

Ressalta-se que a ação proposta pela Rede Sustentabilidade foi fruto de mais uma parceria entre os membros do MP e um partido político. Os diálogos revelam que o ajuizamento da ação tinha sido alinhado entre Deltan e um parlamentar: *“Randolfe: super topou. Ia passar pra Daniel, assessor jurídico, já ir minutando. Falará hoje com 2 porta-vozes da Rede para encaminhamento, que não depende só dele”*. No dia seguinte o procurador Dr. Diogo Castor confirma que enviou uma *“sugestão”* de minuta ao partido.

A configuração de um quadro sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais de ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas que era utilizada pela Lava Jato, muitas vezes de forma espúria e para enganar o Judiciário e o próprio STF.

As informações revelados dão conta de que a força-tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça e em Mônaco, para obter provas ilícitas com o objetivo de prender alvos considerados prioritários. Após encarcerados preventivamente, muitos deles viriam a se tornar delatores (conteúdo disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/27/lava-jato-usou-provas-ilegais-do-exterior-para-prender-futuros-delatores><https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas->

HC 166373 / PR

[noticias/2019/09/27/lava-jato-usou-provas-ilegais-do-exterior-para-prender-futuros-delatores](#)).

Aqui há ainda passagens de conversas entre membros do MP e o Dr. Roberto Leonel, que depois veio a ser chefe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), em Brasília. Num diálogo com Júlio Noronha, Deltan Dallagnol indaga a respeito de uma pessoal supostamente ligada ao ex-presidente Lula: *“Vcs checaram o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público”*. Em seguida, afirma: *“Pede pro Roberto Leonel dar uma **olhada informal**”*.

Aí então se revela que o Dr. Roberto Leonel atuava como uma *longa manus* do MP dentro do COAF para fazer “pescarias” sem qualquer controle judicial. Em um grupo do qual fazia parte membros do MP e o próprio Leonel, o procurador Athayde Ribeiro da Costa pede: *“Leonel, boa noite. Se possível, tentar ver dps se os seguranças do LULA adquiriram geladeira e fogão da marca BRASTEMP no ano de 2014 que foram parar no apartamento. (...) Será que conseguimos ver isso?”*.

Já em conversa com o próprio Dr. Roberto Leonel, Dallagnol tenta obter acesso a uma lista de contribuintes que haviam aderido um programa de regularização de ativos. Na ocasião, o procurador demonstra clara preocupação com a possibilidade de os superiores de Leonel descobrirem a consulta: *“Roberto se eu pedir para consultar todos os nomes, Vc não tem como assegurar que o Paulo não vá ter acesso?”* (disponível em: <https://theintercept.com/2019/08/18/lava-jato-dados-sigilosos-chefe-coaf/>)

Cabe aqui ressaltar que esses mecanismos obscuros de obtenção de prova foram utilizados em investigações contra réus que tentaram se socorrer com a impetração de *habeas corpus* no Supremo Tribunal Federal, muitos deles sem êxito.

O próprio *Sistema Drousys* da Construtora Odebrecht, que é fonte de elementos indiciários utilizados em diversos inquéritos e ações penais da Lava Jato, fora clandestinamente acessado pelos procuradores pelo menos 1 (um) ano antes da celebração de acordo com os 78 executivos da

HC 166373 / PR

empreiteira, quando o acesso ao sistema teria sido oficialmente concedido ao MP (disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimashttps://noticias.uol.com.br/politica/ultimas>).

Antes de encerrar, merece ser destacada aqui uma soturna realidade: **a vinculação funcional com o MPF foi explorada por esses agentes públicos para a promoção pessoal e para a obtenção de benefícios pecuniários de forma flagrantemente imoral e possivelmente ilícita.**

As reportagens do The Intercept revelam que Deltan Dallagnol teria faturado quase R\$ 400 mil com palestras e livros em 2018. Em um dos *chats*, Dallagnol e seus colegas discutiram o potencial risco para suas imagens ao participarem de eventos realizados por instituições financeiras, mas acabaram decidindo que valia a pena. “*Achamos que há risco sim, mas que o risco tá bem pago rs*”, escreveu Dallagnol em um chat privado com seu colega na força-tarefa, o procurador Roberson Pozzobon, em fevereiro de 2018. (“*Achamos que há risco sim, mas que o risco tá bem pago rs*”, escreveu Dallagnol (<https://theintercept.com/2019/07/26/deltan-encontro-secreto-bancos-xp/>)).

Os segredos internos da Operação Lava Jato, aliás, eram vistos como um ativo a ser monetizado para a promoção pessoal. Em julho de 2017, o então corregedor-geral do Ministério Público Federal, Hindemburgo Chateaubriand Filho chegou a criticar informalmente a conduta do procurador da República Deltan Dallagnol na divulgação de uma palestra que apresentava o seguinte título: “*Operação Lava Jato - Passado, presente e futuro - A Lava Jato na visão de quem está no olho do furacão*”, que seria realizada na Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná) na noite de 4 de julho daquele ano.

Na postagem de divulgação da palestra, Deltan prometia a divulgação de informações sigilosas sobre as investigações: “*Venha conhecer pessoalmente os procuradores da Lava Jato em Curitiba e ficar por dentro do que está acontecendo na operação - em primeira mão!!*”. O constrangimento da situação não escapou a outro membro do grupo: “*virou atração circense A Corregedoria devia suspender Os tentáculos da vaidade*

HC 166373 / PR

e do estrelismo podem agarrar os colegas sutilmente (ou nem tão sutilmente assim". Apesar da notória utilização da imagem da Lava Jato para fins indevidos, a corregedoria do Ministério Público não promoveu a punição dos agentes.

O papel correicional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a propósito, restou claramente debilitado em todos esses episódios. Em uma das situações, o procurador Dr. Diogo Castor confessou ao Corregedor-Geral do MP Dr. Oswaldo Barbosa ter pago pela instalação de um outdoor próximo ao aeroporto de Curitiba para promover a Lava Jato. Após lobby de Deltan junto a Barbosa, o corregedor deu o caso por encerrado, fazendo recair um manto de sigilo sobre a confissão de Castor, o que impediu que este fosse investigado por parte do CNMP. (<https://theintercept.com/2019/08/26/lava-jato-procurador-audios-outdoor/>)

É esse o cenário dantesco de violação à legalidade que nos traz até aqui. Parece-me ter chegado o momento de fazermos uma avaliação crítica da postura desta Corte Constitucional. Eu realmente tenho muito orgulho de, desde o primeiro momento, ter apontado falhas nesse sistema.

Elogiei, elogio e reconheço que de fato a corrupção tinha atingido níveis preocupantes e é preciso que se combata. Mas, insisto: não se pode combater crimes comentando crimes.

3. Questão a ser enfrentada neste *habeas corpus*

No caso em tela, o paciente foi denunciado, em 8.6.2017 juntamente com outros corréus Marivaldo do Rozario Escalfoni, Paulo Roberto Gomes Fernandes, Edison Krummenauer, Mauricio de Oliveira Guedes e Luís Mário da Costa Mattoni. Entre eles, Edison Krummenauer e Luís Mário da Costa Mattoni celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.

Aponta-se que o Juízo de 1ª instância acertadamente estipulou que

HC 166373 / PR

os réus colaboradores fossem ouvidos antes dos demais. Contudo, não adotou lógica semelhante no que diz respeito à ordem das alegações finais, visto que determinou prazo conjunto para todos os réus, colaboradores ou não.

Diante disso, a defesa peticionou para requerer a apresentação das alegações finais somente após a apresentação das alegações finais pelos réus que celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal, em prol de uma proteção efetiva ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

A questão levantada neste habeas corpus vai um pouco além, como já exposto: inexistindo previsão legal — seja no art. 403 do CPP, seja na Lei 12.850/2013 — para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados, há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação?

4. Ampla defesa e direito de falar por último

Consagrado constitucionalmente (art. 5º, LV), o direito à ampla defesa e ao contraditório é uma base fundamental para um julgamento justo e, inclusive, pressuposto para a imparcialidade do julgador.

Tendo em vista que o ônus probatório recai sobre a acusação, pois é quem deve alegar e provar os fatos que imputa, resta evidente que o acusador deve se manifestar em um primeiro momento, iniciar o processo penal e produzir as provas para assentar a culpa do réu.

Assim, para que o exercício da defesa se realize de um modo efetivo, o réu precisa conhecer os contornos da acusação e as provas que foram produzidas em sua confirmação. Nesse sentido, consolida-se, por exemplo, o princípio da correlação entre acusação e sentença, pois o réu não pode ser condenado por crime distinto daquele narrado na inicial acusatória.

A partir de tal lógica, a reforma normativa aportada pela Lei 11.719/2008 deslocou o interrogatório do início para o fim da instrução probatória, consolidando a sua caracterização como instrumento de

HC 166373 / PR

defesa do imputado.

Portanto, trata-se de medida indispensável para a consolidação de um processo penal em conformidade com os ditames constitucionais e convencionais, compatíveis com um Estado democrático de Direito.

5. Premissas teóricas sobre colaboração premiada e o exercício do contraditório pelos corréus delatados

Na colaboração premiada, o réu delator adere à acusação, em troca de um benefício acordado entre as partes e homologado pelo julgador natural, nos termos da Lei 12.850/2013. Ou seja, o delator, em regra, presta contribuições à persecução penal, incriminando eventuais corréus.

Nos termos que assentei quando votei no Inq. 4074 (Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14.8.2018, DJe 17.10.2018), a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), a qual, como regra probatória e de julgamento, impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. É produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas (art. 4º da Lei 12.850/13), ou seja, um ânimo de autoexculpação ou de heteroinculpação (NIEVA FENOLL, Jordi. *La valoración de la prueba*. Madri: Marcial Pons, 2010. p. 244, tradução livre).

Os elementos de prova produzidos em razão de colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica, em relação a provas produzidas por corréus: MITTERMAYER, C. J. *Tratado da prova em matéria criminal*. Tomo II. Rio de Janeiro, 1871, p. 123-125; ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. *Código de Processo Penal brasileiro anotado*. v. III. 5. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. p. 39-40.

Portanto, presumir o interesse do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional

HC 166373 / PR

do juiz. O natural é que o colaborador dê versões o mais próximo o possível do que lhe coloque em uma posição melhor para negociar, não de como os fatos realmente se passaram.

Se dermos aos atos de colaboração força de prova desinteressada, provar fatos não ocorridos será tarefa leve. Bem mais árdua será a tarefa da defesa do delatado, sobre a qual, invertendo-se a presunção constitucional, recairá o ônus da prova da inocência. Nesse cenário, o colaborador não terá motivo para temer o desfazimento do acordo e perda dos benefícios nele entabulados, visto que seus atos de colaboração serão de quase impossível desafio. O direito de defesa dos coimputados delatados precisa ser resguardado para que o processo penal não se torne um mero instrumento ritual para confirmação de hipóteses preconcebidas sem contraditório.

Tanto na doutrina como na jurisprudência, é pacífico o reconhecimento do direito ao confronto dos corréus delatados diante das declarações prestadas pelos colaboradores, pois *“o colaborador deve se submeter a essa ‘prova de fogo’, sendo certo que o contraditório é uma das melhores formas de se descobrir, se não a verdade, ao menos que o colaborador está mentindo ou omitindo parte dos fatos”*. [MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO; QUEIROZ (Org.). *A prova no enfrentamento à macrocriminalidade*. 2. ed. JusPodivm, 2016. p. 238]

Conforme posição reiterada no HC 127.483, *“não resta dúvida, portanto, de que o delatado, no exercício do contraditório, terá o direito de inquirir o colaborador, seja na audiência de interrogatório, seja em audiência especificamente designada para esse fim”*. (STF, HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015, p. 45)

Tal orientação há muito é consolidada no Supremo Tribunal Federal: HC 94.016/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.9.2008; HC 94.601/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 4.8.2008; HC 93.607/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 4.5.2010; HC 101.648/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.5.2010.

HC 166373 / PR

Portanto, os delatados têm direito de fazer perguntas ao corréu delator, exercendo o direito ao confronto como componente inerente ao contraditório efetivo.

Trata-se de sistemática que parte de premissas similares àquelas assentadas em precedentes deste Supremo Tribunal Federal que determinaram o direito de participação dos réus incriminados no momento dos interrogatórios de corréu, para realizar perguntas e exercer o direito ao confronto. Nesse sentido, cito julgado da 2ª Turma, de relatoria do eminente Min. Celso de Mello:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

- Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa. Precedentes.

- **A nulidade radical que afeta os diversos atos de interrogatório judicial, quando provocada pela conduta do magistrado que arbitrariamente nega, ao réu, o direito - por este titularizado - de formular reperguntas aos demais litisconsortes penais passivos**, contamina, por efeito causal, todos os atos subseqüentes do processo, notadamente aqueles de índole probatória, como a inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Precedentes.” (HC 94016 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 1.4.2013)

Partindo-se de lógica semelhante, para efetividade do contraditório, na doutrina, sustenta-se que a oitiva do colaborador deve, necessariamente, ser realizada em momento anterior ao interrogatório dos corréus incriminados. Cito: ARAS, Vladimir. O réu colaborador como testemunha. In: SALGADO; QUEIROZ (Org.). *A prova no enfrentamento à*

HC 166373 / PR

macrocriminalidade. 2. ed. JusPodivm, 2016. p. 214 e 228; BORRI, Luiz A.; SOARES, Rafael J. A readequação dos procedimentos processuais penais em face da colaboração premiada. *Boletim IBCCrim*, n. 296, jul. 2017. p. 16; ROMERO, Eneas. A colaboração premiada. In: AMBOS; ROMERO (Coord.). *Crime organizado*. Marcial Pons, 2017. p. 265; FONSECA, Cibele B. G. *Colaboração premiada*. Del Rey, 2017. p. 164.

A questão levantada neste *habeas corpus* vai um pouco além, como já exposto: inexistindo previsão legal — seja no art. 403 do CPP, seja na Lei 12.850/2013 — para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados, há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação?

Trata-se, portanto, de questão inovadora, não submetida antes ao colegiado deste Supremo Tribunal Federal. Portanto, aqui analisaremos o problema de modo detalhado e profundo.

Sobre a questão, em 27.8.2019, esta Segunda Turma concedeu a ordem no HC 157.627 AgR, por maioria (relator o Ministro Ricardo Lewandowski, acompanhado por mim e pela Ministra Cármen Lúcia, vencido o Ministro Edson Fachin). Nos debates, a Ministra Cármen Lúcia ressaltou que delatores e delatados não estão na mesma condição processual e, portanto, não podem ser tratados de forma igual.

Devo ressaltar que, nos pronunciamentos que me antecederam, foram citados alguns casos de minha relatoria que pretensamente teriam relação com o debate agora em análise por este Plenário.

No parecer do eminente Procurador-Geral da República, faz-se referência ao HC 137.316/PR, ao qual neguei seguimento monocraticamente. Em tal *habeas corpus* efetivamente questionou-se a tese de inversão da ordem de alegações finais de colaboradores e delatados. Contudo, nessa decisão não enfrentei o mérito da questão, ao passo que havia óbice formal ao conhecimento do feito, de modo que, a partir dos elementos constantes naqueles autos e naquele momento processual, não verifiquei ilegalidade manifesta apta a superar o óbice formal.

Já no HC 167.727, em respeito ao direito de defesa, deferi medida liminar para assegurar a produção de diligências complementares, ou

HC 166373 / PR

seja, direito à prova defensiva. Esse era o pedido principal do habeas corpus. Depois da produção das provas, determinei a reabertura do prazo de alegações finais, nos termos do CPP, mas não enfrentei diretamente a questão da ordem das alegações em relação a corréus colaboradores e não-colaboradores.

Por fim, no HC 108.476, mencionado pelo eminente Relator em seu voto, penso não se tratar propriamente de um caso contrário à tese de prazos sucessivos entre colaboradores e delatados. Nesse precedente, o paciente alegava nulidade da sentença pelo fato de a acusação ter se manifestado por último em sede de alegações finais.

Em tal decisão, afastei a tese de nulidade observando que, no caso concreto, o paciente voluntariamente antecipou-se à intimação legal e apresentou alegações finais antes do MP. A defesa adotou essa estratégia porque o MP já havia, em manifestação anterior, pedido a absolvição do paciente. Contudo, nas alegações finais apresentadas posteriormente, o MP acabou pleiteando a condenação do paciente.

Assim, o fundamento da decisão assentou no fato de que o réu teria dado causa à alegada nulidade e que, por uma proibição de comportamento contraditório, não poderia requerê-la posteriormente. Lá destaquei que, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do *venire contra factum proprium*, em abono aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais.

Portanto, não verifico qualquer tese contraditória em decisões anteriores, além de que somente agora neste Plenário é que enfrentamos tal problemática em detalhe e em seu mérito.

Diante das premissas teóricas e do precedente assentado na Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, pode-se firmar que, em prol de um contraditório efetivo, para resguardar a vulnerável posição jurídica dos corréus delatados, **o interrogatório e a apresentação de alegações finais pelo colaborador devem ocorrer em momentos anteriores aos dos delatados.**

Portanto, a abertura de prazo para alegações finais deve se dar de

HC 166373 / PR

modo sucessivo, possibilitando que os corréus delatados se manifestem ao final do processo, tendo conhecimento de todos os elementos incriminatórios produzidos também pelos corréus delatados.

6. Circunstâncias deste caso concreto

Inicialmente, pode-se afirmar que **a alegada nulidade foi apontada no momento pertinente nas alegações finais do paciente (eDoc 12, p. 322-327)** e rebatida na sentença condenatória proferida em 5.2.2018, a partir dos seguintes fundamentos:

“II.6

79. As Defesas de Maurício de Oliveira Guedes, Paulo Roberto Gomes Fernandes, Márcio de Almeida Ferreira e de Marivaldo do Rozário Escalfoni alegam vício procedimental porque, segundo eles, o prazo para a apresentação de suas alegações finais só deveria ter sido aberto após a apresentação das alegações finais das Defesas dos acusados colaboradores.

80. De fato, houve requerimentos nesse sentido pelas Defesas e que foi indeferido nos despachos de 24 e 28/11/2017 (eventos 476 e 481).

81. Na linha do exposto no tópico anterior, trata-se de outro requerimento que não tem amparo legal.

82. A Defesa de acusado colaborador não equivale à Acusação, sendo posições processuais distintas.

83. Não cabe, por outro lado, ao julgador estabelecer hierarquia entre Defesas e acusados. O prazo é comum para alegações finais de todos os defensores.

84. Não cabe mudar o Código de Processo Penal com base em interpretações criativas.

85. Registre-se, por oportuno que tal matéria foi submetida ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo HC 5069625-91.2017.4.04.0000 e que foi indeferido liminarmente.

86. Inexiste, portanto, qualquer vício procedimental no

HC 166373 / PR

ponto.”

Nos autos da ação penal de origem, após encerrada a fase de instrução, o Juízo de piso conferiu às partes prazo para alegações finais **de forma conjunta**, para todos os réus, colaboradores e não colaboradores.

A defesa então peticionou requerendo fosse determinada a intimação da defesa do ora Requerente para a apresentação das alegações finais somente após a apresentação das alegações finais pelos réus que celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.

O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau com os seguintes fundamentos:

“A Defesa de Márcio de Almeida Ferreira requer seja postergada a apresentação de suas alegações finais para data posterior à apresentação das alegações finais pelos acusados que celebraram acordo de colaboração premiada com o MPF (evento 474).

A pretensão da Defesa não está albergada pelo ordenamento jurídico.

Nem o CPP nem a Lei 12850/2013 prevêm benefício da espécie. A ampla defesa e o contraditório foram já plenamente assegurados com a oitiva dos colaboradores em audiência, sujeitos aos questionamentos das partes. Indefiro, assim, o pedido formulado pela Defesa de Márcio de Almeida Ferreira, mantendo o prazo comum para a apresentação das alegações finais pelas Defesas (evento 463).

Ciência à referida Defesa.”

Destaca-se que pedidos semelhantes foram apresentados pela defesa de outros corréus e igualmente indeferidos.

Segundo as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau:

HC 166373 / PR

“Conforme verifica-se do processo eletrônico, os colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 499) e Edison Krummenauer (evento 500) foram os primeiros réus a apresentarem alegações finais. Após a juntada das alegações por parte dos colaboradores os demais réus juntaram suas alegações finais. Maurício de Oliveira Guedes (evento 501), Márcio de Almeida Ferreira (evento 502), Paulo Roberto Gomes Fernandes (evento 503) e Marivaldo do Rozario Escalfoni (evento 504). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni complementaram suas alegações finais (evento 505).

Após a apresentação das alegações finais os autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida na data de 15/01/2018 (evento 509), tendo em vista a juntada de novos documentos por algumas Defesas (todas de não colaboradores) conjuntamente às suas alegações finais, fato que impôs a reabertura do contraditório, com a intimação das partes para eventual complementação de suas alegações finais.

Os réus colaboradores Luís Mário da Costa Mattoni (evento 519) e Edison Krummenauer (evento 522) complementaram suas alegações finais antes mesmo do MPF (evento 526). Paulo Roberto Gomes Fernandes e Marivaldo do Rozario Escalfoni, réus não colaboradores, complementaram as alegações finais no evento 529. Os réus Maurício de Oliveira Guedes e Márcio de Almeida Ferreira optaram por não complementarem suas alegações finais.

(...)

Registro ainda que nas alegações finais apresentadas pelos réus colaboradores neste caso concreto (eventos 499 e 500), como é a praxe em todos os autos envolvendo colaboradores em que esta magistrada julgou, houve argumentos buscando reforçar a colaboração prestada e pedidos para que sejam aplicados os benefícios máximos possíveis previstos no acordo celebrado.

Não há na alegações finais destes réus nenhuma inovação argumentativa, fática ou probatória que possa importar em

HC 166373 / PR

prejuízo às demais defesas, sendo expresso em nossa legislação processual que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo.” (eDoc 13)

Embora nas informações prestadas o juízo de origem afirme que os colaboradores foram “os primeiros réus a apresentarem alegações finais”, pelas datas apontadas nas petições juntadas pela própria autoridade coatora verifica-se que **todas indicam o dia 18 de dezembro de 2017** (eDoc 12, p. 163, 173 e 490), além de que a abertura do prazo foi determinada de modo comum a todos.

Ainda assim, a própria ideia de preclusão tem sido problematizada no direito processual penal a partir de construções doutrinárias contemporâneas. Ao se envolver uma violação de direito fundamental, especialmente diante da importância da ampla defesa e do contraditório na seara penal, questiona-se a tese de que nulidades por violação a direitos fundamentais possam ser convalidadas em razão da preclusão (GLOECKNER, Ricardo. **Uma nova teoria das nulidades: processo penal e instrumentalidade constitucional. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Paraná**, 2010. p. 453-460)

Contudo, como exposto, neste caso tal discussão nem se coloca, ao passo que a alegação da nulidade se deu no momento adequado.

Após a apresentação das “primeiras” alegações finais – repise-se em prazo comum – os **autos foram baixados em diligência por meio de decisão proferida na data de 15.1.2018 (evento 509)**, tendo em vista a juntada de novos documentos pelas defesas de alguns dos corréus.

Nessa segunda oportunidade, o prazo de novas alegações também foi reaberto de forma conjunta, conforme informado pelo juízo de piso em informações prestadas no âmbito do presente HC. Resta evidente, portanto, que **nas duas ocasiões em que foram abertos prazos para alegações finais, isso se deu de forma conjunta.**

Além disso, nesse segundo momento, a abertura de prazo para novas manifestações das partes se deu de modo restrito e vinculado, **somente em relação aos novos documentos juntados anteriormente**. Ou seja, não houve possibilidade de efetivo contraditório em relação às

HC 166373 / PR

alegações finais apresentadas pelos corréus colaboradores no prazo comum anterior.

Nesse sentido, o paciente não teve, de fato, a oportunidade de apresentar as suas alegações finais nos termos de seu pleito, isto é, somente após a apresentação das alegações finais pelos réus que celebraram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal.

Além disso, em suas alegações finais, o colaborador Edison Krummenauer ressaltou diversas imputações feitas a corréus e destacou elementos que lhe embasavam como corroboração (eDoc 12, p. 164-173). **Ou seja, aportando ou não fatos novos, suas alegações finais contribuíram para a tese acusatória.**

Ademais, em prol da proteção efetiva ao contraditório e à ampla defesa, deve-se traçar como regra procedimental a necessidade de apresentação sucessiva das alegações finais de corréus colaboradores e não-colaboradores. Não se pode admitir que, de um modo abstrato, tomemos como regra que somente se houver novos fatos imputados se deva reabrir o prazo para alegações finais aos delatados.

Do mesmo modo que o CPP presume que a acusação pode aportar fatos e argumentos novos em suas alegações finais, ou ao menos consolidar o que foi produzido no processo em uma perspectiva favorável à tese acusatória, o colaborador também adota postura tendente a reforçar ou consolidar os seus argumentos.

7. Dispositivo

Diante do exposto, acompanho a divergência e **concedo a ordem de habeas corpus** para declarar a **nulidade da sentença** e determinar a **reabertura do prazo de alegações finais/memoriais ao paciente**.

É como voto.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, pela ordem. Eu queria fazer uma observação a Vossa Excelência.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quando é das Turmas, admite eventualmente uma dissidência, mas, quando é jurisprudência firmada pelo Plenário, até nós, integrantes da Corte, devemos nos submeter a ela.

Se nós, integrantes da Suprema Corte, submetemo-nos a essa jurisprudência, *a fortiori* toda a magistratura tem que se submeter também, porque o Código é claro hoje em estabelecer que o juiz deve respeitar, em matéria infraconstitucional, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, em matéria constitucional, a jurisprudência do Supremo. De sorte que o julgamento que hoje se encerra irá fixar uma orientação para todos os juízes. Portanto, temos que analisar - com respeito, claro, à manifestação do Colegiado - os aspectos das consequências dessa nossa decisão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

O tema foi afetado ao Plenário exatamente para a fixação, independentemente do caso concreto, de uma tese para ser seguida e orientar todos os juízes e tribunais do País. Vossa Excelência tem toda razão quanto a isso. Eu ainda não estou a proferir posicionamento.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

O Dr. Alcides Martins, representando a Procuradoria-Geral da República, pede a palavra. Concedo a palavra a Sua Excelência.

O SENHOR ALCIDES MARTINS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Agradeço muito a Vossa Excelência, Senhor Ministro Presidente. Se me permite, gostaria de levantar essa questão de ordem, que submeto a este douto Colegiado.

É que ontem, na manifestação que fiz, imaginei a higidez das disposições constantes na lei instrumental, que não foram enfrentados por esta Corte, nem foi negada a sua constitucionalidade em nenhum momento. Disse mais: que, da nulidade, todos concordamos, mas havia a necessidade da ocorrência de prejuízo. Esse prejuízo também que, em princípio, não teria ocorrido, na medida em que a parte teve a oportunidade, num segundo momento, de se manifestar em alegações finais após - eu peço vênias aos eminentes Ministros - a ocorrência deste fato de apresentação simultânea das alegações.

O que me permito rogar à Corte - e também já ontem o fiz -, por essas razões, considerando a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, a insegurança que ela pode vir a gerar, é que haja a modulação da decisão da Corte. Aliás, isso foi ponderado no voto do Ministro Barroso tanto quanto do Ministro Fux, no sentido de que os efeitos dela venham ocorrer *ex nunc*, modulando-se, portanto, como, aliás, a Corte tem, em outras oportunidades, decidido.

Agradeço a Vossa Excelência a compreensão, pedindo desculpa aos eminentes Ministros.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

DEBATE

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, Vossa Excelência ainda não votou, mas eu queria, já que sou o primeiro voto divergente, só pontuar rapidamente alguns fatores.

Primeiro, o *habeas corpus* é uma ação concreta. Nós não estamos aqui em ação direta de inconstitucionalidade. Ou deferimos - e a maioria se forma nesse sentido -, ou não. Ao deferirmos, anula-se a sentença e se retorna.

Então, com todo respeito ao eminente Ministro Barroso, que colocou a questão, e ao eminente Subprocurador-Geral da República, não existe *habeas corpus* em que se defira a ordem com validade só para os casos dali para frente.

Não seria nem uma modulação, mas aqui seria possível se fazer uma análise. Porque o caso concreto tem a peculiaridade que manifestei no meu voto: houve expressa impugnação da defesa no momento processual adequado. Então, parece-me que a isso é possível fixar a tese. Entendemos que isso vale sempre - se a sucessividade não for respeitada -, ou só quando a própria defesa entende que aquilo é seu prejuízo? Para isso, realmente, acho que vale a pena. Fora isso, vale para frente e para trás, obviamente.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me permite?

Nós tínhamos essa questão posta agora, na terça-feira, na Turma. E, com sua argúcia e sensibilidade, a Presidente, a Ministra Cármen Lúcia - simplesmente porque ali nós não tínhamos delatores, mas réus colaboradores -, já no que dizia respeito à ordem de sustentação, fez a inversão, considerando a decisão que se tomara.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Nos casos em que

HC 166373 / PR

tiverem havido, de fato, a sustentação e a arguição, anula-se até esse limite e se volta tudo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exato. Nos demais casos, parece-me - e é o sentido do meu voto - que houve a preclusão. Se não impugnou, a própria defesa entendeu que não houve nenhum prejuízo. Então, nesse caso, não haveria aplicação retroativa. Mas este é um caso concreto.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Nós temos uma peculiaridade também, porque, na verdade, temos, até agora, cinco votos pelo deferimento e seis votos pela tese e faltaria o Presidente realmente votar.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, na condição de Relator, peço a palavra.

O julgamento ainda não se concluiu embora, obviamente, o debate sobre eventual modulação seja relevante. E, é claro, Vossa Excelência está a conduzir a sessão com a maestria de sempre. Em matérias dessa natureza não raro é relevante ter o pronunciamento do quórum do Pleno do Tribunal e, para isso, de alguma forma, foram afetados, como aliás agora o Ministro Ricardo Lewandowski vem de afetar, diversos julgamentos à apreciação do Tribunal.

Portanto, quicá, em tema dessa natureza, fosse relevante colher os votos de todos os integrantes do Tribunal, exatamente porque, como acaba de dizer o Ministro Luiz Fux, a orientação que daqui emergirá será uma orientação vinculante, por assim dizer, para o Judiciário como um todo.

E, em *habeas corpus*, já há aquele precedente da relatoria de Vossa Excelência, que já foi aqui referido, o 127.900, oriundo do Estado do Amazonas, em que, no item VII, aprovou-se, precisamente, a seguinte fixação: ordem denegada com a fixação da seguinte orientação:

A norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum

HC 166373 / PR

aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.

Portanto, fixar orientação em *habeas corpus* não é algo obviamente estranho à deliberação do Plenário.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Aí foi denegada a ordem, aqui foi deferida. Como que nós iríamos deferir a ordem e falarmos para o paciente: Nós deferimos só que não vale para você. Não existe essa possibilidade lógica.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Essa contradição lógica que Vossa Excelência traz é apenas aparente.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Nós já decidimos aqui no sentido de que esse processo tem um aspecto subjetivo e uma objetivação. Já houve casos aqui que nós julgamos diferente.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, se me permite, acho que deveríamos encerrar a votação, e, na verdade, se houver já quatro votos contra a modulação, não precisamos nem aguardar a modulação. Porém, podemos, pelo menos, encerrar a votação; e seguindo o que o Ministro Fachin falou, aguardar a composição plena, para analisar a tese. Acho que seria mais coerente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, eu queria manifestar-me contra a modulação.

Senhor Presidente, estamos examinando um caso concreto, que tem suas balizas bem delimitadas: houve um prejuízo, houve recurso, tempestivo, por parte do réu prejudicado, este é o caso que nós examinamos. Se nós formos adotar a proposta do eminente representante do Ministério Público, teríamos que discutir outras questões, que não foram aferidas na análise desse *habeas corpus*.

Por exemplo, a existência ou não de prejuízo, a existência ou não de recursos tempestivos e outras questões que podem aflorar em uma realidade multifacetada, que sói ocorrer na pluralidade de recursos que tramitam no Judiciário brasileiro. Nós hoje examinamos um caso

HC 166373 / PR

concreto. Não podemos ampliar para começar a discutir outras questões que não foram objeto deste julgamento. Então não cabe, *data venia*, a modulação neste caso.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É um caso bem específico.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, pela ordem. Se existe algo que não se discutiu aqui, se existe alguma coisa aqui que não se debateu, foi o caso concreto. O que se debateu aqui, intensamente, foi a tese.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, perdão, Ministro Fux, eu debati o caso concreto.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Perdão, Ministro Fux, eu debati o caso concreto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu trouxe até à colação a decisão do juiz de primeiro grau que não permitiu que se aditasse as alegações finais, salvo no concernente aos documentos juntados, quer dizer, mais concreto do que isso, *data venia*, acho que é impossível.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, será que alguém aqui desconhece que esse julgamento do Supremo não vai ter uma eficácia que transcende esse caso concreto? É claro que vai ter.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Fux, na verdade, a posição da maioria já foi definida. Quando não houver sucessividade, quando não se permitir a última palavra ao delatado e ele impugnar no momento processual correto, isso gera nulidade. Essa é a posição. Não há o que modular, a meu ver, nesse sentido.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Mas Vossa Excelência está pressupondo que o julgamento já acabou?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, já há seis posições em relação à tese, mas acho que deve votar o Ministro Toffoli, lógico.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhor Presidente, o compromisso do Supremo Tribunal Federal se dá com

HC 166373 / PR

relação aos valores e aos princípios da Constituição, e não com relação aos milhares de casos concretos que estão em tramitação neste Tribunal. Esse é o nosso compromisso. Nós juramos defender a Constituição.

26/09/2019**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

OBSERVAÇÃO**O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):**

Todos estão com os debates bem esclarecidos.

Esta cadeira tem uma responsabilidade maior. O tema foi afetado ao Plenário para que todos participassem, todos votassem. E é assim que tenho agido em vários outros casos.

Eu tenho voto. Também tenho uma proposta de modulação, como fiz também em outros casos. Eu quero fazer a leitura desse voto; e quero fazer exatamente a discussão desse tema.

Adianto que estou concedendo a ordem no caso concreto, mas que vou apresentar, ainda no caso concreto, uma proposta de sua abrangência, até porque esse tema é um dos temas de maior relevância; foi afetado ao Plenário; e é importante que isso tenha a devida análise.

A Presidência precisa emitir seu voto. A hora já está bastante adiantada. É importante que tudo fique muito bem apontado: qual tese vai ser fixada, quais são os casos cuja nulidade será atingida, ou não. Nós não estamos falando só de uma dada operação; estamos falando de vários casos que têm origem em colaborações premiadas, cujos processos são inúmeros.

HC 166373 / PR

Então, temos, não há dúvida nenhuma, que transmitir ao Sistema de Justiça, tanto ao Judiciário quanto às instituições essenciais à Justiça - ministério público, advocacia privada e defensoria pública, nos casos que envolvem as ações criminais -, qual foi a decisão, de forma bastante clara, deste Tribunal, fixando uma tese.

A responsabilidade da cadeira em que tenho a honra de ora estar me impõe isso. Então, já sinalizo que vou acompanhar a divergência, mas vou ler meu voto na próxima sessão, trazendo os limites que entendo serem aqueles a serem colocados na decisão para a fixação da tese.

É essa minha posição.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhor Presidente, só para que fique o registro: o eminente Ministro Celso de Mello trouxe a questão do *quorum*.

No RE 586.453/SE, proferi voto - não participei do julgamento, a Ministra Ellen havia participado -, apenas na questão do *quorum*. Isso ocorreu em 20 de fevereiro de 2013.

Depois, refleti muito sobre o assunto, e a minha posição eu vim a externar nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 377.457 do Paraná. Lembram daqueles embargos de declaração da OAB? O julgamento ocorreu em 19/10/2016. E, aqui, eu me reposicionei na mesma linha dos votos da corrente que ficara minoritária no RE 586.453/SE.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

É importante todas essas discussões, pois estamos diante de um caso que é de importância relevantíssima, **maxima**.

Eu já até anotei o sentido de meu voto, mas tenho proposições a fazer, com sugestões na parte dispositiva e, também, quanto à tese. E, nesse sentido, é da responsabilidade desta Presidência – como fiz em outros casos em que, por razões mais do que justificadas, fiz pedido de vista - para aguardar a integridade da Corte para as questões relevantes. Então, não é o primeiro caso em que estou agindo assim, tenho feito dessa forma.

Adianto que meu voto será pela concessão, mas trarei delimitações a respeito da aplicação. Se a Corte vai acompanhar ou não tais delimitações, é uma outra situação que veremos na próxima sessão, inclusive tendo a oportunidade da presença do Ministro **Marco Aurélio**, que teve que se ausentar em razão da extrapolação do tempo do horário ordinário da sessão, por questões justificadas, para que ele também possa se posicionar sobre tema que é importantíssimo.

É importante que os 11 juízes votem e que os 11 juízes decidam sobre a tese, que deve orientar o Sistema de Justiça de uma maneira bastante clara. Por quê? Porque senão o tema vai ficar voltando a respeito de uma questão aqui, de uma questão ali, de uma alegação acolá.

Então, é essa a razão pela qual vou suspender este julgamento para retomá-lo na próxima sessão.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -

Presidente, eu queria fazer duas observações apenas.

Primeiro, a questão da modulação de efeitos em caso concreto - já observou agora o Ministro Alexandre - tem uma delicadeza, claro, temos feito em relação a RE com repercussão geral, modulando os efeitos para outros casos, mas não para o caso efetivamente apreciado. Por quê? Porque, de fato, do contrário seria, na verdade, dar com uma mão e tirar com a outra.

A outra questão é que, num caso como este, o Ministro Alexandre delineou bem, em que, desde o começo, houve o pedido, o

HC 166373 / PR

próprio aparato judicial assume o risco da revisão, porque, do contrário, os órgãos de recurso viram órgãos lítero-poético recreativos. Não é, Ministro Fux?

Eu citei o exemplo, agora, da Ministra Cármen que, diante da arguição que se colocou perante a sua presidência, ela simplesmente já fez a inversão da ordem. E isso veio numa preliminar. Quer dizer, todos sabem que isso está sendo arguido, o tema é colocado, portanto, já se sabe. Aí se diz: "Não, mas eu não posso agora anular, porque terá a consequência de anular as sentenças". Quer dizer, é um risco que foi devidamente calculado pelo próprio aparato judicial, uma questão que se conhece.

E há muita lenda urbana em torno disso, vamos assumir. As pessoas não trazem números e mentem de forma arrogante. E Vossa Excelência falou bem: a questão não é a Lava Jato, é todo o sistema de Justiça criminal que está sendo discutido. Mas isso virou um tipo de instituição. Quer dizer: "Ah, falou, vai perturbar." E tem gente que treme.

Eu trouxe aqui o *The Intercept*, é constrangedor, inclusive para alguns de nós, porque, de fato, falam mal de nós, chamam a nós de vagabundos. Queriam interferir na distribuição do processo.

HC 166373 / PR

Falam mal do Ministro Fachin. Quer dizer, passam de todos os limites, mentindo, agredindo a Corte. E nós "Ah, temos que atender à Lava Jato". Quer dizer, vamos honrar um pouco as calças que vestimos! Sabe, é o tipo de coisa... Quer dizer, é uma gente que passou de todos os limites.

Agora, é importante que a Procuradoria, com o novo Procurador-Geral, traga um levantamento aqui, faça um levantamento do que está acontecendo no âmbito estadual, com o próprio sistema de Justiça. Porque, toda vez que houver uma decisão, em *habeas corpus*, que envolva anulação em aplicação de lei processual, haverá essa consequência. Por isso que o próprio sistema cria esse modelo de fusíveis.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Gilmar, só uma observação.

No *habeas corpus*, principalmente, a lei - volto a dizer: não há lógica em se conceder e, depois, não se aplicar -, o Código de Processo Penal manda aplicar o efeito extensivo para todos aqueles que estejam na mesma situação. Não há, com todo o respeito, a possibilidade de, depois de discutirmos isso dois dias, falarmos: "Não, foram só ideias jogadas ao vento, mas não se aplica ao *habeas corpus*".

Eu verifico, com todo o respeito - posso até ser convencido na próxima sessão -, que a única modulação possível ou a única discussão é "quem impugnou e quem não impugnou", porque nem foi tratado neste caso, mas já dá um direcionamento.

Agora, feriria "totalmente" a razão de existência do *habeas corpus*, que envolve a liberdade, concedermos e falar: "Não se aplica para os outros em situação igual". Realmente, isso é um argumento *ad terrorem* que vem sendo feito como se o mundo fosse acabar.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vossa Excelência me permite? Se o juiz errou, nós é que vamos consertar aqui? Ele tem que arcar com as consequências. É que nosso ordenamento legal é muito leniente, porque deveria responsabilizar o juiz, salvo se agiu com extrema boa-fé.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Porque senão fica fácil, como o Ministro Gilmar disse, "nulidades, nulidades", porque essa é uma hipótese. Imagine um outro HC com uma outra nulidade. Vamos modular também. Então fica fácil. Fica fácil, nulidade em cima de nulidade, quando chega ao Supremo: "Ah, não, só daqui para frente".

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, apenas para encerrar, gostaria de cumprimentar a iniciativa da Presidência, embora não necessite de cumprimentos, pela serenidade da indicação que faz à relevância da matéria.

E, obviamente, com todo o respeito à divergência, nós estamos aqui discutindo teses e ideias. E, do ponto de vista de fixar orientação em *habeas corpus*, como disse, há esse precedente. E ouvirei, com muito gosto, as ponderações de Vossa Excelência na próxima sessão.

26/09/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

SUSPENSÃO DE JULGAMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Eu só gostaria, antes de terminar a sessão, de fazer a proclamação.

Fica suspenso este julgamento. Vamos readequar para a sequência, na sessão da quarta-feira próxima, primeiro item, já para concluir. É um tema sobre o qual eu gostaria também de me manifestar e de justificar minha posição, como todos os Colegas fizeram. Vai longe a hora, vários de nós já tivemos que adiar compromissos ou cancelá-los.

Gostaria, então, de declarar suspenso este processo. Retomá-lo-emos na próxima sessão.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que concediam a ordem de *habeas corpus*; e dos votos dos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Edson Fachin (Relator), no sentido de denegar a ordem, o julgamento foi suspenso. Não votou, nesta assentada, o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.9.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**V O T O**

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Tem-se em jogo controvérsia alusiva à definição de prazo comum ou sucessivo para apresentação de alegações finais em processo-crime consideradas as figuras de corréus delator e delatado.

As normas processuais são imperativas. Vale dizer: atuam independentemente da vontade das partes. O processo apresenta-se como algo organizado, tendo formas impostas pelo Código respectivo.

No processo-crime, ante ação penal de iniciativa pública, duas são as partes propriamente ditas: o Estado acusador, personificado pelo Ministério Público, presente integrante desse Órgão, e o acusado, ou acusados, caso haja ação plúrima sob o ângulo subjetivo, em decorrência de prática delituosa por diversos agentes. Além dessas duas partes, pode ser admitido a participar da relação processual o assistente da acusação, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal.

Observem a disciplina legal referente às alegações finais. A teor do artigo 403 do citado diploma:

[...]

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

[...]

O § 1º versa a existência de mais de um acusado e revela que o tempo previsto para a defesa de cada qual será individual.

[...]

§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para

HC 166373 / PR

a defesa de cada um será individual.

[...]

Quanto ao assistente do Ministério Público, dispõe o § 2º:

[...]

§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 (dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.

[...]

No § 3º, sinaliza-se a possibilidade de o Juízo, levando em conta a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes – Ministério Público e defesa – o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais.

[...]

§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.

[...]

Sob o ângulo da legislação especial, a Lei nº 8.308/1990, por meio do artigo 11, prevê prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais por acusador e assistente da acusação e o mesmo período, em prazo próprio, para a manifestação de corréus. Eis o preceito:

[...]

Art. 11 - Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas.

HC 166373 / PR

§ 1º - Será comum o prazo do acusador e do assistente, bem como o dos co-réus.

[...]

Na Lei de Drogas – nº 11.343/2006 – tem-se no artigo 57 regra semelhante à do Código de Processo Penal, ou seja, reveladora da apresentação das alegações finais em audiência sucessivamente por acusação e defesa, considerado o tempo de 20 minutos, passível de ser acrescido de 10.

[...]

Art. 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz.

[...]

O Código de Processo Penal Militar é expresso quanto à apresentação de alegações finais escritas em prazo sucessivo de 8 dias para o Ministério Público e a defesa:

[...]

Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.

[...]

HC 166373 / PR

Por último, o Código Eleitoral, mediante o artigo 360, versa prazo sucessivo de 5 dias para cada uma das partes – acusação e defesa – apresentarem as alegações finais.

[...]

Art. 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 (cinco) dias a cada uma das partes - acusação e defesa - para alegações finais.

[...]

Tal regramento esgota em si a matéria. Variação nesse procedimento discrepa, a mais não poder, da organicidade e da certeza que cercam o direito, especialmente o instrumental.

Tem-se o instituto da colaboração premiada, que não é novo, mas, sim, meio de obtenção de provas em contínua evolução. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, ao definir organização criminosa, investigação criminal, meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e procedimento criminal, revela-se o diploma mais minucioso quanto ao tema da delação. A legislação versa parâmetros, nada dispondo sobre a apresentação de alegações finais, com prazos distintos, por delator e delatado. Ambos continuam corréus do mesmo processo-crime, merecendo tratamento igualitário. Mais do que isso, contraria norma expressa imaginar que alcance o delator dupla qualificação no processo, sendo a um só tempo corréu e assistente da acusação. Em primeiro lugar, essa interpretação vai de encontro ao princípio lógico racional do terceiro excluído. Consideradas as partes do processo-crime, tem-se unicamente o Ministério Público a acusar, e o réu ou réus a defenderem-se. A adoção, por corréu, de postura colaborativa não o destitui da posição de acusado, tampouco viabiliza, ausente previsão legal, a distinção de prazos para a apresentação de alegações finais.

O Código de Processo Penal surge pedagógico ao dispor, no artigo

HC 166373 / PR

270:

[...]

Art. 270. O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.

[...]

Se há contraditório no campo da delação, ocorre por meio do acesso e pronunciamento do delatado acerca do acordo formalizado, ou seja, das cláusulas, no que revelado o alcance da delação.

O sigilo a respeito do conteúdo da colaboração premiada, a teor do § 3º do mencionado artigo, deve permanecer, como regra, até o recebimento da denúncia.

[...]

§ 3º O acordo de colaboração premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a denúncia, observado o disposto no art. 5º.

[...]

O preceito trata da cessação do sigilo relativamente ao acordo, assentando o direito do investigado de, recebida a denúncia, conhecer aqueles que o subscreveram, bem assim o próprio conteúdo, viabilizando-se a ampla defesa e o contraditório.

O processo é uma marcha em direção à sentença final. Encerrada a instrução, abre-se margem às alegações finais que, em última análise, hão de guardar sintonia com os elementos coligidos. Manifesta-se, em primeiro lugar, o Ministério Público e, após, tem-se espaço, sem distinção, consideradas as figuras de delator e delatado, para manifestação dos corréus. Em síntese, o delatado não se defende de alegações que possam ser apresentadas pelo corréu delator. Já o terá feito, ou ao menos tido oportunidade de fazê-lo, anteriormente. Mais do que isso, o ofício judicante é vinculado ao direito positivo. O Supremo não legisla; pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o

HC 166373 / PR

delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência.

A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria e, por si só, porquanto originado de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja.

A Lei nº 12.850/2003 é expressa, no artigo 3º, ao defini-la como instrumento de obtenção de provas, assim como o são a ação controlada, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, bem assim o afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, previstos nos incisos do referido artigo. Trata-se de meio extraordinário para chegar-se a provas, no que diz respeito a delitos cometidos.

Não tem natureza de prova. Se tivesse, poderia, isoladamente, embasar a condenação criminal, situação inadmitida no § 16 do artigo 4º da Lei nº 12.850/2003:

Art. 4º [...]

[...]

§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador.

Em síntese, repita-se à exaustão, o que é a delação premiada? Simples depoimento prestado à autoridade, a ser considerado, inclusive sob o ângulo das consequências, na hora devida, pelo órgão julgador, para fins de reconhecimento de benefícios descritos na Lei. Transparece como confissão qualificada pelas informações que podem levar a resultados, também versados no artigo 4º da Lei – identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, revelação da estrutura e da divisão de tarefas do grupo, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades,

HC 166373 / PR

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito dos delitos cometidos e localização de eventual vítima com a integridade física preservada.

Imagine-se, por exemplo, um fato criminoso cuja premissa seja a participação de vários agentes, mas, de imediato, identifique-se apenas um deles. A prevalecer a óptica da distinção, no caso de o identificado, ao depor, revelar a identidade dos demais, ter-se-á, quanto às alegações finais, tratamento diferenciado destes?

Frise-se estar-se julgando a matéria considerado *habeas corpus*. A ação constitucional deságua ou na procedência do inconformismo revelado ou na improcedência, não havendo campo para o meio-termo, para a denominada modulação. Aliás, supor que o novo enfoque apenas terá eficácia a partir da decisão deste Tribunal, em processo de natureza subjetiva, é admitir, de forma clara, que as normas em vigor até aqui não disciplinam o tema e que o Supremo pode substituir-se ao legislador.

Percebam a independência e a harmonia dos Poderes da República – Legislativo, Executivo e Judiciário, e nessa ordem estão no artigo 2º da Lei das leis –, a pressuporem a atuação de cada qual na área que lhe cabe constitucionalmente. Cumpre atentar para a tríplice reserva institucional, sob pena de não se alcançar patamar civilizatório aceitável.

O devido processo legal é observável dentro dos limites da lei. A pretexto de implementá-lo, presente o sistema, não cabe partir para solução que, além de inovadora, considerado tudo que foi realizado até aqui, coloque em risco marcha alvissareira como é a do combate à delinquência do chamado setor do colarinho branco. Quantos e quantos processos foram julgados, impondo-se a condenação e interrompendo-se a prescrição, sem distinguir, nessa fase – que não é de prova ou de impugnação à prova, mas de simples alegações –, réus que terão culpabilidade definida em sentença, compensada sempre a efetividade da colaboração. O momento de delatado pronunciar-se sobre o assacado pelo delator não é o das alegações finais, no que estas surgem a ressaltar – simplesmente ressaltar – os acontecimentos e elementos já documentados no processo.

HC 166373 / PR

Admito que, no campo legiferante, e não no judicante, possa ser implementada a diversidade de prazo para réus – delator e delatado –, sem o defeito da falta de razoabilidade. Mas, observada sempre a almejada segurança jurídica, que venha ato emanado do Congresso Nacional, que venha lei, sempre prévia considerado o procedimento processual. À sociedade não interessa a surpresa na arte de proceder e de julgar, mas, sim, poder imaginar como será e o que será a boa marcha processual, no que assegura a liberdade em sentido maior, ou seja, saber o que pode, ou não, ocorrer na tramitação do processo.

Interpretar é, sim, ato de vontade, mas ato vinculado ao direito aprovado pelos representantes eleitos, sem invencionices de toda ordem, sob pena de prevalecer o critério de plantão. A criação surgida – na dicção de uma grande defesa, reconheço – somente tem uma consequência, e é danosa: a retroação a fase anterior, sem que se possa, porque totalmente estranho ao mundo das normas processuais e procedimentais, concluir configurada nulidade.

Não é demasia lembrar John Steinbeck, no fecho de obra sob o título *O inverno da desesperança*: “Quando uma luz se apaga, é muito mais escuro do que se jamais houvesse brilhado.” Sim, a sociedade vem aplaudindo o sucesso da denominada Operação Lava-Jato. Eis que o mais alto Tribunal do País, o Supremo, em passe revelador de atuação livre, à margem da ordem jurídica, vem dizer que não foi bem assim, que o sucesso se fez contaminado no que se deixou de dar, na seara das alegações finais, tratamento preferencial ao delatado, colocando em plano inferior aquele que, com ele ombreando em termos de imputação, talvez não lhe tenha sido fiel, embora não para ver imperar a justiça, mas para lograr benefícios penais, protegendo, tanto quanto possível, a própria pele.

A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito, em termos de responsabilidade penal, com o famoso “jeitinho brasileiro” e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados “tubarões da República”.

Paga-se um preço por se viver em um Estado de Direito, e esse

HC 166373 / PR

preço, módico, estando ao alcance de todos – reafirmo sempre, pedagogicamente –, é o respeito irrestrito às regras estabelecidas, não sendo demasia lembrar Rui Barbosa quando, recém-proclamada a República, no ano de 1892, ressaltou: “Com a lei, pela lei e dentro da lei; porque fora da lei não há salvação”.

Acompanho o Relator no que indeferiu a ordem.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Eu reitero o que tenho dito em vários momentos: se existe o combate à corrupção, tão necessário ao País, é graças a este Supremo Tribunal Federal, que, juntamente com o Congresso Nacional e os chefes do Poder Executivo, elaboraram pactos republicanos, notadamente em 2004 e 2009, quando presidiam este Supremo Tribunal Federal o Ministro **Nelson Jobim** e o Ministro **Gilmar** Mendes, respectivamente.

Todas as leis que aprimoraram a punição à lavagem de dinheiro, as leis que permitiram a colaboração premiada, as leis de transparência foram previstas nesses pactos com o suporte do Supremo Tribunal Federal. É uma falácia dizer o contrário: que esta Corte atua em sentido contrário. Isso é uma desonestidade intelectual!

Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos, os excessos e a tentativa de criação de poderes e instituições paralelos.

Volto a dizer, se não fosse este Supremo Tribunal Federal, não haveria combate à corrupção no Brasil.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Habeas corpus impetrado em favor de Márcio de Almeida Ferreira no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no HC nº 96.059/PR.

O impetrante sustenta, em suma, que, "ao designar as datas para realização do interrogatório o r. Juízo de 1ª instância acertadamente estipulou que os réus colaboradores fossem ouvidos antes dos demais".

Todavia, "encerrada a instrução, ao conferir às partes prazo para a apresentação das alegações finais o r. Juízo de 1º grau estabeleceu prazo conjunto para todos os réus, colaboradores e não colaboradores".

Alega o impetrante, a propósito, que "a apresentação dos memoriais concomitante às alegações finais de réus delatores viola frontalmente o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório".

Diante disso, requer a concessão da ordem de **habeas corpus** "para reconhecer a nulidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau, ordenando-se nova abertura de vista à defesa do Paciente após as alegações finais dos réus colaboradores".

A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.

É a síntese do caso.

Rememorando o caso, anoto que a questão central colocada nesta impetração é saber se, inexistindo previsão legal — seja no art. 403 do CPP, seja na Lei nº 12.850/13 — quanto à ordem cronológica do oferecimento das alegações finais pelos acusados colaboradores e pelos delatados, configuraria constrangimento ilegal a determinação de prazo comum para ambos.

Conforme adiantei na última assentada, rogando a mais respeitosa **vênia** ao Relator, Ministro **Edson Fachin**, estou acompanhando a

HC 166373 / PR

dissidência capitaneada pelo Ministro **Alexandre de Moraes**.

Passo às premissas de meu voto.

Preliminarmente, há que se restringir a questão da sucessividade ou não das alegações finais **às hipóteses em que houver acordo de colaboração premiada devidamente homologado**.

Com efeito, a Lei nº 12.850/13, ao disciplinar o regime jurídico desse meio de obtenção de prova, instituiu a figura **sui generis** do colaborador premiado, o qual, além da possibilidade de figurar como corréu no mesmo processo em que o delatado, **presta contribuições à persecução penal**, haja vista que, por expressa determinação legal, “nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade” (art. 4º, § 14).

Outrossim, o desate da controvérsia pressupõe que se compreenda a natureza e a finalidade das alegações finais no âmbito da instrução criminal.

Longe de mera formalidade burocrática, as alegações finais, em verdade, constituem o **momento culminante da instrução processual**.

Segundo o magistério de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Scarance Fernandes e Antonio Magalhães Gomes Filho, **“a instrução criminal, entendida em sentido amplo como conjunto de atividades destinadas a preparar o provimento final (do latim *instruere* = transmitir conhecimentos) SOMENTE SE COMPLETA COM OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES PELOS PARTICIPANTES DO CONTRADITÓRIO”** (As nulidades no processo penal. Malheiros Editores, 1992. p. 151).

É nesse momento argumentativo que as partes, **criticando as provas e extraíndo de seu contexto versões mais favoráveis a sua posição, exercem com plenitude seu poder de influir no convencimento do magistrado**.

Observe-se que, de acordo com Ada Pellegrini Grinover, o objetivo principal da garantia do contraditório (art. 5º, inciso LV, CF) **“não é a defesa, entendida no sentido negativo de oposição ou resistência, MAS SIM A INFLUÊNCIA, TOMADA COMO DIREITO OU**

HC 166373 / PR

POSSIBILIDADE DE INCIDIR ATIVAMENTE SOBRE O DESENVOLVIMENTO E O RESULTADO DO PROCESSO” (Novas **tendências do Direito Processual**. 2. Ed. Forense Universitária, 1990. p. 19).

Isto significa que as partes terão o direito de pleitear a produção de provas, de participar dos atos probatórios e **de se pronunciar sobre seu resultado, buscando influenciar a formação do convencimento do magistrado.**

Assentadas essas premissas, exsurge a relevância, nas hipóteses de colaboração premiada, **de assegurar-se ao acusado delatado o direito de somente apresentar suas alegações finais após as alegações finais do acusado colaborador.**

Ao reconhecer a **impossibilidade de o delatado impugnar o acordo de colaboração**, consignei, em julgado de minha relatoria (v.g. HC nº 127.483/PR, Tribunal Pleno, de **minha relatoria**, julgado em 27/8/15), que a ele **será assegurado, pelo contraditório judicial, o direito de confrontar as declarações do colaborador e as provas com base nelas obtidas.**

Verifica-se, portanto, a importância do reconhecimento do direito dos acusados de confrontarem as declarações prestadas pelos acusados colaboradores, pois, como bem lembrou o Ministro **Gilmar Mendes**,

“o colaborador deve se submeter a essa ‘prova de fogo’, sendo certo que o contraditório é uma das melhores formas de se descobrir, se não a verdade, ao menos que o colaborador está mentindo ou omitindo parte dos fatos” [MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO; QUEIROZ (Org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. JusPodivm, 2016. p. 238” (HC nº 157.627-AgR, Segunda Turma, Rel. p/o ac. Min. **Ricardo Lewandowski**, julgado em 27/8/19).

Já tive a oportunidade de consignar, ao citar **Joaquim Canuto Mendes de Almeida**, que “o contraditório é, pois, em resumo, ciência

HC 166373 / PR

bilateral dos atos e termos processuais e possibilidade de contrariá-los” (**A contrariedade na instrução criminal**. São Paulo, 1937, item 81, p. 110).

O contraditório se expressa no binômio

“informação necessária + reação possível”, ressalvando-se que “esse segundo aspecto de mera oportunidade ou possibilidade de reação toma nuances diversas em todos os processos em que se controverta em torno de uma relação jurídica indisponível, como é o caso do processo penal”.

No processo penal, **dado o risco de grave intervenção no direito fundamental à liberdade**, a reação não pode ser meramente possível. O contraditório “**há de ser pleno e efetivo**, indicando a real participação das partes na relação jurídica processual” (**GRINOVER**, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do processo. In: **Novas tendências do direito processual**. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 18 – grifos nossos).

Não basta, portanto, a mera ciência dos fatos: sem a possibilidade de reação, a garantia do contraditório se tornaria inócua.

Gustavo dos Reis Gazzola, ao tratar do direito de o delatado contrastar as informações prestadas pelo colaborador, aduz que a delação premiada no curso do processo pode gerar duas situações:

“Primeira, o delatado é corréu no processo. Deve, portanto, o delatado, por meio de advogado, poder contrastar as informações prestadas pelo delator no curso da própria relação processual, o que se dará pela possibilidade de perguntas, quer em audiência de interrogatório, quer em audiência designada para essa finalidade.

Segunda, o delatado não é corréu no processo. A delação será objeto de contraditório no processo a que eventualmente estiver respondendo o delatado, ou no mesmo em que se deu a delação, caso haja aditamento da denúncia (...)” (Delação premiada. In: CUNHA, Rogério Sanches, TAQUES, Pedro e GOMES, Luiz Flávio (Org.). **Limites constitucionais da investigação**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p.180).

HC 166373 / PR

Também **Frederico Valdez Pereira** assenta a indispensabilidade de se assegurar aos delatados o direito de confrontar os colaboradores em juízo, com o intuito de retirar ou abalar a credibilidade de suas declarações. Aduz o autor que o exercício desse direito representa

“(...) verdadeiro método indireto de controle da atuação dos órgãos de persecução no momento prévio de se definir por embasar a estratégia investigativa e de imputação em pretensos colaboradores, pois deverão então considerar, antecipadamente, o exame a que serão submetidos na fase judicial os declarantes, limitando-se, desse modo, a favorecer apenas sujeitos que pareçam fiáveis e constantes na opção colaborativa.

(...) [P]ortanto, acaso se pretenda utilizar as informações advindas da delação para sustentar um juízo condenatório, ostentando a condição de meio de prova, é indispensável submeter o agente colaborador ao contraditório em juízo” (**op. cit.**, p. 146-147).

No direito comparado, destaco que, nos Estados Unidos, o direito a confrontar declarações incriminadoras de **coimputado tem estatura constitucional**.

A Sexta Emenda estabelece que, em todas as persecuções criminais, o acusado terá o direito de ser confrontado com as testemunhas de acusação e de convocar testemunhas a seu favor (**in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right (...) to be confronted with the witnesses against him; to have compulsory process for obtaining witnesses in his favor (...)**).

A Suprema Corte americana, nos precedentes **Lilly v. Virginia** (98-5881) 527 U.S. 116 (1999) e **Washington v. Texas**, 388 U.S. 14, 87 s. ct. 1920, 18 l. ed. 2D 1019 (1967), reconheceu ao corréu o direito a confrontar em juízo, mediante exame cruzado, as declarações incriminatórias de coautor ou partícipe do crime.

Na Itália, o art. 111, § 3º, de sua Constituição assegura ao acusado a

HC 166373 / PR

faculdade de inquirir ou fazer inquirir, perante o juiz, a pessoa que presta declarações em seu desfavor, de obter a convocação e a inquirição de pessoas para sua defesa nas mesmas condições da acusação e de produzir qualquer outro meio de prova a seu favor (**la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore**).

Como observa **Paolo Tonini**, essa norma se refere a

“pessoas que prestam declarações acusatórias, e não a testemunhas, ressaltando que a diversidade terminológica foi necessária, pois a palavra testemunhas, em seu significado técnico, não compreende, por exemplo, o declarante que tem a qualidade de acusado (A prova no processo penal italiano. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 25 – grifos nossos).

Segundo esse importante professor de Direito Processual Penal da Universidade de Florença,

“o confronto significa geralmente o controle da idoneidade de uma declaração. Nesse sentido, **todas as declarações prestadas no curso do procedimento penal devem ser submetidas a um confronto. Trata-se de verificar se os fatos afirmados pelo declarante encontram confirmação nos outros elementos de prova constantes dos autos; isso faz parte do dever de motivação imposto ao juiz. Na verdade, nos termos do art. 192, inciso I, CPP, o juiz deve valorar a prova, especificando na motivação os resultados obtidos e os critérios adotados.”**(op. cit. . p. 178 – grifos nossos).

Sob essa perspectiva, estou convencido de que há constrangimento ilegal na hipótese em apreço, porque as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório **asseguram aos acusados delatados o**

HC 166373 / PR

direito de se contrapor a todas as cargas acusatórias, inclusive aquelas que emanam dos acusados colaboradores, máxime quando se leva em consideração que eles contribuem com a acusação.

Consoante pertinentemente apontou o Ministro **Gilmar Mendes** no julgamento do HC nº 157.627/PR-AgR,

“[n]a colaboração premiada, o réu delator adere à acusação, em troca de um benefício acordado entre as partes e homologado pelo julgador natural, nos termos da Lei 12.850/2013. Ou seja, o delator, em regra, presta contribuições à persecução penal, incriminando eventuais corréus” (Rel. p/o ac. Min. **Ricardo Lewandowski**, julgado em 27/8/19 – grifei).

Em artigo intitulado “O status processual do corréu delator”, os professores **Luís Greco** e **Alaor Leite** indicam que o delator não é

“um acusado ‘comum’. Afinal, entre outras coisas, o acusado ‘comum’, em nosso sistema processual, não entabula sigiloso consórcio com o órgão de persecução em desfavor de terceiro, levado à homologação judicial – pelo mesmo juiz que proferirá a sentença quanto ao colaborador e ao terceiro delatado –, tudo, em regra, antes do oferecimento da denúncia. O acusado ‘comum’ é simplesmente surpreendido pelo órgão de persecução, não granjeia qualquer melhora em sua situação processual e, também por isso, possui direito a uma acusação precisa e determinada (art. 41 CPP) e ao silêncio – ao qual renuncia o delator” (disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/penal-em-foco/o-status-processual-do-correu-delator-30-09-2019 – grifos nossos).

Esses renomados juristas invocam o processualista alemão **Karl Peters**, “que indicou a necessidade de que a ‘credibilidade’ do coautor que incrimina outro sujeito **deva ser escrutinada** e ‘necessita de uma

HC 166373 / PR

conferência a partir de provas reais” (grifos nossos).

Sob essa óptica, o Supremo Tribunal Federal reconheceu

“a cada um dos litisconsortes penais passivos, **o direito** – **fundado** em cláusulas constitucionais (CF, art. 5º, **incisos** LIV e LV) – **de formular** **reperguntas aos demais** co-réus, que, no entanto, **não estão obrigados** a respondê-las, **em face** da prerrogativa **contra** a auto-incriminação, de que **também** são titulares” (HC nº 94.016/SP, Segunda Turma, Rel. Min. **Celso de Mello**, DJe de 26/2/09 – grifos do autor).

O aresto paradigma enfatizou, ainda, que o

“desrespeito a essa franquia individual do réu, **resultante** da arbitrária recusa em lhe permitir a formulação de reperguntas, **qualifica-se** como **causa geradora de nulidade processual absoluta, por implicar grave transgressão** ao estatuto constitucional do direito de defesa” (grifos do autor).

Convergindo com esse entendimento, **Gustavo Badaró** explica que,

“no caso em que há colaboradores e delatados a serem interrogados, não havendo disciplina específica no CPP nem na Lei nº 12.850/2013, **a lacuna deve ser suprida pela aplicação do princípio da ampla defesa**. O próprio deslocamento do interrogatório do momento inicial da instrução para após o seu término, promovido pela Reforma de 2008, visou permitir que o acusado possa exercer sua autodefesa – ou até mesmo optar por renunciar ao seu exercício, permanecendo calado – já tendo um conhecimento completo de toda a prova produzida e, em especial, dos elementos incriminatórios colhidos na instrução. **A lacuna deve ser suprida com apoio no princípio da ampla defesa, que exige que seja interrogado inicialmente o colaborador, e depois, os corréus delatados**” (Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-set-24/gustavo-badaro-figura->

HC 166373 / PR

especifica-colaborador-premiado - grifos nossos).

Colaciona, ainda, esse renomado Professor de Direito Processual Penal da USP que,

“concluída a instrução e interrogados os corréus, primeiro o colaborador, e depois os delatados, coloca-se o problema da ordem da apresentação das alegações finais. Dificilmente, pela complexidade dos casos, será adequada a realização de debates orais. A questão, portanto, cinge-se à ordem de apresentação de memoriais. O CPP limita-se a prever que as alegações finais orais serão apresentadas, ‘respectivamente, pela acusação e pela defesa’ (art. 403, *caput*). E, no caso de conversão em memoriais, o juiz deverá ‘conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais’ (art. 403, § 3º). Interpretando o parágrafo, segundo a regra geral da cabeça do artigo, fica evidente que as partes serão, primeiro a acusação e depois a defesa. Novamente, não há previsão expressa no caso de haver corréu colaborador. Pelas mesmas razões expostas quanto ao modo do interrogatório, na apresentação de alegações finais, é necessário que o acusado conheça a síntese argumentativa da acusação existente contra ele, quando da apresentação de suas alegações finais. Por isso, a ordem dos memoriais é: primeiro a acusação, depois a defesa. Procurando suprir a lacuna legal pela aplicação dos princípios constitucionais, em especial a ampla defesa, a ordem deve ser: memoriais do Ministério Público; memoriais do colaborador premiado; memoriais do corréu delatado” (grifos nossos).

Em abono a esses fundamentos, destaco o substancial voto proferido no caso pelo Ministro **Alexandre de Moraes**, quando consignou que

“[o] direito de falar por último **está contido no exercício pleno da ampla defesa**[.] englobando a possibilidade de refutar TODAS, absolutamente TODAS as informações, alegações,

HC 166373 / PR

depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam, direta ou indiretamente, influenciar e fundamentar uma futura condenação penal, entre elas as alegações do delator”.

Ao concluir que **“o delatado tem o direito de falar por último sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação”**, Sua Excelência ponderou que

“o delator precisa que o Ministério Público obtenha a condenação para ter sucesso em seu acordo. Consequentemente, [em] suas alegações finais, [ele] fornece[] ao processo e ao juiz todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória”.

É providencial, portanto, que os acusados delatados tenham o direito de inquirir os acusados colaboradores nas audiências de interrogatório, **bem como de contraporem, em momento posterior, os argumentos constantes das alegações finais por esses ofertadas, o que enaltece o direito ao confronto, inerente ao contraditório pleno, reconhecido, inclusive, pelo direito norte-americano e italiano, como já demonstrado.**

Assegura-se, dessa forma, a “paridade de armas” entre os acusados delatados e o órgão acusador, a qual se entende como

“o indispensável equilíbrio que deve existir entre as oportunidades concedidas às partes para que, ao apresentar suas provas e alegações ao juiz ou tribunal, não seja colocado em desvantagem em relação à parte contrária” (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. **A motivação das decisões penais**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 36).

A par dessas premissas, penso que a oitiva dos acusados delatados

HC 166373 / PR

deve necessariamente ser realizada em momento posterior ao interrogatório do acusado colaborador, como ocorreu na espécie. Essa mesma lógica processual em prol da ampla defesa e de um efetivo contraditório deve prevalecer para os acusados delatados na fase das alegações finais, até porque

“[a] exigência de um contraditório efetivo e equilibrado impõe que se analise, (...) o próprio conteúdo das alegações oferecidas, **sob pena de se transformar a participação nessa fase em mera formalidade inócua, desprovida de qualquer aptidão para influenciar o convencimento do julgador**” (GRINOVER et al. **As nulidades no processo penal**. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 229 – grifos nossos).

Ademais, ainda que se questione a ausência de previsão legal nesse sentido, “a compreensão hermenêutica e a incidência das normas fundamentais”, como pertinentemente anotou o Ministro **Ricardo Lewandowski** no julgamento do HC nº 157.627-AgR, “não estão condicionadas, em princípio, à existência de texto normativo infraconstitucional, conforme prescreve o disposto no § 1º do art. 5º da CF/88.”

Como bem disse Sua Excelência em seu douto voto,

“[é] cediço, nessa quadra, que o legislador é incapaz de prever, de forma apriorística e com pormenores, as diversas situações em que [se] descortina indispensável assegurar o contraditório substancial ao acusado, mormente quando envolver novel diploma legal introduzi[do] no ordenamento jurídico”.

Vale registrar que o direito de defesa constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. Havendo justo receio de ser ele infringido, deve assumir máxima efetividade na ordem constitucional (v.g. HC nº 87.111, Segunda Turma, Rel. Min. **Gilmar**

HC 166373 / PR**Mendes**, DJ de 23/6/06).

Por essas razões, reconheço que, em todos os procedimentos penais, é direito do acusado delatado apresentar as alegações finais após o acusado delator que, nos termos da Lei nº 12.850/13, tenha celebrado acordo de colaboração premiada devidamente homologado.

Concluo, assim, pela existência de prejuízo suportado pelo paciente, que, no caso concreto, se insurgiu **oportuno tempore** e de forma reiterada contra o cerceamento de defesa, de sorte que percorreu toda a cadeia processual até chegar a esta Corte.

Cabe, ainda, consignar que esse ponto de vista guarda coerência com meu entendimento em matéria de nulidade processual, notadamente de que, “além da arguição **oportuno tempore** da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do **pas de nullité sans grief**, presente no art. 563 do Código de Processo Penal” (RHC nº 138.752/PB, Segunda Turma, de **minha relatoria**, DJe de 27/4/17).

Forte nessas razões, como já havia adiantado, **concedo a ordem de habeas corpus** para determinar o retorno do processo à fase de alegações finais, assegurando que o acusado delatado apresente sua alegações após o acusado delator. **Acompanho**, portanto, o voto divergente inaugurado pelo Ministro **Alexandre de Moraes**, renovando a mais respeitosa **vênia** ao Relator.

É como voto.

Não obstante, como já anunciado na última assentada, trago à submissão dos eminentes pares **não uma modulação dos efeitos do julgado, mas uma proposta de tese para balizar todo o sistema de Justiça brasileiro**, resguardando, assim, o postulado da segurança jurídica.

A proposta em questão assumirá, ademais, a relevantíssima função jurídica de “proteger a confiança do particular nos atos do Estado – no caso específico, **a confiança do jurisdicionado na pauta de conduta criada pelo Poder Judiciário**”, como leciona a professora **Teresa Arruda**

HC 166373 / PR

Alvim em obra de grande relevância acadêmica (**Modulação na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 158-159).

Ressalto que o que se está a decidir na espécie é a garantia da aplicação de preceitos fundamentais da Constituição, como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, “[d]e molde, sempre, a salvaguardar direitos do cidadão” (**op. cit.** p. 165).

A proposição de tese em processo subjetivo, diga-se de passagem, não é novidade para este Plenário, já que, no julgamento do HC nº 127.900, de **minha relatoria**, no tocante à incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum sobre todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, a Corte fixou uma tese objetiva para a matéria.

Nesse sentido, proponho ao colegiado as seguintes teses:

i) Em todos os procedimentos penais, é direito do acusado delatado, desde que ele o argua até a fase do art. 403 do CPP - ou sua equivalente na legislação especial - e que ele reitere a arguição nas fases recursais subsequentes, apresentar as alegações finais após o acusado que, nos termos da Lei nº 12.850/13, tenha celebrado acordo de colaboração premiada devidamente homologado, sob pena de se configurar nulidade processual.

ii) Para os processos já sentenciados, é necessária, ademais, a demonstração do prejuízo, que deverá ser aferido no caso concreto pelas instâncias competentes.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Quanto a reconhecer a impossibilidade de o delatado impugnar o acordo de colaboração, eu é que trouxe esse precedente aqui a esta Corte. E votei no sentido de que, no negócio jurídico entre o colaborador e o Estado-investigador e Estado-acusador, não compete àquele que está sendo apontado como um eventual futuro acusado ou denunciado - se a investigação assim entender, e o órgão-acusador, Ministério Público, assim apresentar - impugnar o acordo entre delator e Estado, porque ali há um meio de obtenção de provas.

Ao reconhecer, como fiz, a impossibilidade de o delatado impugnar o acordo de colaboração, consignei – no HC nº 127.483, do Paraná, de minha relatoria, julgado por este Tribunal Pleno por maioria, consolidando o acordo de colaboração como um negócio jurídico entre o estado-acusador e o acusado que deseja com ele colaborar, tornando-se um delator– que a ele, delatado, não cabia a possibilidade de impugnar o acordo de colaboração, porque esse lhe é "extra".

Entretanto, consignei que a ele será assegurado, pelo contraditório judicial - isso está no meu voto lá proferido, e muitos dos Colegas me acompanharam, para honra minha -, o direito de confrontar as declarações do colaborador e as provas com base nelas obtidas.

Aquele julgado foi aclamado como um **leading case**, em várias obras doutrinárias, passando a ser um "norte" para todo o Poder Judiciário brasileiro, para a magistratura, para o Sistema de Justiça: estado-acusador, ministério público, defesa, advocacia, defensoria, segurança jurídica. Isto já foi dito aqui, em "alto e bom som", pelo Plenário deste Tribunal: não cabe a impugnação do delatado ao acordo, mas caberá a ele a última palavra. Nesse julgado de agosto de 2015 – há quatro anos –, está todo o "norte" do que é o conceito e a natureza jurídica em questão.

Ministro **Celso** se lembra muito bem, porque muito me honrou a

HC 166373 / PR

manifestação de Vossa Excelência em apoioamento, naquela data, a meu voto, manifestando-se no sentido de que era um voto que honrava a tradição deste Supremo Tribunal Federal, que muito me emocionou, Ministro **Celso**.

Mas ali está todo o norte dado. Não há que se dizer que a magistratura não soubesse disso. Não há que se dizer que o Ministério Público, Dr. Alcides – que nos honra, com sua permanência aqui conosco –, não soubesse disso. Não há que se dizer que a defesa também não sabia dessas possibilidades. Todos sabiam. Já estava dito aqui - repito pela importância histórica que tem. Ninguém está inovando neste julgamento.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

O que ocorre? O delator e o delatado passam a ser contrastantes, partes contraditórias. É evidente que o delator não se torna estado-acusador, mas ele tem um compromisso em colaborar. Qual é o nome do termo? Colaboração premiada. Ele renuncia a ficar calado, passa a ter o dever de dizer a verdade sob pena de cometimento de outro crime e perder a colaboração.

Ele está contrastando com o estado? Não, ele está colaborando com o estado. Então, como entendê-lo um réu tal qual o outro réu que é delatado? Qual a lógica, com a devida vênia?

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

O contraditório é depois. Não é concomitante, não é ao mesmo tempo. E vejam quantas colaborações foram firmadas, que depois redundaram num nada jurídico, com a própria Procuradoria-Geral da República pedindo arquivamento. Quantas?

Porque, muitas vezes o dito colaborador está querendo se safar daquilo que ele fez e começa a apontar o dedo para outrem. E, depois, se verifica que aquele outrem não era culpado de nada, não se chega a nada. E aí ele pode perder, como já há aqui feitos em que se pede exatamente a nulidade da colaboração ou a sua revogação, porque não houve sucesso. Olhem o cuidado desse instituto de colocar pessoas que não são culpadas como se criminosas fossem.

Não é de pouca coisa que nós estamos falando; é do direito de cada cidadão brasileiro. E aqui não estamos falando só dos casos que são julgados nesta Corte, e sim de todas as investigações que ocorrem em todas as delegacias de polícia do Brasil; em todos os fóruns; em todas as varas criminais. Não é pouca coisa. Nós vamos tirar esse direito do cidadão brasileiro de falar por último?

E volto a dizer: em 27 de agosto de 2015, este Plenário determinou exatamente que o delatado não pode impugnar a delação, mas, no curso do processo, fará esse contraditório sempre após o delator. Já estava indicado pelo Plenário desta Corte.

Vamos agora ao direito comparado.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

INCIDÊNCIAS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Já placitado aqui e no Tribunal Superior Eleitoral para ampliá-lo para o direito processual eleitoral e para o direito processual militar sem lei específica.

Estou citando precedentes do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, sem lei específica, em relação àqueles procedimentos, em que se entendeu que aquilo que foi estabelecido como regra geral deveria ser levado à legislação específica do Código Eleitoral e do Código de Processo Penal Militar, dando aos acusados, na Justiça Eleitoral e na Justiça Militar, o direito de ser interrogados no final, em razão do princípio constitucional da ampla defesa.

E, embora contra a expressa disposição dos respectivos Códigos - Código Eleitoral, dizendo explicitamente que era no início da instrução; Código de Processo Penal Militar, idem -, nós estabelecemos que, em razão do princípio constitucional da ampla defesa, que também é lei, e, mais do que lei, está acima do Código de Processo Penal Militar e do Código Eleitoral, o interrogatório deveria ser ao final.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhor Presidente, no caso concreto, *Habeas Corpus* 166.373, que Vossa Excelência vem de já de proclamar o resultado, será Redator para o acórdão o Ministro Alexandre Moraes, nada obstante a figura do Relator, obviamente, não desaparece, apenas se desloca a redação do acórdão.

Por isso, peço a palavra, Senhor Presidente, para contribuir, neste momento do julgamento, e assentar que, em meu modo de ver, a tese majoritária acolhida neste Supremo Tribunal Federal, em sede do Plenário, e que confortou a compreensão da maioria - inserindo-se este Relator na posição vencida -, de algum modo, embora não com a tese do Relator, responde à motivação que tive ao afetar este feito ao Pleno do Supremo Tribunal Federal.

Permito-me lembrar que, no despacho que exarei em 28 de agosto deste ano, assentei que,

"Com vistas a angariar segurança jurídica e estabilidade jurisprudencial, afeto a presente impetração à deliberação do Plenário cujo objeto traduz controvérsia a merecer exame do Colegiado sobre esse tema".

Portanto, quero mencionar que me parece merecer todo o acolhimento a ideia segundo a qual deva-se fixar uma orientação, porque efetivamente há precedente nesse sentido. E diria o mesmo se a tese prevalente fosse a tese que aqui trouxe e que tive a honra de ser acompanhado, na conclusão, por quatro e, na tese, por três eminentes Pares.

De modo que não se trata mais de defender essa ou aquela conclusão, trata-se de apoiar a iniciativa de Vossa Excelência, no sentido de manter-se, este Plenário, fiel. E me recorro do debate que fizemos, nesse *habeas corpus* de relatoria de Vossa Excelência, que, por coincidência é o *Habeas Corpus* 127.900/AM, no qual, precisamente, ao final, fez-se uma fixação de orientação, metodologicamente falando, na direção do voto

HC 166373 / PR

que Vossa Excelência agora traz à colação, e estou só me referindo à parte das teses, porque, no mais, entendo que isso já restou obviamente fixado.

Portanto, na questão de fundo, vale dizer, o reconhecimento do direito, que a tese nº 1 de Vossa Excelência proclama, do direito de o acusado delatado apresentar alegações finais após o acusado delator, nas condições que Vossa Excelência traz, ainda que não conforte posição que aqui defendi, na qual fui acompanhado pelos eminentes Colegas, em meu modo de ver, reproduz a compreensão majoritária.

E, ao mesmo tempo, o Tribunal, por sua maioria, fixa uma orientação que deixa nítida a conclusão majoritária, não apenas para os jurisdicionados, mas para nós todos. Por exemplo, nesta impetração, assim que o julgamento for concluído, irei deliberar de acordo com a percepção majoritária do Colegiado. E, se o tempo me permitir e nenhuma emergência surgir, ainda hoje, porque creio que assim fazemos todos nós no sentido de seguir as orientações majoritárias do Tribunal Pleno.

Portanto, a intervenção que faço, Senhor Presidente, há de dizer que o sentido da participação foi exatamente esse, de buscar uma orientação à luz do precedente que Vossa Excelência já houvera relatado; a orientação majoritária deflui do que acabou de ser deliberado: sete votos em relação à tese e seis em relação à conclusão, portanto firmou-se a percepção majoritária.

Como já disse e repito, estou entre aqueles que entendia inexistir esse direito, até o presente momento, mas essa foi uma posição vencida e a posição vencedora, e, para harmonia e estabilidade, passa a ser a posição deste Colegiado. Aqui importando menos, no meu modo de ver, o posicionamento individual de cada um dos magistrados, porque nós vamos operar, como sempre temos feito - estou seguro disso -, em homenagem ao Colegiado.

Portanto, faço essa manifestação inicial, dizendo que, nada obstante vencido, entendo que se deva fixar orientação nessa dimensão. É claro que, vencido na questão de fundo, poderia se cogitar de uma tese que indicasse efeito prospectivos. Mas, tenho para mim - posso estar

HC 166373 / PR

enganado, embora a mim, me apetecesse votar uma eficácia *ex nunc* nessa dimensão -, que, quando a maioria defere a ordem, implicitamente está, à luz do caso concreto, espraiando uma dimensão eficaz de natureza *ex tunc*, ainda que com isso não concorde. Acredito que essa seja a posição majoritária.

Por isso, as teses que Vossa Excelência traz à colação, tanto a de nº 1 como a de nº 2, não obstante não espelhem premissas das quais parti, mas premissas diversas das quais este Relator partiu - e me permito dizer que estou vencido, embora não convencido -, seguirei, como não poderia deixar de ser, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal Federal.

Creio que Vossa Excelência agrega dentro da corrente majoritária, e agora trazendo para todos, porque não está propondo apenas orientação para a corrente majoritária, mas para todo o Tribunal. E me sinto legitimado, embora vencido, a dizer: primeiro, é importante termos orientação; segundo, as propostas de Vossa Excelência, no meu modo de ver, são coerentes com a percepção formada aqui majoritariamente, nada obstante tenha ficado numa posição vencida.

Era o que tinha a dizer a Vossa Excelência e aos eminentes Pares.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**EXPLICAÇÃO****O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):**

Gostaria de justificar o porquê de ter trazido a tese com esses dois itens. Porém, antes – exatamente pelo que disse o Ministro **Edson Fachin**, o qual ficou vencido –, quero proclamar o resultado.

A tese, o Colegiado vai fazer, respeitando exatamente o posicionamento majoritário. É importante essa colegialidade na fixação da tese. Por isso, proclama-se a decisão do caso específico, em julgamento primeiro, e, depois, abre-se para discussão. Não é a primeira vez que isso ocorre. Assim foi feito em várias gestões deste Supremo Tribunal Federal.

Após a proclamação, a tese que proponho é mais para orientação, conforme destacou o Ministro-Relator Luiz **Edson Fachin**. Mas gostaria de justificar o porquê de eu entender pertinente - e sei que há divergência, por isso adianto.

Por que coloco a tese não só em relação à questão das alegações finais serem apresentadas por último pelo delatado, mas também em relação à demonstração do prejuízo? Por uma questão exatamente de maioria nos fundamentos do voto.

Entendi, em meu voto concedendo a ordem, ser necessário o prejuízo. Nesse sentido, entendi que houve o prejuízo, pois, se assim não houvesse entendido, o resultado seria a denegação da ordem. Por outro lado, a Ministra **Cármem Lúcia** também entendeu necessário o prejuízo – corrija-me, Sua Excelência, não quero declarar voto já declarado. Meu entendimento foi o de que Vossa Excelência só não concedia a ordem porque entendeu não haver prejuízo, mas, na tese – item 1 –, Sua Excelência concordaria. Vejo que a Ministra **Cármem Lúcia** assente.

Então, o que nós temos do ponto de vista de resultado quanto a fundamentos? Nós temos sete votos pela necessidade de o acusado, réu delatado, falar por último nas alegações finais. Sete! Nomino os sete votos em relação ao fundamento da necessidade de o réu delatado falar por

HC 166373 / PR

último: Ministro **Alexandre de Moraes**; Ministra **Rosa Weber**; Ministra **Cármem Lúcia**; Ministro **Ricardo Lewandowski**; Ministro **Gilmar Mendes**; Ministro **Celso de Mello** e Ministro **Dias Toffoli**. Então, o item 1 tem, nos fundamentos dos votos proferidos, sete adesões. O item 2, que é a necessidade da ...

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI -
Presidente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Posso concluir, Ministro **Ricardo Lewandowski**?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim, Vossa Excelência pode. Mas é um aparte importante, Presidente, *data venia*.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Eu só estou fundamentando a minha proposta de tese.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, é a questão do art. 403 do CPP, a qual não foi discutida.

Para que possamos aplicar essa tese que Vossa Excelência está sugerindo ao Plenário, seria necessário que nós tivéssemos discutido isso à exaustão, e isso não foi objeto do nosso HC. Aqui, só discutimos uma questão muito bem circunscrita, que é exatamente esta: alguém que se insurgiu, desde o primeiro momento, contra o fato de não lhe ter sido propiciada a oportunidade de se manifestar depois dos delatores. Outras questões não foram cogitadas aqui.

Se tivéssemos que, agora, discutir a tese, deveríamos ter feito previamente uma discussão sobre essa questão. Assim também sobre os tipos de prejuízos que podem ocorrer. Inclusive, no texto que Vossa Excelência cita, do Professor Gustavo Badaró, em continuação, consta exatamente isto: a parte deve apenas alegar o vício, mas a obrigação de demonstrar o prejuízo não é da parte, porque no caso de ofensa a uma garantia fundamental da Constituição, trata-se de nulidade absoluta.

A parte prejudicada, então, meramente alega o prejuízo. Compete ao Ministério Público ou à parte contrária mostrar que não houve prejuízo. Então, Senhor Presidente, são questões que não foram discutidas e teríamos que ter verticalizado. Nós temos que ficar dentro dos parâmetros do HC simplesmente, com a devida vênua.

Peço desculpas da minha ênfase na defesa do ponto de vista, porque não podemos extrapolar os limites objetivos daquilo que discutimos. Na verdade, Vossa Excelência está apresentando uma tese que, no fundo, é uma modulação. Estamos aqui, a rigor, se Vossa Excelência me permite, dando um contra-HC. E a primeira lição que eu aprendi com o Ministro Marco Aurélio, assim que cheguei neste Tribunal, a menos que Sua Excelência tenha mudado de ponto de vista, é que não existe contra-HC.

Com uma tese tal como a sugerida por Vossa Excelência, estaríamos

HC 166373 / PR

prejudicando todos os demais réus que ainda não tiveram oportunidade de suscitar essa questão. Então, num *HC* limitado a parâmetros objetivos, vamos prejudicar toda uma série de réus ou de acusados, que ainda não tiveram oportunidade de se manifestar sobre essa questão e discuti-la ao longo de toda a cadeia recursal.

Desculpe, Presidente, pela intervenção intempestiva.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Ministro **Luiz Fux**. Eu, depois, vou retomar para justificar.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, só uma intervenção muito simples. Talvez o Ministro Ricardo Lewandowski esteja entendendo que a questão do prejuízo está no art. 403, mas não está. O art. 403 é o que expressa quem deve falar por último e isso foi discutido.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Não foi discutido, *data venia*.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Foi discutido. O delatado tem que falar por último. É a exegese do art. 403. A Ministra Rosa citou no voto dela e vários citaram.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - A verdade, Ministro Fux, é que a doutrina é absolutamente unânime: se a nulidade é absoluta, o prejuízo é presumido. Há presunção.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Eu não a entendo como absoluta. Aí é que está. E, pelo que entendi, a Ministra **Cármen** também não entende como absoluta.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Agora, nós não discutimos à exaustão a natureza desse vício. Porque, se fosse assim, teríamos que baixar toda a doutrina e jurisprudência, para saber que tipo de vício é. Para mim, já adianto, essa é uma nulidade absoluta, insanável.

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ministro Celso, Vossa Excelência me permite? Há outra questão importante.

HC 166373 / PR

Imaginemos dois réus no mesmo processo: um recorreu, e o outro não. Como é que fica o princípio da isonomia? Como interpretar o art. 580 do Código de Processo Penal, que determina que os réus, em idênticas situações, tenham igual tratamento? Ou seja, nós vamos declarar aqui a inconstitucionalidade ou negar a eficácia do art. 580 do CPP?

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: (CANCELADO).

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, permite-me uma consideração, já que sou o Redator para o acórdão?

Primeiro, Presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela ideia e tentativa de votação de uma tese para a garantia da segurança jurídica. O Ministro Edson Fachin colocou essa importância e eu quero reiterar aqui.

Contudo, entendo que os instrumentos são diversos para a obtenção da finalidade que Vossa Excelência, no voto, colocou. Explico. Nós julgamos um *habeas corpus* com questões específicas. A partir dessas questões específicas, na fundamentação, dois dos sete votos - na verdade, um dos seis votos que deferia - entenderam pela necessidade de prejuízo. Um dos votos que indeferiu pode adotar a tese, mas entender que não houve prejuízo.

Na verdade, o que ocorreu? Em virtude das peculiaridades do caso concreto, o delatado solicitou ao juiz para falar por último. O delatado havia já sido interrogado depois do delator. O juiz indeferiu. O delatado impugnou e foi recorrendo. Nós entendemos que é nula a decisão.

A partir disso, o Ministro Celso, agora, e o Ministro Ricardo citaram o art. 580. Se fossem corréus - até o Ministro Celso disse, há o pedido de extensão -, há o efeito extensivo do *habeas corpus* que, se ampliarmos a ideia, poderíamos dizer: "Todos os casos semelhantes a este caso devem ter a mesma decisão". Entendo que é possível extrair isso como tese, porque isso foi discutido.

Agora, e todos os casos que não são semelhantes? Todos os casos que não discutimos? O efeito extensivo - tanto que o próprio Código de

HC 166373 / PR

Processo Penal diz que, se houver circunstâncias específicas, não se aplica - do art. 580, entendo, poderia justificar e permitir uma tese do que foi discutido e do que foi julgado. Ou seja, todos os casos idênticos a esse devem ter uma solução idêntica. Nos demais casos, se a Corte entender por bem definir os pontos, aí, com o devido respeito a Vossa Excelência, não se poderia utilizar o art. 580.

Neste caso, a Constituição prevê, no art. 103-A, a edição de uma súmula vinculante, para alcançar outros casos. A própria Constituição exige vários casos, mas, se quisermos abarcar todas as hipóteses, a questão da extensão, a meu ver, seria de súmula vinculante. Isso - antes que se diga que é uma filigrana jurídica ou, como usei no julgamento passado, uma "firula jurídica" - não é porque o quórum é diverso. A súmula vinculante precisa de dois terços do Tribunal e é vinculante. E por que digo isso, Presidente?

Entendo, como já disse, que a ideia para preservar a segurança jurídica é importantíssima, mas não podemos deixar que o Tribunal acabe perdendo credibilidade, porque, em outros casos, em outros julgamentos, nós já temos, por exemplo - e cito aqui um caso de segunda instância -, dois *habeas corpus* decididos por maioria e uma repercussão geral. O próprio Tribunal entende que é necessário julgar uma ação declaratória de constitucionalidade para vincular o próprio Tribunal.

Por que cometeríamos o mesmo erro agora, ampliando uma tese, não só estendendo - e aí o Código permite que todos os casos iguais a esse devem ser julgados aqui -, sabendo que temos um retrospecto que, nesses casos, acaba não vinculando o próprio Tribunal?

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Vossa Excelência está sugerindo, portanto, que eu não siga a decisão majoritária do Tribunal?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não, não, de forma alguma. Estou sugerindo que decidamos sobre a decisão majoritária do Tribunal.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Mas, se Vossa Excelência me permitir, no HC 127.900, este Pleno, da relatoria do

HC 166373 / PR

Ministro Dias Toffoli, concluiu: "Em vista das razões do meu voto e das substanciais ponderações lançadas pelos Membros da Corte, durante os trabalhos, que acolho, proponho, como orientação que (...)". Ou seja, nós temos um precedente que fixa a orientação.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Fachin, talvez eu não tenha sido claro. Eu disse que são dois instrumentos possíveis. O utilizado nesse precedente é exatamente o que eu também proponho agora: a extensão para o que foi discutido no *HC*. Nesse precedente, não houve extrapolação do que foi discutido no *HC*. Foi discutido um tema e a tese definiu o tema. O que eu proponho é: O que nós discutimos? O que foi decidido? Que é exatamente o item 1 da tese, esse tema.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Entendi e desculpe-me a intervenção. Vossa Excelência, portanto, está de acordo que, neste debate, seja fixada uma orientação, mas está a debater a amplitude.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - A amplitude. Mais do que isso seria necessária uma súmula vinculante. Essa é a minha sugestão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

As posições estão dadas, vamos colher os votos. Eu só queria terminar para justificar. Sempre há algo de maior desafio do mundo – e eu não tenho essa capacidade – em divergir de nosso Decano, Ministro **Celso de Mello**, e não vou ficar citando aqui alguns precedentes, mas são vários os precedentes desta Corte, tanto em matéria de nulidade relativa ou mesmo de nulidade absoluta, relativos à necessidade do prejuízo.

E votei concedendo a ordem porque, no caso concreto, entendi pelo prejuízo. Evidentemente o prejuízo em si só é aferível em cada caso concreto. Esse debate, tendo esse item 2 ou não, vamos ser realistas, será colocado por eminentes advogados, pela defensoria pública em todos os processos em que a defesa entender que houve ou não o prejuízo, porque ela terá que demonstrar. E o juízo competente local vai aferir isso. Ele pode dizer: "Para mim, o prejuízo é a condenação."

HC 166373 / PR

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Apenas para sugerir, do ponto de vista metodológico, como Vossa Excelência disse, as posições estão postas, talvez pudéssemos votar os itens separadamente.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - A questão, Ministro Toffoli, no caso concreto, o que entendi é que - agora Vossa Excelência esclareceu o seu voto - os demais, assim como a divergência que lancei, entenderam, que, nesse caso em que se pede, se nega e se é condenado, esse é o prejuízo. Está claro o prejuízo. Por isso a diferença. Então, dentro da metodologia que até o Ministro Fachin colocou, eu entenderia que, salvo melhor juízo, deveria se colocar primeiro se se deve ou não votar a tese. Depois, os pontos da tese.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Então, vou dividir em três votações: primeiro, se colocamos ou não uma tese para o caso; segundo, o item 1; terceiro, o item 2. Mas antes de colocar em votação pediu a palavra o Ministro **Ricardo Lewandowski**.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, apenas peço a palavra pela ordem.

Na verdade, Vossa Excelência, com o cuidado que tem na qualidade de Presidente, está nos apresentando uma tese. Entretanto, eu ousaria dizer que essa tese, na verdade, é uma modulação. E, como modulação, está sujeita à decisão que tomamos no RE 586.453/SE, sujeita, pois, a uma votação de dois terços, uma maioria, portanto, qualificada, *data venia*, como ocorreu nos demais casos.

Desde logo, com o devido respeito, estou me pronunciando contra a modulação.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Veja bem, a partir da premissa de Vossa Excelência, o que decidimos aqui, se não fixarmos uma tese, poderá ser desconsiderado pelos juízes e terão que vir **habeas corpus** até aqui.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas a tese dentro dos parâmetros objetivos, Presidente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

HC 166373 / PR

Porque, se tudo precisar de súmula vinculante e oito votos, qual a orientação que nós vamos passar? Vamos passar a julgar tudo. Então, por exemplo, aquilo que Vossa Excelência votou, se nós não fixarmos tese nenhuma aqui, nenhum juiz estará orientado a seguir. É importante fixar a tese, é necessário.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, por isso que fiz o diferencial, porque uma coisa é fixar uma tese estendendo para todos os demais casos o que foi decidido. Se houver necessidade de se ampliar, aí, realmente, há necessidade de um *quorum* diferenciado. Agora, estender o que já foi decidido? É uma extensão.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Eu já justifiquei o porquê de eu colocar a questão da segurança jurídica, porque, em minha contabilidade e em razão de meu voto, eu assento a necessidade explícita de uma demonstração de prejuízo.

Eu colho voto em relação a fixarmos tese ou não a partir do Relator. E voto, como sugeri inicialmente, a favor de fixarmos uma tese.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO S/PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Eu voto contrário.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**VOTO S/PROPOSTA**

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, eu gostaria de esclarecer um ponto aqui.

Não se trata de modulação em sentido técnico. Modulação é uma categoria que tem uma acepção própria, prevista expressamente na Lei nº 9.868/1999, pela primeira vez, no art. 27, para as hipóteses em que, declarada a inconstitucionalidade de uma norma em ação direta, o Supremo Tribunal Federal (STF) teria a possibilidade de prever que os efeitos dessa decisão somente se produziram dali para frente, ou a partir de um momento especificado. Essa previsão exige dois terços de quórum, porque, na verdade, excepciona a teoria da nulidade.

A teoria da nulidade sempre sustentou, e sempre foi adotada no Brasil, sempre estabeleceu que o ato inconstitucional é nulo, desde o início, e não pode produzir efeitos válidos. Veio a Lei, e criou uma exceção para admitir que, ponderado com outros valores como segurança jurídica e interesse social, poder-se-ia modular, ou seja, não declarar a inconstitucionalidade com efeitos retroativos.

Modulação é dizer: uma lei inconstitucional excepcionalmente produziu efeitos válidos e só vamos retirá-la do ordenamento jurídico ou pronunciar a sua ineficácia daqui para frente. Em alguns precedentes, o Supremo havia feito isso em controle incidental. Poucos, mas existiram. E, aí, sem quórum.

Houve um caso importante, do STF, em que se declarou inconstitucional uma lei que criara o cargo de oficial de justiça. O oficial de justiça perdeu o cargo, porém esta Corte não declarou a nulidade de todos os atos praticados por aquele oficial de justiça, senão anular-se-iam todos os processos. Ou, se o STF declarar a inconstitucionalidade da lei que criou o cargo de juiz de paz, por exemplo, todos os casamentos que ele tivesse celebrado seriam inválidos automaticamente. Algumas pessoas até poderiam celebrar, mais isso, evidentemente, não seria a consequência

HC 166373 / PR

jurídica.

Portanto, havia precedentes de modulação que significavam basicamente permitir que lei inconstitucional produzisse efeitos válidos. Isso é que é, com todas as vênias, modulação.

Com modulação não se confunde, novamente com todas as vênias, à eventual questão de mudança de jurisprudência. E aí, o Ministro Celso mencionou, temos dois precedentes: um mais antigo e, depois, um mais recente, em que o próprio Ministro Celso, tendo votado vencido - comigo, com o Ministro Gilmar e com algum outro Colega, que de cabeça não me lembro -, disse: "Nós precisamos rediscutir essa questão do quórum quando não haja declaração de inconstitucionalidade".

Mas esse julgamento a que se referiu o Ministro Celso como sendo o momento que nós devêssemos começar a repensar isso foi de fevereiro de 2016, concluído em fevereiro de 2016. Depois desse julgamento, sobreveio, o Código de Processo Civil - Código novo, o Código Fux de Processo Civil. E ali se estabeleceu, Presidente, de maneira textual e sem nenhuma previsão de quórum, o seguinte:

"Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica."

De modo que, se aqui se tratasse de mudança de jurisprudência, creio que pelo novo Código Civil, que é superveniente a nossa decisão, não se exigiria quórum algum.

Com todas as vênias, nós nem estamos modulando por declaração de inconstitucionalidade, nem, em rigor, estamos modulando por mudança de jurisprudência, a menos que considerássemos como jurisprudência dois precedentes da Segunda Turma, em que houve pedido de inversão da ordem, e o *habeas corpus* foi denegado. Dois precedentes: um monocrático e o outro do Colegiado; pedido transcrito no voto do *habeas corpus*, embora, verdade seja dita, a Turma não tenha

HC 166373 / PR

debatido essa questão. Mas, pedida a inversão da ordem, o *habeas corpus* foi denegado. Mas eu não consideraria um julgamento em lista em um precedente monocrático como jurisprudência consolidada.

O que nós estamos fazendo é julgando, pela primeira vez, um tema. E aqui, ao julgar esse tema pela primeira vez, penso, de maneira inelutável, que estamos criando, por interpretação constitucional, uma regra processual.

De modo que estabelecemos, como orientação, numa fase em que se objetivou, de uma maneira geral, todo tipo de procedimento no STF. Entendo que uma decisão do Plenário desta Corte deve ser observada pelas demais instâncias, seja em ação direta, seja em processo subjetivo; uma decisão do Plenário é uma manifestação de vontade da Corte Suprema do País.

O fato de não ter efeito vinculante formal...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

E o meu voto foi explícito quanto à necessidade de segurança jurídica, voto que foi fundamental para a formação da maioria, o que, de fato, também pensou a Ministra **Cármem Lúcia**, embora, no caso concreto, não tenha identificado o tal prejuízo.

A tese reflete o que nós debatemos e julgamos aqui. Trata-se disto: modulação é para dar efeitos futuros, como Vossa Excelência tem dito. Agora, fixação de tese é orientação para todo o Sistema de Justiça, e é importante isso.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - É exatamente isso.

O fato de o *habeas corpus* não produzir vinculação formal às demais instâncias não quer dizer que ele não deva ser seguido como orientação. E, evidentemente, se queremos que se siga a orientação, temos de esclarecer que orientação é essa.

Por isso, sem discutir ainda a questão das teses, adianto que ressaltarei o meu ponto de vista, que não prevaleceu, para acompanhar Vossa Excelência, mas creio - se a esse ponto chegarmos - imprescindível votar uma tese, do contrário, vamos cair em um subjetivismo judicial das

HC 166373 / PR

instâncias inferiores.

E aqui me parece também fora de dúvida que se produziu um voto médio. Vejam Vossas Excelências: o Ministro Fachin, eu, o Ministro Fux e o Ministro Marco Aurélio votamos no sentido de que não há previsão legal dessa inversão de ordem e que, não havendo previsão legal, não há ilegalidade em não se ter sido observada essa inversão. A posição da Ministra Cármen Lúcia foi no sentido de que não houve prejuízo, portanto, ela não votou na tese maior, não há previsão legal. A Ministra Cármen Lúcia disse: "Não tendo havido prejuízo, no caso concreto, denego a ordem." E os outros votos entenderam ou que, independentemente de lei, deveria ser assim, ou, como Vossa Excelência, que houve prejuízo e que, portanto, deve-se conceder a ordem.

De modo que média mesmo ficou sendo essa posição de Vossa Excelência e a posição da Ministra Cármen no tocante à exigência do prejuízo. Então, existem duas posições extremas, e existe uma posição intermediária.

Assim, entendo que a proposição de Vossa Excelência, coerentemente, legitimamente, indispensavelmente acena para os juízes do Brasil que vão julgar *habeas corpus* - e são mais de dezesseis mil juízes - o que o Supremo entendeu. Portanto, por que não vamos explicitar o que o Plenário do Supremo decidiu em uma tese?

Vossa Excelência bem sabe e os eminentes Colegas também que sou defensor da fixação de tese em todo e qualquer julgamento. Não há julgamento, não há voto que eu profira que não termine com uma tese, porque, como acredito que as instâncias todas do Judiciário devem observar a jurisprudência do Supremo, tenho de explicitar qual é o *holding*.

Quando se institui um sistema de observância de precedentes, tem-se que distinguir o que é mero comentário, mera reflexão, *obiter dictum*, daquilo que constitui efetivamente o julgado, a *ratio decidendi*, o que, em inglês, chama-se de *holding*.

Então, como creio que se deva fazer isso, em todo julgamento, mas ainda num julgamento da importância que este tem. E como o Doutor

HC 166373 / PR

Alcides Martins demonstrou num precioso parecer, que distribuiu a todos nós: "Produz um impacto potencial muito grande sobre o País, de uma maneira geral." E por que vamos deixar a insegurança jurídica prevalecer se podemos estabelecer o que claramente correspondeu à posição da maioria aqui?

De modo que voto, Presidente, veementemente, no sentido de que aqui, mais do que em todos os casos...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

Por enquanto, é a discussão se se fixa a tese, ou não.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Precisamos fixar uma tese.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**VOTO S/ PROPOSTA**

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER – Senhor Presidente, sem embargo da respeitabilidade da tese defendida por essa corrente liderada pelo meu querido amigo Luiz Edson Fachin, referendada pelos não menos queridos amigos Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e defendida pelo querido Ministro Marco Aurélio, e considerada, em especial, a enorme complexidade da teoria das nulidades processuais, tanto no processo geral, quanto, em particular, no processo penal, entendo que não há consenso na doutrina, nem na jurisprudência.

E assim defendi, no voto que aqui externei, que, na hipótese de afronta a princípios de extração constitucional, e é o caso dos autos – nós estamos tratando das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que são garantias asseguradas pela Lei Fundamental do País, a Lei das Leis, ou seja, há assento legal, a Lei fundamental –, configura-se hipótese de nulidade absoluta. Disse, com todas as letras, no voto que externei – repito – na assentada anterior.

E, em declarando que há nulidade absoluta, significa que não reconheço a ocorrência de preclusão, entendendo que ela pode ser pronunciada de ofício, e ainda que o vício pode ser suscitado em qualquer momento. E mais, o vício não prescinde da ocorrência de prejuízo, mas a diferença é a de que o prejuízo é presumido, ele não precisa ser demonstrado. Também não vou ao ponto de entender que essa preclusão é uma hipótese de preclusão *juris et de jure*, pois entendo que ela é uma presunção *juris tantum*, e a sua consequência é a inversão do encargo probatório.

Então não caberá, no caso, ao paciente demonstrar a ocorrência do prejuízo, e sim ao Ministério Público, ou seja, à parte contrária. No *habeas corpus*, o Ministro Marco Aurélio sempre diz que não há parte que se confronte ao impetrante. De qualquer sorte, entendo que caberia ao Ministério Público a demonstração da inoccorrência do prejuízo. Então, há

HC 166373 / PR

necessidade de prejuízo sim. O Ministro Fachin, no seu brilhante voto, invocou precedentes meus, em que digo *pas de nullité sans grief*, e, por isso, afastei a hipótese da nulidade, não reconhecendo a ocorrência do prejuízo.

Então, assentadas essas balizas, louvo o esforço de Vossa Excelência no sentido da formulação de uma tese que contemple o pensamento médio do Plenário. Com todo o respeito, não posso acompanhá-lo, em função das premissas que orientam o meu voto, mas, se Vossa Excelência está me questionando exclusivamente quanto à oportunidade da fixação de uma tese, a minha resposta é positiva.

Acompanho Vossa Excelência quanto à necessidade da formulação de uma tese orientadora. Por óbvio, não sendo a minha tese a vencedora, que talvez seja a mais obediente do Plenário, vou aplicar a tese vencedora em todos os meus votos, pedindo vênias ao Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu pela desnecessidade.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**VOTO S/ PROPOSTA**

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, de antemão, afirmo que estou de acordo com Vossa Excelência, de que deve ser fixada uma tese, tendo em vista que este julgamento do Plenário - é público e notório - vai repercutir para todo o Judiciário penal brasileiro. Primeiro.

Em segundo lugar, Senhor Presidente, hoje vivemos uma nova era em termos de Direito material e Direito processual. A regra hoje é que os tribunais respeitem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Hoje há, digamos assim, a teoria do *stare decisis* aplicada ao processo civil e ao processo penal. Nós já fixamos tese aqui em *habeas corpus*.

O novo Código de Processo Civil, o qual influi no processo penal pela própria admissão do Código de Processo Penal, que reconhece poderem ser aproveitadas as regras do processo civil, estabelece: "Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente."

É isso que Vossa Excelência está fazendo. Vossa Excelência está uniformizando a nossa jurisprudência sobre o que ocorre quando o delatado fala antes do delator ou no mesmo momento do delator. Segundo lugar.

Em terceiro lugar, estamos discutindo, Senhor Presidente, se devemos editar uma súmula sobre prejuízo em face da nulidade processual. Nessa discussão, estamos esquecendo que o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula. A Súmula nº 523 da nossa Corte diz o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu."

Essa é uma Súmula do Supremo, a nº 523.

Então, nesse caso em que há uma controvérsia relevante - tanto é assim que a Corte se dividiu -, é muito importante que haja a fixação de

HC 166373 / PR

uma tese. Eu não só concordo com o momento para a fixação da tese, como concordo com a tese que Vossa Excelência esposou no seu voto.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO S/ PROPOSTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Com as vênias do Ministro Alexandre de Moraes, quanto à necessidade ou à prudência de se fixar a tese, estou acompanhando Vossa Excelência e, na sequência, então, me manifesto.

(Publicado sem revisão. Art. 95, RISTF)

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO
S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, vou reafirmar o meu entendimento e dizer que a tese de Vossa Excelência, com o devido respeito, é, sim, uma modulação. Também com o devido respeito, quero dizer que, “ainda que se chame um gato de cachorro, ele não deixará de miar”.

Neste caso, estamos, sim, fazendo uma modulação temporal. Vossa Excelência está propondo - sempre com o devido respeito e sempre entendendo a preocupação de Vossa Excelência de conduzir esses trabalhos no sentido de que tenham o melhor desfecho possível -, no item 1 da proposta de tese - que entendo como modulação -, uma modulação temporal no sentido de que a nossa decisão aqui, tomada por uma maioria muito expressiva, não atinja aqueles que não se manifestaram *opportuno tempore* na fase do art. 403.

Portanto, Vossa Excelência quer imunizar, dos efeitos de nossa tese, aquelas situações às quais está fazendo referência, em que, de certa maneira, teria ocorrido uma preclusão, porque o réu não se manifestou no art. 403 do CPP.

Entendo, Senhor Presidente, ademais, que Vossa Excelência - e nesse ponto me parece que fez muito bem - invoca a segurança jurídica para modular. De fato - e veja como como é emblemática a expressão que utilizou - Vossa Excelência quer modular em função da segurança jurídica, que é exatamente um dos requisitos previstos no art. 927, § 3º do novo Código de Processo Civil.

Agora, segurança jurídica, em Direito Penal, objetiva proteger os acusados em face do arbítrio estatal. Existem vários exemplos, Senhor Presidente, no Direito Penal: a irretroatividade da lei penal mais grave; a anterioridade da lei penal; a impossibilidade da *reformatio in pejus*; a impossibilidade de revisão criminal invocando o *pro societate*. De maneira

HC 166373 / PR

que, quando se trata de segurança jurídica, em matéria penal, é para preservar os direitos do réu ou do acusado.

Então, aqui, Senhor Presidente, na modulação que Vossa Excelência propõe, na verdade - insisto -, estamos dando um contra-*HC*. Nós, ao invocarmos, a meu ver, com o devido respeito, de forma indevida a segurança jurídica, estamos prejudicando todos aqueles que não se pronunciaram na fase do art. 403.

E mais - já, talvez, adentrando um pouco no mérito, mais eu vou me pronunciar oportunamente -, o que acontece? Alguns réus, quiçá, mais abastados, contratam um advogado de escol, que tem a *expertise* para refutar todas as decisões que sejam adversas aos seus constituintes. Outros réus, mais humildes, que, muitas vezes, contentam-se com advogados, enfim, não tão experientes, ou mesmo advogados *ad hoc*, designados pelo juiz, não fazem essa impugnação no momento oportuno.

Então, pergunto, quer dizer, o erro do Estado-juiz vai prejudicar aquele que, eventualmente, não foi bem assessorado do ponto de vista técnico? E insisto nesse aspecto, Senhor Presidente: e aqueles que se encontram no mesmo processo, na mesma situação? Um réu abastado, muito bem defendido, que impugnou a decisão. E o outro, modesto, muitas vezes, largado nos fundos de um ergástulo, não teve condições de reagir.

E o que me chamou a atenção, Senhor Presidente - vivamente chamou a atenção -, e isso consta do memorial trazido pelos eminentes advogados - Bulhões e Advogados Associados S.A -, que essa questão só foi suscitada - vejam como é o processo penal nos dias atuais - no Evento 509.

No meu tempo, Senhor Presidente, quando eu advogava, ou quando integrava, com muita honra para mim, o egrégio Tribunal de Alçada Criminal, o advogado contestava decisões, eram meia dúzia de decisões ao longo de um processo criminal. Hoje, o advogado precisa estar atento dia e noite, 24 horas por dia, no seu computador para, aqui, contestar uma decisão que é chamada de Evento 509. Certamente um processo desse terá uns mil ou mil e quinhentos eventos.

HC 166373 / PR

Se prevalecer, com a devida vênia, a proposta de Vossa Excelência, o que vai fazer o advogado criminalista daqui para frente? Vai contestar, impugnar, todas as decisões dos magistrados, a 459, a 509, a 1.105, inclusive as de mero expediente, porque assim ele estará seguro. "Eu vou contestar tudo! Saiu um evento, contesto, refuto!" E assim ele estará seguro, porque ele se verá confortado por uma tese aqui do Supremo Tribunal Federal.

O que quero dizer, Presidente, é que estamos, sim, em face de uma modulação temporal, *data venia*, e se essa proposta de Vossa Excelência prevalecer, gostaria de insistir no aspecto de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no precedente ao qual fiz referência, que, para a aprovação dessa modulação que Vossa Excelência chama de tese, são necessários oito votos afirmativos.

É como me pronuncio quanto à admissão da modulação: contra, portanto, acompanhando o Ministro Alexandre de Moraes.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -

Presidente, inicialmente, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela condução e pelo voto que proferiu.

E nós, na assentada passada, não tivemos oportunidade - sobretudo, Ministro Celso e eu - de nos manifestarmos, fizemos uma ablação por voto por razões mesmo de tempo, tendo em vista que se impunha encerrar a votação naquele dia.

Então, gostaria de fazer duas pontuações antes de tratar do tema. Vossa Excelência já me honrou com a situação a propósito da questão do combate à corrupção que aparece no Pacto Republicano. Aqui, neste campo, ninguém me dá lições.

Agora, a minha preocupação com os abusos, nessa seara, vem de longe. Em relação à Lava Jato - eu tenho uma nota, vou só resumir - eu já dizia, ainda quando Relator do processo o Ministro Teori, em 2015, a mim me parecia que estávamos se aproximando do limite em que a prisão preventiva se torna antecipação da execução, a não ser que

HC 166373 / PR

haja outra justificativa. Era o *HC* de Renato Duque, 125.555.

Depois, eu disse que tínhamos um encontro marcado com essas alongadas prisões que se determinavam em Curitiba, e tínhamos que nos posicionar neste tema que, em grande estilo, discorda e conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo desses anos - Reclamação 25.362, Ministro Edson Fachin.

Vossa Excelência mesmo - e aqui também foi objeto de censura - o fato de restringir-se a competência da 13ª Vara, como se fosse uma competência universal, Vossa Excelência diz, Tribunal deixou claro, no caso de Vossa Excelência, deixou claro: "O fato da Polícia Judiciária ou o Ministério Público denominarem de fases da Operação Lava Jato, na sequência de investigações sobre crimes diversos, não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência". É algo mais ou menos óbvio, mas precisa-se dizer óbvio. "É que nenhum órgão jurisdicional pode se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins políticos-partidários". É o Inquérito 4.130, relatoria de Vossa Excelência, Questão de Ordem, em 23/9/2015.

Portanto, é esse o diapasão das minhas posições no que diz respeito a esses casos.

HC 166373 / PR

No julgamento do HC 132.267, impetrado por Marcelo Odebrecht, o próprio Relator reconheceu que a prisão não mais se justificava para assegurar a aplicação da lei penal ou para garantia da ordem, mas a segregação cautelar foi mantida pela Segunda Turma como medida extrema pela conveniência da instrução criminal.

Na ocasião, destaquei que, mesmo em caso rumorosos, venho ressaltando a jurisprudência do Tribunal a proposta da excepcionalidade da prisão provisória. Naquele caso, não se tinha qualquer notícia de colheita de provas em andamento que pudesse ser prejudicada pela libertação do paciente. Hoje se sabe, de maneira muito clara - e o *The Intercept* está aí para confirmar e nunca foi desmentido: que se usava a prisão provisória como elemento de tortura - custa me dizer isto no Plenário, mas era instrumento de tortura; e quem defende tortura, não pode ter acento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isso aparece hoje, Ministro Fux, nessas declarações do *The Intercept*, feitas por gente como Dallagnol, Moro. É preciso que se saiba disso, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal.

Quando foi divulgado, em 2016, as tais dez medidas,

HC 166373 / PR

eu fui a voz que se levantou, creio que a única neste Tribunal, sobre as suas impropriedades. O que disse:

“Tenho impressão de que estamos vivendo momento singular [...] Depois, esses falsos heróis vão encher os cemitérios, a vida continua.”

Sou o maior profeta, Presidente, Doutor Alcides, porque isso eu falava em 2016 e aconteceu.

O resumo da ópera é: Você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o "ó do borogodó". Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia, calcem as "sandálias da humildade".

Mesmo sujeito às contingências do convencimento do Colegiado nas ações julgadas pela Segunda Turma e pelo Plenário, busquei advertir sobre os descomedimentos de um inovador e criativo modelo de Justiça criminal negocial que se alastrava pelo País com os acordos de colaboração premiada da Lei nº 12.850/2013. No emaranhado de acordos negociados pela força-tarefa de Curitiba, podemos afirmar que vimos de tudo.

Ao apreciar a Questão de Ordem na PET 7.074, em que esta Corte discutia os poderes do relator para homologação dos acordos

HC 166373 / PR

de colaboração premiada celebrados entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo J&F, meu voto trouxe sérias advertências sobre os abusos cometidos pelo Parquet na celebração de tais acordos.

Aqueles acordos em que atuava aquela dupla Fernanda Tórtima e Miller - e o Doutor Janot, com a sua sobriedade e característica, conforme confessa em livro que acaba de lançar.

Eu citei - não vou cansá-los - todas as medidas *extra-legal* que se tomaram neste acordo.

O acordo de Sérgio Machado, a propósito, notabilizou-se por ser talvez o mais engenhoso e inventivo que a Lava Jato pôde ter produzido. O acordo colocava a salvo da recuperação de ativos bens em nome de familiares, especialmente dos filhos do colaborador. De forma flagrantemente *contra legem*, o acordo previa que o Ministério Público se comprometia a postular que as sentenças em ações de improbidade administrativa ajuizadas contra o colaborador teriam natureza meramente declaratória.

Complemento esse inventário com outras pérolas.

O ciclo de engenhosidades parece ter atingido o seu ápice na previsão de novos regimes de execução de pena privativa de

HC 166373 / PR

liberdade não imaginados pelo legislador.

O mesmo acordo de Sérgio Machado previa a "obrigação" de o delator cumprir a sentença de prisão em sua própria residência particular durante o período negociado, sendo-lhe permitido sair da residência, em oito dias por ano, por um período de seis horas contínuas. O acordo continha como anexo um rol de 27 amigos e familiares que poderiam visitar a residência. Já o acordo de João Cerqueira de Santana Filho estipulava que o réu deveria ficar apenas das 20h às 6h em sua casa, sendo autorizadas viagens para o exterior para tratamentos de saúde.

Diante de todas essas constatações, no julgamento da referida PET 7.074-QO, em meu voto, mesmo sem deixar de reconhecer os avanços que a Operação trouxera para o combate à corrupção no País, externalizei, com veemência, as minhas recalcitrâncias quanto às verdadeiras finalidades dos membros da força-tarefa. Nesse sentido, destaquei à época que: A preocupação [da Operação Lava-Jato] em produzir volume de investigações, com ou sem futuro, parece ter se tornado, com as vênias de estilo, ou sem vênias, um dos objetivos do Grupo de Trabalho da Procuradoria-Geral da República. Os objetivos da

HC 166373 / PR

Lava Jato não são imediatamente políticos. A disputa é por poder entre Poderes do Estado. E depois, isso está caracterizado nas revelações, agora, do *The Intercept*.

Para além das vaidades pessoais, está em formação um quadro que permite que o processo penal domine o jogo político. Complementadas pelo tapetão eleitoral costurado pela Lei da Ficha Limpa, as investigações de macrocriminalidade das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do País - basta abrir um inquérito sem controle.

E agora quem o diz não sou eu, é Dallagnol, quando diz que imaginava lançar quatro procuradores como candidatos ao Senado. E dizia: "Pobre do Álvaro. Eu vou derrotá-lo, porque só tem uma vaga e a vaga é minha". Era um sujeito tão vaidoso, que dialogava com espelho - no caso, o *Telegram* - contando isso. Vejam: o partido dos procuradores! Um projeto político. E não sou eu que estou dizendo, mas eu disse isso antes.

Na apreciação do HC 143.333, impetrado por Antonio Palocci, dediquei parte do meu voto a denunciar que a corrupção já havia chegado à Procuradoria e falei dos episódios Miller, Fernanda Tórtima e

HC 166373 / PR

tudo o mais. Em 16 de março de 2009, ainda antes de serem reveladas as mensagens do *The Intercept*, o Tribunal julgou o Inquérito 4.435, quarto agravo regimental, de que era Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual se discutia a extensão da competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais previstos no inc. IV do artigo 109 da Constituição e no inc. II do artigo 35 do Código Eleitoral.

Mais uma vez não me furtei a denunciar.

Na oportunidade, busquei deixar claro a tentativa do Ministério Público de mudar a competência da Justiça Eleitoral, a qual permanecia incólume todas as constituições brasileiras - diga-se de passagem, por amor à verdade. Não houve modificação de entendimento nesta matéria.

É preciso o combate à corrupção dentro do Estado de Direito.

Não se pode combater a corrupção cometendo crimes, ameaçando pessoas, exigindo delações, ou fazendo acordos, tendo o irmão como dono de escritório por que passam as delações. Tudo isso não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias brasileiras. O Esquadrão da Morte é fruto disto.

HC 166373 / PR

É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito. Conúbio entre Julgador e Polícia... Pode ter até algum fetiche, até de índole sexual. Moderação aqui!

Julgador é órgão de controle, não é órgão de investigação. Tenho minha consciência tranquila, Presidente, de que desde as fases iniciais da operação, ainda em 2014, exerci de forma responsável o controle jurisdicional dos atos praticados pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público e pelo próprio Poder Judiciário relacionados à apuração de fraudes no sistema Petrobras.

Mas, Presidente, é muito interessante agora a análise - e eu não vou ter tempo de fazer isso de maneira aprofundada, mas certamente o terei em outras oportunidades - das mensagens que vem do *The Intercept*.

Não parece haver dúvida de que o Juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais.

Quem acha que isso é normal, certamente não está

HC 166373 / PR

lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal.

Ao apreciar a denúncia formulada contra o suposto operador Zwi Skornicki, Moro deu por falta de provas de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro *coach* da acusação, o juiz avisou a Deltan, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que "tem um depósito em favor de Musa e se for por lapso que não foi incluído, ele vai receber amanhã e dá tempo". O magistrado ainda tinha a função estratégica de sugerir aos procuradores a ordenação das fases da operação, considerando, é claro, o seu interesse midiático.

O quadro de esquizofrenia na função de juiz não chega a passar despercebido pelos próprios membros da Força-Tarefa. Em mensagem atribuída à Doutora Monique Cheker, a Procuradora demonstra ter clareza de que Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Está aqui no *The Intercept*.

Aqui não há como deixar de reconhecer que a própria dignidade dos membros do Supremo foi vilipendiada, Presidente, em diversos episódios dessa triste tragédia.

Em um dos lamentáveis episódios descobertos, após a

HC 166373 / PR

Polícia Federal ter anexado aos autos um processo da Lava Jato e indícios probatórios envolvendo autoridades com foro no STF, Moro e Deltan, com o apoio da Procuradoria-Geral da República, articularam a escolha de qual inquérito o juiz deveria encaminhar para o STF:

Falei com o Pelella. Ele disse que se resolve com a remessa dos autos. Ajustei mandar à Odebrecht e disse que manteria Zwi e Santana, com o que ele concordou, e disse que cindirão e devolverão. E confidenciou que, na próxima semana, a pressão se transferirá para lá e esquecerão isso. Quanto à decisão de ontem, ele disse que certamente as coisas se acalmarão.

Isso para não falar, Presidente, das investidas dos membros da Força-Tarefa para investigar Ministros do Supremo. Em outro célebre diálogo, Dallagnol, sem o menor pudor, pede ao ex-chefe de gabinete da PGR, o Pelella, o endereço do Presidente Dias Toffoli, a fim de trabalhar em dados de inteligência.

Pelella, queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o competente é o PGR (risos), mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação, acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado?

Era para envolvê-lo, Presidente, na delação da OAS.

Era disso que se tratava. Como denominar isso, Presidente? Como

HC 166373 / PR

denominar isso? Poucos dias depois, pede-se de novo a informação, e Pelella dirá: "Não é apartamento, é casa onde Tofolli mora". E lhe fornece o endereço. É disso que nós estamos falando, Presidente!

Essas insinuações parecem ter atingido seu grau máximo, quando, insatisfeitos com a concessão de ordem, em sede de *habeas corpus*, os membros da Força-Tarefa iam em evidente delírio e elucubraram que eu seria beneficiário de contas e cartões de crédito mantidos na Suíça.

Na ocasião, a possibilidade de membros do MP apurarem dados a respeito dos Ministros do Supremo é tratada com ironia e desdenho. "Vai que tem um para o Gilmar, hehehe", diz o Procurador Roberto Pozzobon.

Aparentemente, nem os relacionamentos entre os membros desta Suprema Corte escapavam ao conhecimento dos membros da Força-Tarefa, que previamente já contavam com os votos e posicionamentos de cada um de nós.

Em uma das anedotas assaz curiosa, Dallagnol conta para os Procuradores que Fux disse, quase espontaneamente, que Teori fez "queda de braço" com Moro e viu que se queimou. Portanto, não

HC 166373 / PR

podia lutar contra Moro. Dallagnol teria revelado, ainda, que os Procuradores da Lava Jato podiam contar com Fux no que fosse preciso. Ao saber do diálogo, Moro sagra: "*In Fux we trust*".

Até o próprio Relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, que sempre se destacou pela sua mais absoluta integridade e isenção em seus posicionamentos, era taxado como um Juiz conivente com a organização criminosa de Curitiba. Em outra conversa, Deltan aponta: "Caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Aha, Uhu! O Fachin é nosso!"

Sequer a Ministra Cármen Lúcia foi poupada: Após tomarem ciência de que uma ADPF ajuizada pela Rede Sustentabilidade houvera sido distribuída à eminente Ministra, os Procuradores não revelam nenhum pudor ao acusá-la de "frouxa".

A configuração de um quadro sistemático e reiterado de ofensas à legalidade e aos princípios constitucionais da ampla defesa dos investigados tornou-se incontroversa com o desvendamento de uma verdadeira máquina de provas ilícitas, que era utilizada pela Lava Jato muitas vezes de forma espúria e para enganar o Judiciário e o próprio Supremo Tribunal Federal. As informações reveladas dão conta de que a

HC 166373 / PR

força-tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça, em Mônaco e contatos com a Receita.

Vejam que aqui há uma passagem, que eu estou omitindo, de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Leonel - que depois veio para o Coaf -, em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita, relativos a familiares do presidente Lula. E depois pergunta: será que essa vista d'olhos passará ao largo do seu supervisor em Brasília? Portanto, investigação informal na Receita, Presidente.

Não é por acaso, Presidente, que hoje os jornais estampam - e vem de novo do Rio de Janeiro essa notícia - que um fiscal ligado à Lava Jato, supervisor de programação da Lava Jato, foi preso, por estar vendendo informações para fiscais, para empresários que estavam sendo achacados: Marco Aurélio da Silva Canal, que estava fazendo investigação, inclusive, em relação a mim, na Receita, certamente a mando dessa gente.

É esse o quadro, Presidente: *gangsters* no comando de investigação. É disso que estamos a falar! Lamentavelmente! Isso tudo está documentado.

Cabe ressaltar, Presidente, que esses mecanismos

HC 166373 / PR

obscuros de obtenção de prova foram utilizados nas investigações contra réus que tentaram se socorrer com a impetração de *habeas corpus* no Supremo Tribunal Federal, muitos deles sem êxito.

O próprio sistema *Android* da construtora Odebrecht, que é fonte de elementos indiciários utilizados em diversos inquéritos e ações penais da Lava Jato, foram clandestinamente acessados pelos procuradores, pelo menos um ano antes da celebração de acordo com os 78 executivos da empreiteira, quando o acesso ao sistema teria sido oficialmente concedido ao MP. É esse o cenário dantesco de violação à legalidade que nos traz até aqui!

Parece-me ter chegado o momento de fazermos uma avaliação crítica de postura desta Corte Constitucional.

E eu realmente tenho muito orgulho de ter, desde o primeiro momento, apontado falhas nesse sistema. Elogiei, e elogio, e reconheço, de fato, que a corrupção tinha atingido níveis preocupantes, e é preciso que se combata, mas eu sempre disse: combater crime sem cometer crimes. E, antes, não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. Nós não sabíamos. E 1,2 bi iria para o Dr. Carvalhosa, para os clientes do Dr. Carvalhosa. Sob

HC 166373 / PR

que razão? O Ministro Alexandre, na decisão que tomou na ADPF, corajosamente proposta pela Doutora Raquel Dodge, apontou a ilegalidade desse acordo e reverteu esse dinheiro para as finalidades públicas.

Então, Presidente, é muito sério que se debata esse tema com profundidade, que todos saibamos do que se está falando. O que se sabe hoje já é muito grave e não se sabe tudo. Dizia-me o cineasta José Padilha que só se divulgou um por cento de tudo aquilo que se acumulou. Portanto, ainda há muitas novidades em torno dessa temática, mas tudo o que há é chocante e, de fato, altamente comprometedor para aquilo que se chama uma investigação isenta.

Agora, Presidente, dois minutos a propósito da alegação de que haveria impropriedade no conhecimento dessas matérias, porque teríamos precedentes contrários.

Àqueles da minha relatoria chamo a atenção.

Parecer do eminente Procurador-Geral faz referência ao HC 137.316 ao qual neguei seguimento monocraticamente. Em tal *habeas corpus*, efetivamente, questionou-se a tese da inversão da ordem de alegações finais de colaboradores e delatados. Contudo, nessa decisão,

HC 166373 / PR

não enfrentei o mérito da questão, ao passo que havia óbice formal ao conhecimento do feito.

Já no *HC* 167.727, em respeito ao direito de defesa, deferi medida liminar para assegurar a produção de diligências complementares, ou seja, direito à prova defensiva. Esse era o pedido principal do *habeas corpus*. Depois da produção das provas, determinei a reabertura do prazo de alegações finais nos termos do CPP, mas não enfrentei diretamente a questão da ordem das alegações em relação a corréus, colaboradores e não colaboradores.

Por fim, no *HC* 108.476, mencionado pelo eminente Relator em seu voto, penso não se tratar propriamente de um caso contrário à tese de prazos sucessivos entre colaboradores e delatados. Nesse precedente, o paciente alegava nulidade da sentença pelo fato de a acusação ter se manifestado por último em sede de alegações finais. Em tal decisão, afastei a tese da nulidade, observando que, no caso concreto, o paciente voluntariamente antecipou-se à intimação legal e apresentou alegações finais antes do MP, ou seja, a Defesa adotou essa estratégia porque o MP já havia, em manifestação anterior, pedido a absolvição do paciente. Contudo, nas alegações finais apresentadas posteriormente, o

HC 166373 / PR

MP acabou pleiteando a condenação do paciente. Assim, o fundamento da decisão assentou no fato de que o réu teria dado causa à alegada nulidade e que, por uma proibição de comportamento contraditório, não poderia requerê-la posteriormente. Lá destaquei que, no sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do *venire contra factum proprium*, em abono aos princípios da boa-fé e da lealdade processuais.

Quanto à proposta da questão de ordem por Vossa Excelência formulada, entendo que talvez fosse recomendável, como já fizemos em pelo menos dois outros casos memoráveis - o caso da súmula das algemas e da questão da progressão de regime -, que formulássemos uma súmula com caráter vinculante. Mas não repudio a ideia de fixação de uma tese, porque entendo que, de fato, e esse foi o propósito do Relator, como já foi dito, inicialmente, de trazer a questão para um debate. Porém, entendo que devemos ter muita cautela nessa formulação, tendo em vista exatamente os aspectos que estão envolvidos e a delicadeza do tema.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, o que estamos a julgar?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE):

É a decisão sobre se vamos ou não fixar uma tese. No atual momento, há os seguintes votos pela formulação de tese a partir do que julgamos no encerramento da votação do HC de hoje. Votam a favor de fixarmos tese: eu mesmo, que a propus – mas não estamos a discutir seu conteúdo, só a fixação, ou não –, e os Ministros Luiz **Edson Fachin**; Luís **Roberto Barroso**; Rosa **Weber**; Luiz **Fux**; **Cármem Lúcia** e, agora, **Gilmar Mendes**. Votam pela não fixação de tese os Ministros **Alexandre de Moraes** e **Ricardo Lewandowski**.

Agora, colho o voto de Vossa Excelência.

02/10/2019

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, no dia de ontem, conversava com Colegas da Primeira Turma e dizia da inadequação de, no campo penal, processual penal, editar-se, até mesmo em cima de reiterados pronunciamentos do Tribunal, verbete de súmula.

Qual seria, no julgamento de um *habeas corpus*, com o Tribunal dividido quanto ao fim desse julgamento, o objetivo da edição de uma tese? Contribuir-se para a colocação de casos e casos na vala comum, deixando-se de apreciar singularidades? Colocar a magistratura nacional numa camisa de força? A tentação de legislar, vejo ser muito grande, Presidente.

Forte no voto que proferi, nesta assentada, indeferindo a ordem, tenho que não cabe ao Supremo partir para esse perigoso campo, transgredindo medula da República, que é a revelada pela existência de Poderes independentes e harmônicos.

De qualquer forma, formei da corrente minoritária e não posso, agora, no bojo deste mesmo *habeas corpus*, em que fiquei vencido, eleger, aprovar tese diametralmente oposta à que sustentei. Partiria para o campo – não é o entendimento dos demais Colegas – da absoluta incoerência.

Portanto, Presidente, cinjo-me ao processo subjetivo, cinjo-me ao julgamento dessa ação constitucional nobre, no que voltada a preservar a liberdade de ir e vir, que é o *habeas corpus*. E tenho como encerrada a jurisdição. Guardarei que a maioria, a sempre ilustrada maioria, concluiu em sentido diverso ao entendimento que sustentei, quando acompanhei o Relator, ministro Luiz Edson Fachin, e refletirei sobre a conclusão assentada.

Entendo que não cabe a edição de tese, transformando processo subjetivo em objetivo, e talvez se cogite da eficácia linear dessa tese para admitir-se, posteriormente, inclusive, em processo diverso, quem sabe, a reclamação, multiplicando-se o número desse procedimento, no que voltado a preservar a competência do Supremo, o respeito a decisões que

HC 166373 / PR

profira.

É como voto, Presidente.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que concediam a ordem de *habeas corpus*; e dos votos dos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Edson Fachin (Relator), no sentido de denegar a ordem, o julgamento foi suspenso. Não votou, nesta assentada, o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.9.2019.

Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de *habeas corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste *habeas corpus*, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.

Presidência do Senhor Ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

30/11/2022**PLENÁRIO****HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ**

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

OBSERVAÇÃO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) – Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a eminente Ministra Cármen Lúcia, os eminentes Pares, o Senhor Procurador-Geral da República, os Advogados e as Advogadas.

Senhora Presidente, Vossa Excelência vem de fazer uma síntese exata desse Habeas Corpus 166.373 que, originariamente, estava sob minha relatoria.

Como Vossa Excelência bem posicionou, submetido o mérito ao julgamento deste Plenário, restei vencido na companhia de eminentes Colegas, prevalecendo o primeiro voto divergente, lançado pelo Ministro Alexandre de Moraes, que se tornou, portanto, Redator para o acórdão.

Naquela assentada, presidida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, propôs-se a fixação de uma tese. Restou debatida essa possibilidade e a proposição sobre a fixação da tese restou vencedora. Vencido, por registro, o eminente Ministro Redator para o acórdão.

Nada obstante vencido, na assentada de hoje, embora conste meu nome como Relator, a palavra é de Sua Excelência o eminente Ministro Alexandre de Moraes, que, embora vencido, traz tese que se alinha com a fixação majoritária do conteúdo desatado quanto ao mérito.

HC 166373 / PR

Então, Senhora Presidente, era desnecessária minha intervenção. Faço esse transcurso apenas almejando que, do ponto de vista formal, concluído esse julgamento, conste, inclusive nas anotações respectivas, que Sua Excelência é o Redator para o acórdão - ainda não se fez porque o julgamento não acabou. Por isso, continua ainda, formalmente, sob minha relatoria.

Muito obrigado a Vossa Excelência!

30/11/2022

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

PROPOSTA

(s/ TESE)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER

(PRESIDENTE) - Muito obrigada, Ministro Luiz Edson Fachin! É sempre muito bom ouvi-lo.

Na verdade, o Ministro Alexandre de Moraes apresentou o primeiro voto que saiu vencedor. Sua Excelência ficou vencido apenas quanto à proposição de que não se deveria fixar uma tese, mas, em termos de conteúdo do *habeas corpus*, a posição do Ministro Alexandre de Moraes terminou majoritária.

Por isso, passo a palavra a Sua Excelência para que proponha, então, a tese.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES

(REDATOR) - Obrigado, Presidente!

Cumprimento Vossa Excelência, Ministra Rosa Weber, a Ministra Cármen Lúcia, os eminentes Colegas e o Procurador-Geral da República, Doutor Augusto Aras.

HC 166373 / PR

Presidente, como Vossa Excelência recordou e o Ministro Edson Fachin também, aqui foi discutida a questão da ordem de apresentação das alegações finais. Por maioria, entendeu-se, nos termos do meu voto - primeiro voto divergente do eminente Relator -, que o réu teria o direito de falar por último, e isso estaria contido no exercício pleno da ampla defesa, inclusive em falar depois do delator ou colaborador premiado.

Também ficou definido - e isso foi objeto de um debate importante - que a não observância dessa sequência acarretaria a nulidade, desde que tivesse ocorrido o pedido do réu, ou seja, os processos em que a defesa não solicitou falar por último seriam absolutamente válidos. Nos processos em que a defesa solicitou falar após o colaborador ou delator, e isso não foi deferido, aí, sim, haveria a nulidade.

É importante esse corte porque isso foi muito discutido nos debates. Levando em conta esses dois pontos importantes, sugiro a fixação da seguinte tese, que inclusive já passei a todos os Colegas:

Havendo pedido expresso da defesa, no momento processual adequado, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a

HC 166373 / PR

manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade.

É a proposta, Presidente.

30/11/2022

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

DEBATE

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, peço a palavra. Renovo meus cumprimentos a todos e agora, especialmente, ao relator e ao eminente Ministro Alexandre de Moraes.

Eu recebi antecipadamente a proposta de tese de Sua Excelência e hoje, examinando-a logo de manhã, eu tive uma certa dúvida e acredito que há aqui uma expressão que pode levar a uma certa ambiguidade. Eu proporia, com o devido respeito, com a devida vênia, a sua ablação.

Aqui, nós estamos dizendo o seguinte: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Esta expressão "no momento processual adequado", a mim me parece que pode causar uma certa perplexidade e levar uma certa discricionariedade do juiz em determinar qual seria o momento adequado. Ou nós retiramos essa expressão - e parece-me que não teríamos prejuízo nenhum -, ou então faríamos referência ao dispositivo do Código Processo Penal que trata das alegações finais.

Penso que poderíamos redigir a tese simplesmente dizendo o seguinte: havendo pedido expresso da defesa, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade. Tiraríamos "esse momento processual adequado", salvo melhor juízo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Na verdade, essa foi a grande discussão após o julgamento, porque, fixada a tese, se agora o réu, já em sede recursal, pedir essa nulidade, não é mais nulidade. Então, o momento processual adequado é o momento da apresentação... Quando o juiz abre o prazo para alegações finais, ele deve se manifestar - eu só vou falar e peço para me manifestar após o delator. Foi muito discutido, exatamente, evitar nulidades em todos os casos em

HC 166373 / PR

que o réu não pediu, nem ele próprio pediu, o seu advogado não pediu, então não poderia arguir agora um prejuízo não existente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu concordo com esse aspecto, *data venia*, e acho que é perfeitamente...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Posso ajudar?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Acho que nós estamos de acordo que o momento processual adequado seria a abertura para as alegações finais.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Exatamente.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu acho que resolveria o problema suscitado pelo Ministro Lewandowski se nós colocássemos, entre parênteses, aqui CPP, artigo tal. E aí estava resolvido.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois é. Havendo pedido expresse da defesa, os réus têm direito...

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - No momento processual adequado, entre parênteses, o dispositivo do CPP. É isso?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ou na forma do artigo "x" do CPP, que, salvo engano, é o 403, § 3º.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Se alguém souber qual é o artigo, a gente agradece.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Não, sei, o Ministro Ricardo é quem sabe, estou sem o CPP.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - É o 403.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente, colocaria o 403: "Não havendo requerimento de diligência, ou sendo indeferida, serão oferecidas alegações finais orais, por vinte

HC 166373 / PR

minutos pela acusação, prorrogáveis por mais dez, tal, tal. Não, não é o 403.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - É o 403, § 3º.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - O juiz poderá conceder... Eu acho que é o 403 como um todo, porque, mesmo oralmente, também deverá ser após o colaborador, então colocaremos o 403.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Perfeito, assim não teríamos dúvida quanto ao momento adequado, que é o momento previsto na legislação processual penal.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Então, ficaria assim, Ministro Lewandowski: havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado, CPP, art. 403, os réus terão o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - De acordo.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Também de acordo.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Todos de acordo?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, eu fiquei vencido parcialmente quanto à aplicação retroativa desse entendimento, mas estou de pleno acordo com a tese, e acho que é muito importante nós fixarmos a tese - acho que o Tribunal fez bem -, porque serve de orientação para todos os tribunais e vamos evitar uma enxurrada de nulidades.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Na linha do que Vossa Excelência defendeu hoje na brilhante manifestação no nosso encontro sobre precedentes.

O Ministro Luís Roberto sustentou a importância da tese, da fixação de tese. Estamos aqui, no *habeas corpus*, a fixar a tese.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Até citei

HC 166373 / PR

Vossa Excelência, Ministro Gilmar, porque esse é um caso que vai muito ao encontro do que Vossa Excelência sustenta, que é tornar as decisões, mesmo em processos subjetivos, em alguma medida, pelo menos, vinculantes. Aqui, ao fixarmos a tese, é o que nós estamos fazendo.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Em matéria de questões formais, isso tem uma enorme repercussão.

Já discutimos aqui, por exemplo, um *habeas corpus* sobre a progressão de regime, no qual declaramos a inconstitucionalidade da impossibilidade de progressão nos crimes hediondos. Eu me lembro que, encerrado o julgamento, o Tribunal houve por bem mandar aplicar de forma genérica, autorizando que cada Ministro fizesse essa aplicação individualizada. Portanto, era uma orientação, até porque todos nós acumulávamos um número significativo de processos tratando do mesmo tema.

Então, acho que é fundamental que a gente avance. Há também um ponto. Até recentemente eu fiz uma adaptação - acho que um voto do Ministro Barroso - no sentido - hoje, perde um pouco de relevância - de não distinguir, para os fins gerais, a declaração de inconstitucionalidade posta em processo com repercussão geral daqueles outros em que declaramos inconstitucional, embora sem que o processo tenha sido reconhecido como de repercussão geral. Parece-me que, se o Plenário do Supremo declara a inconstitucionalidade de uma dada lei, isso é suficiente, *tollitur quaestio*, para todos os fins.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Obrigada, Ministro Gilmar!

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite?

Eu estava observando e há uma dúvida também que remanesceu. Nós temos, nos tribunais superiores, uma lei específica que trata da tramitação dos processos penais e outros procedimentos, que é a Lei nº 8.038. Essa lei se refere também a um prazo de alegações finais, dizendo o seguinte:

“Art. 11 - Realizadas as diligências, ou não sendo estas requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas a

HC 166373 / PR

acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem, no prazo de quinze dias, alegações escritas”.

Isso, a meu ver, corresponde às alegações finais no Código de Processo Penal, que rege o procedimento nas instâncias inferiores da Justiça. Eu não sei se deveríamos fazer também referência a esse artigo da nossa lei especial.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência me permite um aparte?

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Pois não.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Antes, cumprimento todos na pessoa da nossa Presidente, ministra Rosa Weber.

Era uma lembrança semelhante à que Vossa Excelência fez, duas expressões me chamaram a atenção. A primeira já foi solvida, em relação ao momento processual adequado. A outra é a necessidade de um pedido expresse.

Entendo a justificativa desse pedido expresse com olhos no passado, à vista de processos em curso e em fase avançada, para se evitar uma enxurrada de nulidades, que não seria razoável. No entanto, não podemos esquecer: a lei que define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal e obtenção de provas, de n. 12.850/2013, sofreu alteração em 24 de dezembro de 2019, praticamente no ano 2020, no § 10-A do art. 4º, que dispõe:

Art. 4º [...]

[...]

§ 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.

Então, com olhos voltados ao futuro, nossa decisão, quando menciona “pedido expresse”, acaba por limitar um direito já posto, a partir de 24 de dezembro de 2019, que garante, independentemente de haver ou não pedido expresse, poder o réu delatado falar por último. Então, minha preocupação é essa, sem de forma alguma afastar aquela já bem-colocada pelo ministro Alexandre de Moraes, da qual comungo também, mirando o passado. Penso que, antes dessa legislação, como não

HC 166373 / PR

havia previsão, aí, sim, deveríamos adotar o pedido expresse.

A partir de então, a lei que cuida desse rito especificamente, das colaborações premiadas, já garante ao réu delatado o direito de falar após o delator. E na mesma fase colocada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Minha preocupação é, a partir de então, ainda assim, exigir pedido expresse quando a lei lhe garante esse direito.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu acho que o problemático aqui é que, sem um pedido expresse e fixação de um momento, acaba podendo pedir a qualquer tempo. E aí pode pedir, não pede no momento certo, espera a sentença e depois pede nulidade. Portanto, eu acho que há um risco grande de nós termos a enxurrada de pedidos de nulidades que a gente quer evitar.

Eu entendo a preocupação do Ministro Nunes Marques, porque ele disse que é um direito subjetivo, não deveria estar sujeito a pedido expresse.

Mas, no fundo, o mais importante aqui é estabelecer o momento até o qual se pode pedir, sob pena de se poder anular, a qualquer momento, o processo, pedindo vênua e entendendo a posição do Ministro Nunes Marques.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Mas conjugando com a sugestão do ministro Ricardo Lewandowski, de o pedido ficar limitado ao prazo imediatamente posterior ao que foi concedido ao réu que o delatou. Não pode ser a qualquer momento, ou depois do proferimento da sentença, já em fase recursal. Minha preocupação também é esta: que hoje apareça um pedido num processo em tramitação numa Corte superior que deseje essa nulidade. Só lembro que esse direito passou a existir em 24 de dezembro de 2019. Então, poderíamos fazer um...

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Mas, veja, aberto o prazo para as alegações finais, ele entra nos autos e diz: eu quero falar depois.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Exatamente.

HC 166373 / PR

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Mas ele já tem esse direito hoje.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Os Colegas me permitem?

Esse é um dos dilemas da metodologia da fixação das teses, cuja metodologia é extremamente importante, e creio que, no fundamental, todos estamos de acordo. É que, no momento de fixar a tese, se reabrir o debate, nós voltamos a apreciar o mérito do que foi deliberado. É preciso guardar uma simetria entre o conteúdo da tese e o conteúdo do que foi deliberado.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - É a adstrição ao caso julgado.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ao conteúdo do julgamento.

O que o Ministro Nunes Marques traz à colação é um tema relevante, mas isso não foi tratado no desate do mérito.

A tese, tal como formulada, é fiel, portanto cumpre o desígnio de lealdade com o que foi discutido e o que foi deliberado. Se ela se apresentar insuficiente para casos outros, certamente esse tema voltará aqui em algum modo ou forma, e nós voltaremos a deliberar, porque, se esse tema for posto à discussão à tese, aí, eu peço a palavra para retomar o meu voto.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Veja bem. Minimamente serve, pelo menos, para demonstrar o seguinte: a partir de determinado momento, de certo marco temporal, que foi a nova redação dada ao § 10-A do art. 4º da Lei n. 12.850, a partir de 24 de dezembro de 2019, esse direito passou a ser subjetivo.

Então, como estamos tratando aqui de tese, fixando essa tese, estaríamos, por via oblíqua, e não diretamente, abordando, fazendo uma negativa de vigência.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Permite-me, Presidente?

Eu também aqui concordo plenamente com o Ministro Edson Fachin, porque nós poderemos ir mais além, poderemos entrar na

HC 166373 / PR

questão. Mesmo com a nova fixação da lei, se o juiz observou isso, mas não ocorreu nenhum prejuízo, também não é novidade. Então, se nós não ficarmos no que foi discutido, e eu lembro de nós debatermos isso amplamente, daí não é uma tese, daí nós vamos virar um código.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, pela ordem. Primeiro saudando Vossa Excelência, como os demais integrantes do Ministério Público, os alunos presentes, o Código de Processo Civil inaugurou essa nova metodologia dessa jurisprudência estável, do precedente. Nessa ocasião, nós estabelecemos que, quando o juiz não aplicar o precedente, ele tem de justificar que não é relativo a um caso que deu ensejo ao precedente. Por isso que existe o instituto do *distinguishing*, da distinção, da superação. Então, a regra na fixação do precedente é o precedente aplicável a casos análogos ao caso julgado.

Então, pedindo todas as vênias ao Ministro Nunes Marques, eu acho que é importante o Tribunal ser minimalista, porque senão a gente vai abrir uma chance para a anulação de inúmeros processos. É claro que a lei todo mundo conhece.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Até porque, Ministro Fux, esse julgamento ocorreu em momento anterior à lei que veio em 24 de dezembro de 2019. As nossas decisões foram tomadas em 25 de setembro, 26 setembro e 2 de outubro de 2019. Com relação a esta decisão, que se segmentou, ou foi tomada nesses três segmentos, é que estamos estabelecendo a tese.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Mas a tese está sendo fixada hoje, Senhora Presidente.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Como retrato, como reflexo deste julgamento.

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Mas como luz, como um farol a guiar a jurisprudência nacional, e não podemos olvidar que agora, neste exato momento, nosso direito positivado traz um direito subjetivo da parte, acho que não é difícil decotar, são momentos diferentes. Até então, houve necessidade de um pedido expresso; daqui para a frente, não haverá. A lei já dispõe dessa forma.

HC 166373 / PR

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Eu compreendo a posição de Vossa Excelência, mas acho difícil estabelecer uma tese quanto a algo que não foi debatido aqui em momento algum.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Não foi nem discutido.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu, *data venia*, compreendo a preocupação do Ministro Nunes Marques.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Eu também compreendo, é relevante.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu compreendo, porque o Ministro Nunes Marques está preocupado em que nós não estabeleçamos um conflito entre a tese e a lei agora vigente, quer dizer, hoje nós temos uma lei que garante esse direito subjetivo aos réus, então, essa tese, segundo estou entendendo, está valendo para os casos anteriores à vigência dessa lei, porque, se for durante a vigência, ou a partir da vigência dessa lei, não haveria necessidade de fazer uma tese. Não é isso?

O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Foi a observação que fiz, exato.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Se me permite, Ministro Ricardo Lewandowski, com essa observação que Vossa Excelência fez, Ministro Alexandre, se Vossa Excelência puder encaixar nos casos anteriores à lei tal, deve haver pedido expresso para esclarecer essa distinção e essa preocupação.

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA - Eu só quero entender também, fica muito difícil, acho que tanto para mim como para o Ministro Nunes Marques, Senhora Presidente, fazer uma explanação a respeito logicamente de todos os debates que já existiram em torno do tema.

A preocupação, me permita aderir à relevância da preocupação trazida pelo Ministro Nunes Marques, a grande questão é, se nós entendermos que isso, que essa tese, que reflete aquele momento, não adentra nas novas perspectivas normativas, a questão para mim está

HC 166373 / PR

resolvida. Se não é assim, de fato, talvez houvesse uma necessidade de um pequeno esclarecimento apenas decotando, salvo mudança legislativa posterior ao momento do julgamento, algo nesse sentido, mas, da minha parte, havendo essa separação de realidades distintas, e mundos e tempos distintos, para mim, acho que a questão estaria - vamos dizer assim - satisfeita.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Uma última intervenção, Senhora Presidente. Eu creio que não há dúvida quanto à relevância do que o Ministro Nunes Marques traz à colação. O que nós aqui estamos a debater é um texto de uma tese que faz sentido no contexto de um determinado processo. Este Tribunal, em momento algum, poderá se negar a deliberar favoravelmente a uma garantia que se estende por uma modificação legislativa superveniente. Portanto, se esse tema se apresentar, não há dúvida alguma que, a partir da lei, do Pacote Anticrime de 2019, a compreensão será de um direito subjetivo que independa de formulação expressa, mas esse contexto não está posto nesse julgamento do qual emerge a tese.

Portanto, o texto da tese há de ser entendido no contexto do julgamento. E assim, subscrevendo a importância e a relevância da observação, a percepção que tenho é que acalma o debate que já se houve, nesse tema, a fixação da tese tal como proposta pelo Ministro Alexandre de Moraes, registrando-se esse debate, como ficará na memória deste julgamento de hoje, da tese, para efeito da compreensão do sentido do alcance da tese.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Presidente, também para acrescentar, sem criar novas objeções. É que, dependendo da anuência do Ministro Alexandre de Moraes, que foi redator para o acórdão, poderia haver dois itens: primeiro item, havendo pedido expresso da defesa, no momento processual adequado, os réus têm o direito de apresentar as alegações; segundo, esse precedente não se aplica às ações penais que se iniciaram após a lei tal.

Isso já resolve.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Ou, então,

HC 166373 / PR

nas ações penais anteriores à lei tal...

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Presidente, duas questões aqui. É minha última manifestação.

Eu presidi a comissão dos juristas que apresentou esse projeto de lei. E nós apresentamos, exatamente, porque já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos andar em círculos, aqui. Aqui, foi uma decisão antes disso. Agora, tem a lei já, mas, aqui, foi antes. Obviamente, se aplica anteriormente, Como que nós vamos colocar um segundo item, se nós nem discutimos a lei?

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Não foi objeto de debate. E sempre poderá haver uma posição divergente.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Aqui, nos debates, já ficou claro isso. Mas, colocar uma tese do que nem foi discutido, porque não existia, começa a não ser uma tese do julgamento. A tese é aquele enunciado que nós fizemos a partir dos debates e do julgamento. Se nós formos incluir algo que foi editado posteriormente ao julgamento, aí nós vamos estar meio que legislando, e não editando uma tese do que foi discutido. Mas, até pelos próprios debates, acho que ficou claro isso.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, me permite mais uma intervenção?

Eu acho que a manifestação do eminente Ministro Nunes Marques realmente me fez refletir um pouco mais verticalmente sobre esta questão.

O que nós quisemos dizer, ao examinarmos aquele processo e concluir, em termos de uma tese, é o seguinte: que são nulas as manifestações das defesas apresentadas após aquelas veiculadas pelos colaboradores. É isto que é, quer dizer, se nós olharmos retrospectivamente toda vez que temos uma alegação final, que foi apresentada depois daquela que foi, enfim, manifestada nos autos pelos colaboradores, nós estamos diante de uma nulidade insanável. Isso que nós decidimos. Daqui para frente a questão está resolvida em função da lei. Não é isso?

HC 166373 / PR

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Ministro Lewandowski, esse foi exatamente o debate que nós tivemos e prevaleceu a ideia da necessidade de pedido expresse. O que o Ministro Nunes Marques traz à colação, e com razão, é que, a partir da lei do chamado Pacote Anticrime, ou seja, de 2019, o que se denomina, aqui, pedido expresse passa a ser um direito subjetivo de apresentação, independentemente da postulação. Portanto, eu creio que está nítido que a observação feita por Sua Excelência integra este julgamento, mas não integrará a tese, porque ela é fiel ao que foi julgado. Mas, fica nítida a questão de que, a partir de 2019, onde se lê pedido expresse, leia-se pedido. Agora, dispensar o pedido, isso não pode ser, porque reabrimos o julgamento.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Vossa Excelência me permite?

O que nós verificamos, nos casos que examinamos aqui - e cito de lembrança - é o seguinte: acusação e defesa apresentam o pedido de alegação final no momento apropriado, do ponto de vista processual. Só que o que os juízes faziam? Ouviam primeiro os colaboradores e, depois, as defesas. Sempre houve um pedido expresse. Eu duvido que alguma defesa técnica tenha deixado de fazer um pedido expresse nos autos para apresentar as alegações finais. O que houve, de fato, e isto foi realmente algo absurdo, do ponto de vista do direito de defesa, foi ouvir primeiro os colaboradores. Ou melhor, os colaboradores por último. Perdão.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Ministro Lewandowski, se me permite.

O que foi muito discutido, e houve muito. O juiz abria a vista para as alegações finais. Primeiro para a acusação e, depois, para a defesa, toda a defesa. E vários advogados não impugnavam isso. Eles apresentavam normalmente. Apresentavam, inclusive, antes do colaborador. O prazo para a defesa era conjunto.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Sim.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - E o advogado apresentava normalmente.

HC 166373 / PR

Alguns advogados, naquele momento - e, aí, é o momento processual adequado, o juiz abriu vista para defesa -, alguns advogados pediam: não, eu só quero falar após o delator. E o juiz indeferia.

O que nós discutimos muito, aqui, foi exatamente o advogado que não pediu, que aceitou prazo conjunto e se manifestou, não fez pedido expresso, ele não tem direito à nulidade. Isso que nós discutimos. Foi uma longa discussão, mas foi vencedor esse posicionamento.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Ministro Alexandre de Moraes, eu peço a Vossa Excelência a gentileza de fazer a leitura da tese que está a propor, para que eu colha o voto de todos.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - Obrigado, Presidente.

Havendo pedido expresso da defesa, no momento processual adequado, CPP, art. 403, e Lei nº 8.038, art. 10, os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - É o 10 ou 11?

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES - É o 11. É que eu lembrei de cabeça, agora, para aderir à sugestão do Ministro Ricardo Lewandowski. Então, art. 11 da Lei nº 8.038, que rege STJ e o Supremo Tribunal Federal na ação penal.

30/11/2022

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO S/PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou de acordo.

Só faço, aqui, uma observação, sobre a lei nova, que diz:

“§ 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou.”

A lei é bem clara: é um direito e, portanto, pode ser exercido. Se não for exercido, não gera nulidade. É uma oportunidade, se não quiser exercer, não exerceu.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Mas esse é um outro debate. Esse é um outro debate que, seguramente, vai ser travado.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Apenas para dizer que a preocupação do Ministro Kassio é pertinente. Acho que já está explícito na lei, não precisa pedir, mas, se não exerceu o direito, também não tem nulidade.

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (PRESIDENTE) - Mas Vossa Excelência apoia a tese?

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Acompanho.

30/11/2022

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

VOTO S/ PROPOSTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Também acompanho a tese, até porque ela se salva, na medida em que tudo aquilo que o juiz pode fazer de ofício não impede a iniciativa da parte.

Então, não vai haver nulidade nenhuma, porque, como já está previsto na lei, se o juiz não se manifestar, a parte pode oferecer o pedido. Se a parte não oferecer o pedido, a lei garante esse oferecimento independentemente de requerimento.

Constando também todo este debate que o Ministro Kassio trouxe - muito próprio -, fez-me refletir.

Concordo absolutamente, integralmente, com a tese do Ministro Alexandre.

30/11/2022

PLENÁRIO

HABEAS CORPUS 166.373 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
PACTE.(S)	: MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA
IMPTE.(S)	: MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA
ADV.(A/S)	: RENATO FERREIRA MOURA FRANCO
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INTDO.(A/S)	: PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES
ADV.(A/S)	: ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES
ADV.(A/S)	: LEONARDO LYRIO DE FREITAS
ADV.(A/S)	: PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA

OBSERVAÇÃO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER

(PRESIDENTE) - O Ministro Dias Toffoli nos comunica que teve que se afastar uns minutos. Já acompanhou e continua acompanhando o Ministro Alexandre de Moraes.

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

HABEAS CORPUS 166.373

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ALEXANDRE DE MORAES

PACTE.(S) : MARCIO DE ALMEIDA FERREIRA

IMPTE.(S) : MARCOS VIDIGAL DE FREITAS CRISSIUMA (130730/RJ, 415825/SP)

ADV.(A/S) : RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (35464/DF)

COATOR(A/S) (ES) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTDO.(A/S) : PAULO ROBERTO GOMES FERNANDES

ADV.(A/S) : ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (1109/AL, 01465/A/DF, 102152/PR, 2251-A/RJ)

ADV.(A/S) : LEONARDO LYRIO DE FREITAS (143413/RJ)

ADV.(A/S) : PAULO EDUARDO AFFONSO FERREIRA (82334/RJ)

Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que denegava a ordem de *habeas corpus*, o julgamento foi suspenso. Falaram: pelo paciente, o Dr. Marcos Vidigal de Freitas Crissiuma; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Alcides Martins, Procurador-Geral da República. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.9.2019.

Decisão: Após os votos dos Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, que concediam a ordem de *habeas corpus*; e dos votos dos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que acompanhavam o Ministro Edson Fachin (Relator), no sentido de denegar a ordem, o julgamento foi suspenso. Não votou, nesta assentada, o Ministro Marco Aurélio. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 26.9.2019.

Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu a ordem de *habeas corpus*, para anular a decisão do juízo de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos à fase de alegações finais, a qual deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Prosseguindo no julgamento e após proposta feita pelo Ministro Dias Toffoli (Presidente), o Tribunal, por maioria, decidiu pela formulação de tese em relação ao tema discutido e votado neste *habeas corpus*, já julgado, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o julgamento foi suspenso para fixação da tese em assentada posterior. Plenário, 02.10.2019.

Decisão: Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: "Havendo pedido expresse da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 30.11.2022.

Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário